

3. Posesión por usucapión (ad usucapionem) y por interdicto (ad interdicta)

La primera se refiere a la posesión de buena fe que permite la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo, mientras que la segunda incluye a la posesión de mala fe. Esta última no produce la consecuencia anterior, sino que sólo concede la protección interdictal⁽⁷⁾.

4. Posesión civil (civilis) y natural (naturalis)

La primera conduce a la adquisición del derecho de propiedad, mientras que la segunda no tiene este efecto y opera como una simple posesión de la cosa, ya que quien la posee no tiene animus, elemento esencial para que se configure la posesión (possessio).

5. Posesión de derecho (possessio iuris) o cuasiposesión (quasi possessio)

Debe destacarse que, con el tiempo, los romanos admiten que la posesión pueda recaer sobre las cosas incorpóreas (res incorporalis). Este tipo de posesión recibe el nombre de possessio iuris o quasi possessio. En un principio, los romanos limitan este concepto a las servidumbres y con el derecho justinianeo lo extienden a la enfiteusis, el usufructo y la superficie⁽⁸⁾.

II. LA ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN

Es indispensable para que ello ocurra que estén presentes los elementos material e intencional llamados corpus y animus, respectivamente.

El primero (corpus) requiere que sea físicamente posible tener la cosa que se pretende poseer y que el poseedor pueda usar de ella, excluyendo a cualquier otra persona que pretenda hacerlo. Sin embargo, excepcionalmente, se admite que pueda adquirirse la cosa sin este requisito, cuando la persona puede tener materialmente la cosa y tiene el ánimo de hacerlo, como, por ejemplo, la adquisición de un tesoro por parte del propietario del terreno en el cual éste se encuentra enterrado, supuesto en el cual la persona sólo necesita el animus para obtener la posesión. El corpus es un elemento de gran importancia porque exterioriza la posesión y constituye su mejor forma de probarla.

Por su parte, el animus, denominado animus domini o animus possidendi, constituye el elemento subjetivo o psicológico de la posesión. Como se exige que exista el animus domini, los infantes, los dementes, los municipios, etc., no pueden adquirir por sí la posesión. El derecho romano admite que se pueda suplir el animus de los incapaces a través de sus representantes legales o voluntarios, es decir, por sus tutores, curadores o síndicos⁽⁹⁾.

La legislación romana siempre reconoce la posibilidad de que la posesión pueda ser adquirida por el pater familias a través de las personas sometidas a su potestad, tanto por los hijos (filius) como por los sirvientes (servis). Desde la época imperial comienza a surgir la idea de que la posesión puede ser adquirida por personas libres que no dependen del titular, como, por ejemplo, a través del procurator. Ya con Justiniano, la posesión puede adquirirse por medio de

cualquier intermediario o procurador que tenga o no mandato para hacerlo, exigiéndose únicamente la ratificación por parte del adquirente⁽¹⁰⁾.

III. LA PÉRDIDA DE LA POSESIÓN

Mientras se encuentren presentes el corpus y el animus domini, la posesión se mantiene, independientemente de que su titular no ejerza el poder en forma inmediata y constante sobre la cosa. En tal sentido, la falta de uno de estos elementos, o de ambos, provoca la pérdida de la posesión⁽¹¹⁾.

a) La posesión se pierde corporalmente (corpore) cuando el titular de la cosa deja de tener poder físico sobre ella. Esto puede ocurrir porque el objeto poseído sale de su órbita de dominio, por ejemplo, un animal doméstico que se escapa y no regresa, o un animal salvaje que, luego de capturado, recupera la libertad, o cuando una persona entierra una cosa, o la esconde y luego olvida dónde la coloca⁽¹²⁾. También sucede cuando el objeto poseído perece, ya sea por muerte, si se trata de animales, o por destrucción, cuando se trata de objetos inanimados o inmuebles⁽¹³⁾. Otro caso se da cuando otro individuo se apodera de la cosa, impidiéndole físicamente disponer de ella al poseedor.

Sin perjuicio de lo expuesto, en algunos casos la jurisprudencia clásica permite que la posesión se mantenga únicamente con la presencia del animus; es el caso de los campos para pastoreo que sólo están ocupados en determinadas épocas del año. Si un tercero ocupa el inmueble con ánimo de poseerlo, sus dueños no pierden la posesión, siempre y cuando no tengan conocimiento de la ocupación, o que, pese a advertirla, no expulsen al usurpador, porque si permanece inactivo por temor o negligencia, o si se le rechaza su pretensión de recobrar la posesión, la pierde en forma definitiva⁽¹⁴⁾.

Luego se extiende esta idea también al esclavo, considerándose que la posesión comprende a todas aquellas cosas que el amo posee por su intermedio, y aun sobre las cosas que el esclavo adquiere con posterioridad⁽¹⁵⁾. En la época de Justiniano no se pierde la posesión cuando otro ingresa en ella en ausencia de su poseedor, considerándose al usurpador como un ladrón, sujeto a la acción de hurto, y el poseedor puede recuperar la posesión valiéndose de los medios generales, siempre y cuando no transcurran treinta años desde la desposesión⁽¹⁶⁾.

b) La posesión se pierde anímicamente (animus) cuando el titular deja de tener la intención de poseer la cosa. Ello debe demostrarse con actos voluntarios, expresos o tácitos, que así lo evidencien, pero esta intención nunca puede presumirse. En este sentido, la posesión se pierde por falta de animus cuando el poseedor sufre la turbación de su posesión por parte de un tercero y no realiza nada al respecto, permitiéndole que se quede con la cosa. Otros supuestos lo constituyen la traditio brevi manu y el constituto possessorio, ya que en ambos casos no se lleva a cabo el acto de traslación o entrega de la cosa. En el primero se le transfiere la posesión a quien antes era tenedor de la cosa, y en el segundo, la posesión se pierde para su titular porque, al enajenar la cosa y permanecer en ella como locador, se convierte en representante de la posesión del adquirente⁽¹⁷⁾.

c) La posesión se pierde corporal y anímicamente (corpore et animo) cuando cesa el poder físico que se ejerce sobre la cosa y el ánimo de poseerla; ejemplo de ello lo constituye el abandono voluntario por parte de una persona de las cosas que le pertenecen (derelictio), y el acto voluntario por el que una persona entrega a otra una cosa con la intención de transferirle el derecho de propiedad (traditio)⁽¹⁸⁾.

IV. LA DEFENSA DE LA POSESIÓN. LOS INTERDICTOS POSESORIOS

La posesión se defiende por medio de los interdictos. Con ellos se protege a quienes están poseyendo de sustracciones o perturbaciones injustas por parte de otro. También cumplen otra función, ya que cuando se discute la propiedad de una cosa, antes de iniciar la "acción de

reivindicación" (reivindicatio), es necesario determinar quién es el poseedor que será demandado por la ella⁽¹⁹⁾.

El interdicto (interdicta) es la orden dada por el magistrado durante la etapa denominada "de derecho" (in iure) del proceso formulario, a petición de un ciudadano, con el objeto de poner fin a una controversia, disponiendo la exhibición de cosas o personas, la restitución de cosas o la abstención de realizar determinados actos. Los interdictos, en un principio, tienen mayor aplicación en la esfera administrativa y pública, pero luego se los emplea también en el campo del derecho privado.

Los principales interdictos son los siguientes:

1. Interdictos de recuperación de la posesión (interdicta recuperandae possessionis). Se utiliza en aquellos casos en que el poseedor trata de recuperar la posesión perdida⁽²⁰⁾. Luego de la reforma agraria que limita la extensión de la tierra pública (ager publicus) que legalmente puede poseer cada ciudadano, algunas personas intentan despojar de dichas tierras a quienes se han visto favorecidos por la nueva distribución. A ello se suma que los clientes que reciben tierras en "precario" por parte de sus patronos se niegan a restituírselas ante su requerimiento. En estos casos, como los titulares de los fundos distribuidos por el Estado sólo tienen el carácter de poseedores, la ley no les otorga una adecuada protección para poder recuperarlos, por lo que entonces el pretor crea este tipo de interdictos para remediar la situación. Existen tres tipos: el unde vi, el de precario y el de clandestina possessione⁽²¹⁾.

1.a. Interdicto unde vi. Se le otorga al poseedor que es expulsado violentamente de un fundo o de un edificio, no se aplica para las cosas muebles⁽²²⁾. El poseedor que es despojado de un inmueble mediante el uso de violencia simple, es decir, sin el empleo de armas, sólo recupera la posesión por medio de este interdicto, si no está poseyendo con vicio de violencia, clandestinidad o como precarista respecto de quien lo priva de la posesión. Este interdicto debe intentarse dentro del año a partir de la expulsión (deiectio) y luego de dicho período el pretor le otorga una actio in factum⁽²³⁾.

En caso de que el poseedor sea expulsado mediante el empleo de violencia armada, éste recupera en todos los casos la posesión, aunque con anterioridad hubiera despojado al agresor utilizando violencia, clandestinidad o como precarista⁽²⁴⁾, y no hay un plazo para intentar esta acción, sino que es perpetua. Para que se pueda interponer este interdicto se requiere la existencia de violencia física o moral, y no procede si el poseedor abandona el fundo por temor de que gente armada intente expulsarlo. Esta acción se puede iniciar no sólo contra el autor directo de la usurpación, sino también contra quien da la orden y contra aquel que la realiza por medio de un representante o un esclavo⁽²⁵⁾.

1.b. Interdicto de precario. Persigue lograr la restitución de un inmueble que se ha dado a título precario, es decir que existe la obligación de devolverlo ante el primer requerimiento. Más tarde se extiende su aplicación a las cosas muebles. Es el pretor, por razones de equidad, quien crea este interdicto con el objeto de que el otorgante recupere la cosa que ha perdido por un abuso de confianza⁽²⁶⁾. Esta acción se otorga al concedente y a sus herederos contra el tenedor precario y sus herederos, a fin de obtener la restitución de la cosa y la reparación de los daños sufridos por la indebida retención de la misma. Si no se puede restituir la cosa, el tenedor precario debe entregar el valor que el accionante le asigna en el momento en que interpone el interdicto⁽²⁷⁾.

1.c. Interdicto clandestina possessione. Es el que otorga el pretor en caso de que una persona sea privada oculta y maliciosamente de la posesión que ejerce sobre un inmueble. Es el caso, por ejemplo, de una persona que deja su casa para ir al mercado y cuando regresa se encuentra con que otro la está ocupando. Cuando aquél regresa puede expulsar al intruso, aunque no por medio de violencia armada⁽²⁸⁾. Este tipo de interdicto deja prontamente de emplearse cuando se dispone que la posesión de los inmuebles no puede perderse clandestinamente y es reemplazado por el interdicto unde vi⁽²⁹⁾.

2. Interdicta retinendae possessionis. Es el otorgado por el pretor por el cual se mantiene en posesión de la cosa a una de las partes cuando existe una controversia acerca de ella. Por este interdicto se prohíbe al vencido perturbar a su adversario en el ejercicio de la posesión. Para obtener tal protección es necesario justificar la posesión, es decir, demostrar que se posee animo et corpore, no importando a tal fin si la posesión es de buena o mala fe. Si el demandado niega la posesión del actor, éste debe probarla. Este tipo de interdicto puede ser de dos clases.

2.a. Interdictum uti possidetis. Se le concede al poseedor de un inmueble contra las perturbaciones que le provoca otra persona, siempre que su posesión no sea viciosa respecto de ella. En un principio se encuentra sujeto a extremas formalidades, dificultándose así su aplicación,

pero con Justiniano se lo unifica con el interdicto utrubi, regido por los principios que regulan el uti possidetis. En virtud de éste, deben cesar las molestias que se le provocan al legítimo poseedor de la cosa, más la indemnización por los daños sufridos⁽³⁰⁾.

2.b. Interdicto utrubi. El pretor lo concede para defender la posesión sobre las cosas muebles de aquel que ha tenido la posesión, sin vicios, por más tiempo durante el año. Para ello resulta importante cuál de los dos ha tenido la posesión de la cosa por más tiempo con anterioridad a que se formule el interdicto. En este sentido, no sólo se computa el lapso en que cada uno de los litigantes tiene la cosa, sino que a éste se le suma el de aquella persona cuya posesión se continúa⁽³¹⁾.

3. Interdicta adipiscendae possessionis. Se le otorga a quien todavía no ha gozado de la posesión de la cosa objeto del litigio⁽³²⁾. Existen cuatro tipos de esta clase de interdictos.

3.a. Interdicta quorum bonorum. Se le da esta acción al heredero designado como tal en virtud de la labor del Pretor (bonorum possessor), con el objeto de que aquella persona que tiene la herencia o parte de ella se la restituya. A tal efecto, no interesa si éste la posee en calidad de heredero o de simple poseedor de la cosa. El interdicto se refiere a la universalidad de bienes que conforman la herencia y no a cada uno de ellos por separado⁽³³⁾.

3.b. Interdicta quod legatorum. Se le confiere al heredero civil y al bonorum possessor con el objeto de que el legatario les restituya aquellos bienes cuya posesión ha obtenido sin su autorización. En caso de que no pueda hacerlo, debe entregarle el equivalente a su valor⁽³⁴⁾.

3.c. Interdicto Salviano. Se considera que es creado por el pretor Salvio a efectos de que el arrendador de un fundo, al que no se le ha pagado el arriendo en el plazo estipulado, entre en posesión de aquellos objetos que el colono o arrendatario introdujo en aquél, y que, por acuerdo entre ambos, han sido afectados para su pago, excepto, según la constitución de Gordiano del año 238, cuando los objetos se encuentran en manos de terceros. Sin embargo, existen divergencias en este punto, ya que según Juliano el interdicto puede interponerse contra quien tiene la cosa, sin ninguna distinción⁽³⁵⁾.

3.d. Interdictum possessorio. El pretor lo otorga en beneficio del bonorum emptor con el objeto de que logre la posesión de los bienes que se le adjudican en virtud de la bonorum venditio que se realiza con motivo de un deudor insolvente. Asimismo, este interdicto recibe el nombre de sectorium cuando se le confiere al comprador sobre bienes que el Estado obtiene por confiscación o por conquista⁽³⁶⁾.

CAPÍTULO XX - LA PROPIEDAD

Se trata de un derecho real sobre la cosa propia y constituye el señorío más general que existe sobre ella, ya sea en acto o por lo menos en potencia, porque su titular puede usar o usufructuar la cosa, disponer y hasta abusar de ella, ya que ésta se encuentra sometida a su poder.

La palabra "propiedad" proviene del latín, *propietas* y *propium*, que significa "aquello que pertenece a una persona o es propio de ella", es decir, lo que pertenece, en definitiva, al "padre de familia".

La voz "propiedad", en sentido jurídico, sirve para designar aquel derecho absoluto que una persona puede ejercer sobre una cosa sin que fuese necesario que su titular se encuentre en contacto inmediato con ella, bastando la mera posibilidad de poder ejercer este derecho libremente.

Es el más amplio de los derechos reales, ya que de él se originan todos los demás y comprende la totalidad de las utilidades o ventajas que pueden obtenerse de una cosa.

I. CARACTERES

El derecho de propiedad es absoluto, exclusivo y perpetuo.

a) Absoluto. Porque no existe poder imaginable que el hombre tenga sobre la cosa que no se encuentre comprendido en el derecho de propiedad. El titular de la cosa puede disponer de ella de la manera que considere más conveniente sin que nadie pueda impedirsele. Ello no significa la inexistencia de limitaciones al derecho de propiedad, pero indica que su titular puede ejercer sobre ella todas aquellas facultades que no están taxativamente prohibidas por el ordenamiento jurídico o mediante convenciones privadas.

b) Exclusivo. No puede haber dos personas con dominio similar sobre una misma cosa. Este principio admite excepciones, ya que en la copropiedad o condominio, la cosa común está sujeta al derecho de propiedad que varias personas pueden ejercer en forma simultánea, aunque, claro está, de modo ideal.

c) Perpetuo. La perpetuidad y la irrevocabilidad son una consecuencia de los dos principios enunciados precedentemente, porque no se puede concebir que este derecho a disponer de una cosa de la forma más amplia se encuentre en manos de un individuo que deba transmitir la cosa o desprenderse de ella en un tiempo determinado. En virtud de ello, Diocleciano, en el año 286, prohíbe la transmisión *ad tempus*, por la cual una persona tiene el derecho de propiedad sobre la cosa por un tiempo determinado y, vencido éste, la debe devolver a su enajenante.

II. CONTENIDO

La propiedad implica el ejercicio de las facultades de usar, disponer y disfrutar.

El "derecho de uso" (*ius utendi* o *usus*) consiste en servirse de la cosa y obtener de ella todas las ventajas posibles sin incluir los frutos. El "derecho de disposición" (*ius abutendi* o *abusus*) radica en el poder de consumir la cosa y, en consecuencia, disponer de ella en forma definitiva y absoluta. Finalmente, el "derecho de disfrute" (*ius fruendi* o *fructus*) es el derecho de gozar de la cosa obteniendo de ella los productos civiles o naturales que pueda producir.

III. LIMITACIONES

Si bien el derecho de propiedad es el derecho más amplio que se tiene sobre una cosa, éste presenta limitaciones. Sostiene Louzán de Solimano que "el dominio se encontraba limitado por ley, razones de vecindad, urbanismo e interés social"⁽¹⁾.

Entre las limitaciones dominiales más usuales en el derecho romano puedo señalar la prohibición de dar sepultura y cremar cadáveres en zonas urbanas; la disposición que prohíbe colocar pira o sepulcro a menos de sesenta pies del edificio de otro; el paso forzoso; la libre navegación por parte del propietario ribereño; los límites de la propiedad (inter limitare), que en zonas rústicas es un sendero libre e imprescriptible de cinco pies de ancho que rodea al fundo (inter limitare) y en las ciudades es el espacio de cinco pies de iguales características que circunscribe la edificación (ambitus); las disposiciones que rigen respecto de construcciones urbanas, como la prohibición de elevar los edificios hasta una altura mayor de ocho pisos; la delimitación de las zonas de edificación de casas (villas) y edificios en propiedad horizontal (insulas); la reparación judicial mediante acciones en el caso del propietario perjudicado por la alteración del curso natural de las aguas de lluvia efectuadas por el vecino; la obra nueva que produce un daño al vecino; la suspensión de obra; su demolición, etc⁽²⁾.

Es interesante observar la limitación del dominio por causa de interés social, por cuanto hasta fines de la República en Roma se aplica la confiscación, es decir, la toma de una propiedad privada de forma absolutamente arbitraria y por la fuerza por razones de índole política y sin pago de indemnización alguna; luego se advierte la sinrazón de este sistema y aparece en el Bajo Imperio la expropiación por causa de interés público, mediante pago de una indemnización al propietario expropiado⁽³⁾.

IV. MODOS ROMANOS ANTIGUOS DE ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD. LA PUBLICIDAD DEL ACTO

1. Mancipatio

Es la venta formal y simbólica que consiste en el cambio de una cosa por una cantidad de dinero, la cual se efectúa ante cinco testigos y un librepens que sostiene la balanza (todos deben ser ciudadanos romanos púberes)⁽⁴⁾. En un principio, la balanza es utilizada para pesar el trozo de cobre, dinero no acuñado que debe ser pesado en la balanza para determinar su valor. Pero con el paso del tiempo, el cobre deja de pesarse, aunque continúa utilizándose la balanza como carácter simbólico. En la mancipatio, como formalidad verbal, sólo habla el adquirente, mientras el enajenante guarda silencio. Es necesario que la cosa que se va a transferir se encuentre presente en el acto, ya que la mancipatio queda concluida cuando el adquirente toma el objeto con la mano, aprehendiéndolo, a menos que se trate de un inmueble, en cuyo caso no se exige este requisito. Con ello opera la inmediata transferencia de la propiedad, ya que no puede estar sometida a condición o término. Es el método idóneo para transmitir el dominio de las cosas llamadas res mancipi. Se pueden incorporar al acto cláusulas adicionales; por ejemplo, la reserva de un usufructo o de otra servidumbre en favor del enajenante. La mancipatio le confiere al adquirente la "acción de continencia" (actio de modo agri), de carácter penal, contra el enajenante si el fundo tiene medidas inferiores a las fijadas y por medio de ella puede obtener el doble del valor faltante; y la "acción de autorización" (actio auctoritatis), en caso de que el adquirente de una res mancipi sufra evicción, es decir, si es privado de ella por la reivindicación ejercida por el verdadero

propietario, autorizándolo a reclamarle al enajenante el doble del precio pagado por la cosa. La mancipatio es abolida formalmente por Justiniano, ya que la legislación romana adopta la tradición (traditio) como única forma de transmitir la propiedad⁽⁵⁾.

2. In iure cessio

Consiste en la transferencia de la propiedad bajo la garantía de la autoridad constituida, es decir, ante el magistrado, mediante un proceso reivindicatorio, simulado o ficticio, en el cual, y en presencia del pretor, el adquirente sujeta el objeto a adquirir y afirma que le pertenece por derecho de los quirites. A continuación, el pretor interroga al cedente o enajenante acerca de si se opone a la pretensión del adquirente y, en caso que éste no se oponga o calle, le adjudica el objeto a quien lo reclama como propio⁽⁶⁾. La in iure cessio se utiliza para la transmisión de las cosas llamadas res Mancipi y nec Mancipi, como también para la transmisión de cosas corporales e incorporales. Asimismo, es especialmente apta para la transferencia de otros derechos reales, como la servidumbre. Es de destacar que la in iure cessio no confiere al adquirente la "acción de autorización" (actio auctoritatis), y tal vez por esta razón es más común el empleo de la mancipatio en la transferencia del dominio. La in iure cessio desaparece como medio de transferir la propiedad al reemplazarse el sistema de "acciones de la ley" por el "procedimiento formulario" y, fundamentalmente, por la aparición de la tradición como medio idóneo para la transmisión de derechos.

Oportunamente he dado mi opinión respecto de la "publicidad del acto" en el derecho romano, considerando que los juristas comprendieron desde temprano que el "acto debe ser público" para producir efectos, esencialmente la "oponibilidad a terceros". Entiendo que el caso de la adquisición de la propiedad no escapa a dicha premisa, sino que la reafirma. No deben interpretarse de otro modo las exigencias requeridas para la transmisión de la propiedad; v.gr., la cantidad de los testigos, su condición de ciudadanos romanos y púberes, el portador de la balanza (librepens), el pesado del cobre, las palabras sacramentales emitidas en el acto, etc. Es evidente que todo ello conduce a la "notoriedad del acto", a su "publicidad", a que no resten dudas de su trascendencia e importancia de allí en más, haciendo oponibilidad al resto de la comunidad. En la actualidad tenemos el "derecho registral". Pues bien, en la Roma antigua, la falta de éste es suplida mediante los modos solemnes de transmisión de propiedad que hacen a la vez de registro en el seno de la comunidad. Luego, con el avance del tiempo, y también dentro del mismo derecho romano, aparecen los primeros registros dominiales.

V. MODOS ROMANOS MODERNOS DE ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD

1. Ocupación (occupatio)

Implica el apoderamiento de algo que no pertenece a nadie con la intención de hacerlo propio. La cosa puede no tener dueño porque nunca le ha pertenecido a nadie o porque su dueño la ha abandonado⁽⁷⁾; v.gr., animales salvajes. También pueden ser objeto de ocupación los animales domesticados (por ejemplo, los ciervos que han perdido la costumbre de retornar al redil de su dueño⁽⁸⁾). Los animales domésticos, como los perros y las gallinas, no se consideran res nullius y, por lo tanto, no son susceptibles de apropiación. Esta forma de adquirir la propiedad tiene gran vigencia en la época de expansión territorial de Roma, ya que permite la apropiación de los bienes del enemigo y de los pueblos conquistados con los cuales no se celebran tratados de alianza o de amistad⁽⁹⁾. Los fundos pertenecientes al enemigo pasan a ser propiedad del Estado romano y luego

pueden ser vendidos o concedidos a los particulares. En cuanto al botín de guerra, sólo puede ser adquirido por ocupación cuando se cuenta con la autorización del general a cargo.

Dentro de la "ocupación" se encuentra el caso particular del hallazgo de un "tesoro" (tesaurus), entendiéndose por éste como aquel objeto móvil de valor escondido desde tiempos remotos. En los primeros tiempos, el tesoro le pertenece completamente al dueño del fundo en el cual se halla, ya que se considera que la propiedad de un inmueble alcanza a todo lo que se encuentra en su superficie o debajo de ella. Luego, el tesoro se considera un bien vacante y su propiedad se le adjudica, por ley, al Estado. Finalmente, Hadriano dispone que la mitad del tesoro le corresponde al dueño del fundo y la otra mitad a quien lo encuentra. Es necesario, para que aquel que encuentra el tesoro en un fundo ajeno pueda adquirir su propiedad por ocupación, que su hallazgo sea fruto del azar, ya que si su aparición es el resultado de una excavación que se realiza a tal fin, la propiedad del tesoro le pertenece por completo al dueño del fundo⁽¹⁰⁾.

2. Accesión

Se produce cuando una cosa se une a otra de modo natural o artificial, formando un todo inseparable. El dueño de lo principal adquiere la propiedad de la cosa accesorio⁽¹¹⁾. La accesión de un inmueble a otro inmueble sólo puede producirse por acontecimientos naturales, es decir, no por hechos de los hombres. La "accesión" puede ser sobre cosas inmuebles y sobre cosas muebles.

1. Accesión de cosas inmuebles. Como se dijo, solamente interviene en ella la acción de la naturaleza. Los distintos casos son los siguientes:

a) Aluvión. Consiste en el lento depósito de tierra en los fundos ribereños inferiores (limo) por la acción de las aguas que erosionan el curso superior.

b) Avulsión. Es el agregado brusco en un terreno de una porción de tierra fragmentada de otro fundo ubicado en el curso superior del río. Es necesario que la tierra añadida quede unida de modo permanente al fundo y desde ese momento su propietario adquiere por accesión el nuevo terreno⁽¹²⁾.

c) Lecho del río. Esta denominación es genérica, puesto que abarca distintos supuestos; así, el propietario de la orilla es el dueño de la isla ribereña que se forma frente a ella. Si la isla se forma en medio de un río, ésta queda bajo el dominio de los propietarios ribereños de ambos lados, y para determinar qué porción le corresponde a cada uno, se toma como base una línea imaginaria que divide al río en dos⁽¹³⁾. Por otra parte, cuando el cauce de un río queda seco, los propietarios de las orillas también se convierten en dueños del cauce seco, y para delimitar la propiedad de cada uno, debe trazarse la línea media del río y tirarse las perpendiculares hasta dicha línea desde los límites de cada fundo⁽¹⁴⁾.

2. Accesión de cosas muebles. En ella encontramos una proficua casuística, producto de la actividad de la jurisprudencia romana, que, a modo de ejemplo, paso a detallar:

1) La obra o edificación adherida en forma permanente al suelo le pertenece por accesión al dueño del terreno. Pueden darse dos supuestos: el primero consiste en que se construya en un terreno propio con materiales ajenos, en cuyo caso el propietario del terreno se hace también dueño de la edificación por ser ésta un accesorio del suelo. El segundo supuesto se da cuando una persona construye en un terreno ajeno con materiales propios, en cuyo caso, y por las reglas de la accesión, la propiedad del edificio le pertenece al dueño del terreno. Si el edificio es demolido, el dueño de los materiales puede reivindicarlos, sin que el titular del terreno pueda invocar a su favor la prescripción por el tiempo en que aquéllos estuvieron incorporados al fundo⁽¹⁵⁾.

2) Siembra. Los árboles plantados y las semillas sembradas en terreno ajeno pasan a ser propiedad del dueño del suelo⁽¹⁶⁾.

3) Otros supuestos. El paño tejido con hilos ajenos, la tela teñida con tela ajena y lo escrito en papel ajeno. En estos casos la propiedad le pertenece al dueño del paño, tela o pergamino. En el caso de las pinturas, el autor del cuadro adquiere la propiedad de la tela sobre la que realiza su obra. Ello ocurre porque la obra terminada tiene más valor que la tela por sí sola. Por otra parte, cuando dos trozos del mismo metal se sueldan y constituyen un todo orgánico, conforman una soldadura (ferruminatio) que determina la adquisición de la cosa accesorio por el dueño de la principal (v.gr., cuando a una estatua de bronce se le suelda un brazo también de bronce). En

cambio, cuando la unión se verifica mediante la utilización de otro metal, como por ejemplo el plomo o el estaño, no se considera que haya accesión⁽¹⁷⁾.

3. Especificación. Es la transformación de materia prima en otra cosa distinta de la anterior (v.gr., trigo en pan). Esta figura genera controversias en cuanto a quién le pertenece la propiedad de la especie nueva cuando se confecciona con materia prima ajena. Justiniano resuelve la cuestión estableciendo que si el objeto nuevo puede recuperar su forma primitiva, la nueva especie le pertenece al dueño del material y, en caso contrario, al especificador⁽¹⁸⁾. Si se utilizan materias primas propias y ajenas para confeccionar la nueva especie, su propiedad le pertenece al especificador⁽¹⁹⁾.

4. Tradición. Consiste en el simple traspaso de una cosa de manos del dueño a las de un tercero, teniendo el primero la intención de desprenderse de ella y el segundo de adquirirla con causa lícita. Es necesario que tanto aquel que enajena la cosa como aquel que la adquiere tengan capacidad de enajenar y adquirir, debiendo además revestir el enajenante la calidad de propietario de la cosa, ya que nadie puede transmitir a otro un derecho más extenso que el que tiene sobre ella (nemo plus iuris⁽²⁰⁾), con excepción del Estado, el emperador o los acreedores hipotecarios, quienes, a pesar de no ser los propietarios de las cosas que enajenan, les transmiten la propiedad a los adquirentes. Asimismo, no pueden enajenar, a pesar de ser propietarios, los locos, los pródigos y los infantes. También es necesario que la entrega de la cosa se efectúe con la intención común de ambas partes, así, del "enajenante" (tradens), de transferir la propiedad, y del "adquirente" (accipiens), de adquirirla, debiéndose exteriorizarla. Es por ello que se exige que se lleve a cabo la remisión de la posesión, que consiste en el acto por el cual el tradens pone al accipiens en posesión de la cosa. En un principio, cuando se transfiere una cosa mueble, ésta debe pasar de la mano del tradens a la del accipiens, y cuando se trata de un inmueble, resulta necesario que el accipiens ingrese a éste. Luego estas exigencias se suavizan, hasta que en la época clásica se permite que se cumpla con la tradición sin que resulte necesaria la remisión de la posesión. Las distintas clases de "tradición" son las siguientes:

a) Traditio simbólica. La entrega de un símbolo o la realización de un acto simbólico resultan suficientes para operar la tradición; por ejemplo, la entrega de las llaves del inmueble o negocio cuando se lo transfiere⁽²¹⁾.

b) Traditio brevi manu. Este supuesto se produce cuando el adquirente ya tiene la posesión de la cosa y entonces el vendedor no necesita hacer la tradición real porque el comprador ostenta el poder físico sobre ella. Por ejemplo, cuando una persona alquila un inmueble y luego decide comprarlo. En el caso inverso, es decir, que el propietario de la cosa la enajena pero continúa conservándola en su poder, v.gr., a título de arrendatario, también se produce la transferencia de la propiedad sin un acto material de remisión de la posesión y ello recibe el nombre de constitutum possessorium⁽²²⁾.

c) Traditio longa manu. Cuando se realiza la transferencia de bienes muebles o inmuebles que el adquirente tiene a su alcance, pudiendo disponer de ellos a voluntad, se reemplaza la entrega de la cosa por su indicación o señalamiento desde lejos⁽²³⁾.

5. Usucapión (usucapio). La propiedad de la cosa se adquiere mediante el transcurso del tiempo, previamente establecido, ejerciendo la posesión continuada de la cosa. El cumplimiento del plazo estipulado por ley tiene por objeto sumar, a la simple posesión, la protección legal con que cuenta aquel que tiene el derecho de propiedad sobre una cosa. En la ley de las XII Tabas se establece que el plazo de tiempo que debe transcurrir para los fundos es de dos años y para las cosas muebles de un año⁽²⁴⁾. Luego, se exige, además del transcurso del tiempo, el "justo título", lo que implica una relación con el antiguo poseedor, y "buena fe", es decir, no obrar en contra de las leyes queriendo lesionar voluntariamente el derecho del legítimo poseedor⁽²⁵⁾. En tal sentido, por justa causa o justo título se entiende todo aquel acto jurídico válido que es idóneo para justificar la adquisición del dominio, pero que, por adolecer de un defecto de forma, tan sólo legitima el comienzo de la posesión. Si la posesión se origina por error, se configura una falsa causa y, por lo tanto, ella no da lugar a la usucapión. En cambio, la jurisprudencia romana mantiene criterios dispares cuando se encuentra frente a un título putativo (buena fe)⁽²⁶⁾.

La buena fe existe cuando el comprador ignora que la cosa es ajena o, al adquirirla, cree que quien se la vende tiene derecho para hacerlo, ya que ésta generalmente se basa en el error en que incurre el adquirente que cree que está recibiendo la cosa de parte del propietario o su representante⁽²⁷⁾. No se requiere que el error implique un desconocimiento absoluto de la situación jurídica real, bastando con que la buena fe exista en el momento en que se toma posesión del objeto a usucapir, considerándose que la mala fe sobreviniente no interrumpe el plazo para adquirir la

propiedad. Si un tercero ejecuta algún acto de desposesión, resulta necesario el comienzo de una nueva usucapión con los mismos requisitos de justa causa o título y buena fe.

Por último, no son susceptibles de usucapión las res divini iuris y las res humani iuris, ya que debe tratarse de una cosa que esté en el comercio, quedando además excluidas las cosas adquiridas mediante el uso de la fuerza o hurtadas y todas aquellas que la ley dispone que no pueden ser usucapidas; por ejemplo, el fundo dotal⁽²⁸⁾. Tampoco resultan susceptibles de usucapión los fundos itálicos

Al cumplimentarse la totalidad de los requisitos detallados precedentemente, la usucapión queda configurada y el poseedor adquiere el derecho de propiedad sobre la cosa, con los mismos alcances que su antiguo propietario, extinguiéndose de esta manera el derecho de este último sobre la misma.

6. Praescriptio longi temporis. Remedia alguna de las deficiencias que presenta la usucapión, ya que sólo se encuentran facultados para adquirir por este medio los ciudadanos romanos y se aplica a los fundos itálicos, protegiendo mediante unaexcepción al poseedor contra quien se lleva a cabo la reivindicación de la cosa. Deben transcurrir diez años desde la posesión sin que el propietario reclame la cosa para que se configure esta forma de adquirir la propiedad. En la legislación justiniana se utiliza el término usucapión para indicar la adquisición de la propiedad de las cosas muebles, fijándose el plazo en tres años, y el término prescripción para las cosas inmuebles, debiendo transcurrir diez años para que se configure entre presentes y veinte entreausentes⁽²⁹⁾.

7. Praescriptio longissimi temporis. El poseedor puede adquirir la propiedad de una cosa mueble o inmueble por el transcurso de treinta años⁽³⁰⁾ sin necesidad de justo título, aunque sí necesita cumplir el requisito de buena fe. Esta forma de adquirir la posesión tiene origen con Teodosio II, quien establece la caducidad de las acciones cuando no se las ejerce en treinta años⁽³¹⁾. En caso de duda, el lapso es de cuarenta años. Igual período se exige cuando se trata del Estado, iglesias y comunidades menores, como forma de proteger los bienes que, por integrar el acervo de dichos entes, resultan de interés público⁽³²⁾.

8. Por ley. La ley le otorga la propiedad de una cosa a una persona. Un ejemplo de ello lo constituye el legado per vindicationem, por medio del cual se le transmite la propiedad civil al legatario tan pronto como el heredero acepta la herencia⁽³³⁾. En este caso, la adjudicación de la propiedad se efectúa sin tener en cuenta la voluntad del propietario de la cosa.

9. Adjudicación. La propiedad es otorgada por el juez en el transcurso de aquellos procesos que tienen por objeto obtener la división de la cosa común que hasta ese momento está en condominio (v.gr. partición judicial). Con ella se le entrega a cada uno de los copartícipes la propiedad exclusiva de una parte de la cosa⁽³⁴⁾.

VI. LA DEFENSA DEL DERECHO DE PROPIEDAD

La protección de la propiedad se lleva a cabo mediante el ejercicio de la "acción de reivindicación" (reivindicatio), que le corresponde únicamente al ciudadano romano en virtud del ius civile. Antiguamente, en la contienda jurídica, la carga de la prueba le corresponde a ambas partes; más tarde, ésta sólo se pone a cargo del actor, quien no sólo debe demostrar que es el propietario, sino también el dominio del propietario anterior, hasta llegar al propietario originario. Lo complejo del procedimiento lleva a que reciba la denominación de "prueba diabólica"⁽³⁵⁾. El fin perseguido por la "acción de reivindicación" es el reconocimiento del derecho de propiedad sobre la cosa objeto del litigio y su devolución al propietario. La cosa reivindicada debe restituirse con todos sus frutos y accesorios. Por supuesto que el casuismo jurisprudencial romano se expide sobre diversos supuestos, como la buena o mala fe de quien posee la cosa hasta que se le exija la devolución mediante la reivindicatio, los deterioros que puede sufrir la cosa⁽³⁶⁾, etc.

VII. BREVE CONSIDERACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD EN ROMA

Habiendo explicitado la defensa de la propiedad a través de la "acción de reivindicación", resulta más sencillo abordar la evolución de la propiedad en Roma. Existen cuatro tipos de propiedades, a saber: quiritaria, publiciana, bonitaria y provincial.

a) La propiedad quiritaria es la propiedad por excelencia en Roma. Es aquella que puede únicamente ostentar el ciudadano romano (quiritas) o, en su caso, un latino que goce del *ius commercium*. Se adquiere o transmite sólo por la *mancipatio* o la *in iure cessio*, y sobre cosas *mancipi* que se encuentren en el suelo romano. Esta propiedad tiene rasgos de señorío absoluto sobre los fundos, extendiéndose en modo ilimitado tanto hacia el aire como hacia el suelo.

b) La propiedad publiciana nace como remedio pretoriano ante los casos en que la transmisión de la propiedad quiritaria presente vicios, poniendo en peligro la titularidad del verdadero dueño, dado que éste puede perderla por cuanto se lo considera un mero poseedor en razón de los defectos que obraron en la transmisión. Un pretor de nombre Publicio brinda solución al problema otorgando la "acción de reivindicación" (*reivindicatio*) que es propia del *ius civile* a los titulares que tuviesen estos vicios de adquisición. La "acción de Publicio" es una de las tantas soluciones brindadas por el "derecho honorario" mediante "ficciones". La acción tenía la finalidad de suponer transcurrido el plazo para *usucapir*. De este modo, frente al "derecho civil", los propietarios no son verdaderos dueños, pero sí lo son en virtud del "derecho pretoriano"⁽³⁷⁾.

c) La propiedad bonitaria es también un tipo de propiedad que surge de la actividad del pretor a raíz de los inconvenientes suscitados cuando el adquirente de una cosa (*mancipi* o *nec mancipi*) la recibe por quien no tiene dominio sobre ella según el derecho civil por ser extranjero. En este caso se aplica el derecho de gentes, dado que el peregrino no goza del *ius commercii* (facultad de disponer según la normativa del derecho civil), originándose la "propiedad de los peregrinos" o "propiedad bonitaria"⁽³⁸⁾. La solución propiciada por el "derecho pretoriano" consiste también en una ficción jurídica, por cuanto, mediante la creación de las acciones de hurto (*actio furti*) y de la ley *Aquilia* (*actio legis Aquiliae*), se estima que el peregrino goza de la ciudadanía.

d) La propiedad provincial emerge en contraposición con la calidad jurídica de los fundos situados en la Península Itálica, puesto que estos últimos se encuentran regidos por el "derecho quiritario", por cuanto se consideran que pertenecen en propiedad al pueblo romano o al emperador, y sólo se entregan a los simples particulares en goce, significando entonces que no tienen la protección, defensa y modos de transmitir que otorga el *ius civile*. Luego la situación evoluciona y al propietario provincial se le concede la "acción publiciana", hasta que Justiniano la denomina también *dominium* o *proprietas*⁽³⁹⁾. Es de destacar que este tipo de propiedad se origina por el expansionismo romano, que adiciona al Estado las tierras de los vencidos. Lógicamente, hubo que brindarles una solución jurídica, dando origen a este tipo de propiedad.

VIII. EL CONDOMINIO (COMMUNIO)

Ulpiano define el condominio diciendo que los titulares "tienen la cosa indivisa (*pro indiviso*), no como si el todo fuese de cada uno de ellos, sino sólo por partes indivisas, de suerte que tengan las partes de la cosa de modo más bien intelectual que corporal"; y también sostiene el jurista clásico que "no puede ser de dos personas íntegro el dominio o la posesión, ni cualquiera ser señor de parte de la cosa, sino que tiene en parte el dominio de toda la cosa sin dividir"⁽⁴⁰⁾.

Los conceptos vertidos por el célebre jurista respecto del condominio se compadecen con las características de la propiedad romana. En efecto, si esta última es exclusiva, y por ende no puede pertenecer en modo individual a varias personas, entonces se admite una comunidad de propiedad por cuotas ideales o *alícuotas*, sin determinación de partes físicas entre los titulares. Por dicha razón se sostiene que mientras no se lleve a cabo la partición, existe condominio, es decir que la cosa pertenece de modo *pro-indiviso* a los titulares, que reciben el nombre de copropietarios⁽⁴¹⁾. El estado de indivisión es temporario, sólo por el tiempo estipulado entre los condóminos. Luego se puede pedir la división por medio de una acción especial (*actio comun dividendo*)⁽⁴²⁾.

Capítulo XXI - La Servidumbre

CAPÍTULO XXI - LA SERVIDUMBRE⁽¹⁾

La servidumbre puede ser definida como una restricción al derecho de propiedad. Es el poder que ejerce una persona sobre la cosa de otro, configurando un derecho real sobre cosa ajena (iura in re aliena) que se manifiesta en el poder que ejerce una persona sobre la cosa de otro, por el cual el propietario de la cosa queda obligado a permitir la realización de ciertos actos o impedido de llevar a cabo otros, ya sea en beneficio de una persona o de un fundo determinado.

Del estudio pormenorizado de las fuentes se obtienen las características de las servidumbres, puesto que, como se ha visto, los juristas romanos son contrarios a las generalizaciones y teorías⁽²⁾, que son las siguientes:

a) Las servidumbres no pueden constituirse sobre una cosa propia (nulli res sua servit) puesto que de lo contrario sería un contrasentido. b) Tampoco pueden establecerse sobre otra servidumbre, sino sobre una cosa (servitus servituis esse non potest). Se cree que el texto es el resultado de una interpolación, ya que en el derecho clásico es sensiblemente distinto. Luego, los compiladores modifican su redacción debido a que consideran el usufructo como servidumbre, y en el derecho justiniano se encuentran casos de usufructo de una servidumbre⁽³⁾. c) Representa en sí misma una abstención, una actitud negativa del propietario, un dejar hacer o sufrir por parte de éste (servitus in faciendo consistere nequit). d) Deben proporcionar una utilidad (utilitas) o ventaja a una persona o fundo determinado (servitus fundo utilis esse debet). e) Son indivisibles. f) Son inalienables. g) Se encuentra sancionada por el derecho civil y, por lo tanto, goza de la protección de una acción civil in rem (la acción confesoria) por la cual el titular de la servidumbre puede hacer reconocer judicialmente su derecho⁽⁴⁾.

I. CLASIFICACIÓN

Las servidumbres pueden ser clasificadas en personales (servitutes personarum u hominum), cuando el derecho concedido recae sobre una persona, y en prediales o reales (servitutes praediorum o rerum), cuando recaen sobre un fundo⁽⁵⁾.

Las servidumbres personales son temporales porque finalizan al morir la persona a quien se las concede. En cambio, las servidumbres prediales se configuran cuando el derecho real se establece sobre un inmueble en provecho de otro. Necesita siempre la existencia de dos fundos contiguos o vecinos, uno llamado dominante (praedium dominans), que es aquel que ejerce el derecho de servidumbre, y el otro denominado sirviente (praedium servum o servians), que es aquel que soporta⁽⁶⁾. En primer lugar, he de referirme a las servidumbres prediales y luego haré lo propio con las personales.

II. LAS SERVIDUMBRES PREDIALES. CLASIFICACIÓN

Como he señalado, este tipo de servidumbre se da cuando se establece sobre un fundo en provecho de otro. Entre las principales características de las servidumbres prediales podemos señalar las siguientes: a) Debe producir una utilidad al fundo dominante, lo que no quiere decir un beneficio personal a su titular, sino al fundo en sí; caso contrario se desvirtúa su naturaleza⁽⁷⁾. b) Se establece a perpetuidad, según el ius civile, mas luego el derecho honorario permite que sea por tiempo determinado⁽⁸⁾. c) Debe tener una causa permanente derivada de una cualidad natural del fundo sirviente que hace de su ejercicio un modo indefinido e independiente del propietario del fundo⁽⁹⁾. d) Es indivisible por su propia naturaleza, puesto que abarca al fundo íntegramente⁽¹⁰⁾.

Las servidumbres prediales se dividen en rurales o rústicas (servitutes praediorum rusticorum) y urbanas (servitutes praediorum).

Al llevar a cabo esta división, las fuentes evidencian la utilidad y verdadera importancia que les conceden a las servidumbres. Desde muy antiguo, teniendo como pilar económico a la agricultura, es menester legislar sobre las servidumbres prediales rústicas, con el fin de facilitar o hacer más productiva la explotación de los fundos itálicos. De aquí se infiere su inclusión entre las res mancipi. Las servidumbres prediales urbanas son de origen posterior, atento a su menor utilidad, por lo que se las incluye entre las res nec mancipi.

Esta clasificación tiene en cuenta el fundo dominante. En el caso de las servidumbres rústicas, se trata de un inmueble libre, no edificado, destinado a la explotación agrícola. Para las servidumbres urbanas, lo que cuenta es la existencia de edificación, sin importar su ubicación geográfica⁽¹¹⁾. Sin perjuicio de adoptar el criterio señalado, debo destacar que la cuestión al respecto no se encuentra en modo pacífico en la doctrina, dado que diversos autores opinaron en contrario, manifestando conceptos con variedad de matices. Así, se ha entendido que la distinción entre ambas categorías se encuentra en las particularidades inherentes a la naturaleza del derecho que se ha de ejercer. En este sentido, para las servidumbres rurales importa el hecho actual del titular del derecho (ius faciendi) y para las urbanas el derecho de tener obras exteriores y gozar de ellas (ius habendi) o prohibir al propietario del predio sirviente que disponga de su propiedad de un modo determinado (ius prohibendi). Otra postura consiste en plantear la división teniendo en cuenta la cualidad del fundo sirviente.

1. Principales servidumbres prediales rústicas

Son las siguientes: a) Servidumbre de paso: Comprende las de iter, actus y via. La denominada iter (ius itineris) autoriza el paso y tránsito por el fundo sirviente en las modalidades a pie, caballo o litera. La conocida como actus (ius actus) permite el paso autorizado por el iter, más el traslado de las bestias de carga y los carros. Y la más completa de todas, la de via (ius via), otorga el derecho pleno de pasaje en un sendero de ocho pies en línea recta y de dieciséis en las curvas, conforme se estipula en la "ley de las XII Tablas"⁽¹²⁾. b) Servidumbre de acueducto (servitus aquaeductus). Es el derecho de conducir el agua a través del fundo sirviente al fundo dominante mediante zanjas, acequias o tubos, pero sin la autorización de construir acueductos de mampostería. c) Servidumbre de estanque (servitutes navegando). Autoriza el paso por un estanque o lago del vecino. d) Servidumbre de sacar agua (servitutes aquahauriendae). Comprende la autorización para sacar agua del fundo sirviente según las necesidades del fundo dominante. e) Servidumbre de abreviar el ganado (servitutes pecuris ad aquam adpellendi). Permite llevar el ganado del fundo dominante al fundo sirviente para tomar agua. f) Servidumbre de quemar cal y extraer greda o arena del fundo sirviente (servitutes calcis coquendae cretae ehimendae, arenae fodiendae). Consiste en el derecho del propietario del fundo dominante de quemar cal, extraer piedras o arenas del fundo sirviente⁽¹³⁾.

2. Principales servidumbres prediales urbanas

Las servidumbres urbanas son numerosas y, aunque menos importantes que las rústicas, están igualmente legisladas por los juristas debido a la necesidad de regular todo lo relativo a las cargas que deben soportar los propietarios de los edificios vecinos.

Entre las más conocidas e importantes se encuentran: a) Servidumbre de apoyo de viga (servitutes tigni immittendi). Otorga al propietario del fundo dominante el derecho de apoyar vigas u otros materiales de construcción en el muro de propiedad del fundo sirviente (vecino). b) Servidumbre de apoyo de muro (servitutes honreis ferendi). Concede el derecho al propietario del fundo dominante de apoyar un edificio sobre un muro o construcción del fundo sirviente (vecino). Presenta además la singularidad de que el propietario gravado por la servidumbre

tiene que mantener en buen estado el edificio sobre el que descansa la construcción otorgada en servidumbre. c) Servidumbre de avanzar sobre el fundo vecino con balcones, galerías y tejados (servitutes proiciendi o protegendio). Permite este tipo de construcciones sobre el fundo sirviente. d) Servidumbre de desagüe (servitutes stillicidi). Autoriza a descargar sobre el fundo sirviente las aguas de lluvia que caen sobre el fundo dominante. Ello puede suceder de varias maneras, naturalmente (servitutes stillicidi), por canaletas (servitutes fluminis), por tuberías o canales (servitutes cloacae). Estas servidumbres de desagüe presentan la particularidad de que pueden ser establecidas de modo negativo (servitutes stillicidi vel fluminis non recipiendi). e) Servidumbre de prohibición al vecino de elevar su edificación más allá de determinada altura (servitutes altius non tollendi). Se formula en forma negativa o a manera de prohibición, facultando al fundo dominante a exigir del fundo vecino no erigir su edificación más allá de cierta altura. f) Servidumbre de impedir de privar al otro de la luz (servitutes ne luminibus officiatur). Prohíbe al fundo sirviente privar de luz con su edificación al fundo dominante. g) Servidumbre de vista (servitutes luminum). Autoriza a abrir ventanas sobre el terreno para recibir la luz⁽¹⁴⁾.

III. CONSTITUCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES PREDIALES

Las servidumbres pueden ser constituidas mediante dos modos, a saber: a) Directamente, cuando el propietario de un fundo cede de éste una ventaja hacia un inmueble vecino (transitio servitutis); b) Indirectamente, cuando el propietario de dos fundos enajena uno, creando sobre este último una servidumbre en ventaja del otro (deductio o retentio servitutis).

No obstante lo expuesto, he de tratar la evolución del modo de constitución de servidumbres, según el derecho civil, el derecho honorario y el derecho justinianeo.

a) Durante el antiguo derecho civil (ius civile), las servidumbres rurales o urbanas se crean principalmente por in iure cessio, adjudicación (adjudicatio), legado per vindicationem y por mancipatio, en el caso de las servidumbres rurales por res mancipi. Latraditio no se considera idónea en la legislación romana para constituir una servidumbre, puesto que no tiene aplicación respecto de los fundos itálicos y las cosas incorpóreas⁽¹⁵⁾. En cuanto a la usucapio, tema debatido por los especialistas, puede sostenerse, según Paulo, que ella es también un modo de constitución de servidumbre, puesto que el citado jurista determina que una lex scribonia suprime a la usucapio como medio adquisitivo de servidumbres, lo cual permite inferir que muy antiguamente ella es aceptada para las primitivas servidumbres rústicas comprendidas entre las res mancipi⁽¹⁶⁾.

b) El derecho honorario (ius honorarium) trata de mitigar el excesivo rigorismo del derecho civil, por el cual no pueden constituir servidumbres los extranjeros, ni aun respecto de los fundos provinciales. Para ello se recurre a modos indirectos, admitiéndose como acto constitutivo del derecho real de servidumbre la obligación asumida mediante una simple convención acompañada de una pena fijada por estipulación, destinada a respetar el ejercicio de una servidumbre (pactionibus et stipulationibus). También se admite la adquisición de la servidumbre por el paso del tiempo (usucapio). El pretor protege su ejercicio mediante interdictos posesorios y excepciones y acciones, como la acción confesoria y la acción publiciana⁽¹⁷⁾.

c) El derecho justinianeo deja sin efecto los vetustos modos del derecho civil, como la mancipatio, la iniure cessio, y mantiene los legados en cualquiera de sus formas, la adjudicación (adjudicatio) y el pacto atque stipulatio. También se acepta durante este período la traditio como medio de constitución de servidumbres rústicas (quasi traditio). Similar consideración obtiene la prescripción como modo normal de constitución de servidumbres rústicas, exigiéndose, para que tenga efectos, una cuasiposesión sin vicios durante diez años, entre presentes, y de veinte años, entre ausentes, amén del justo título y la buena fe⁽¹⁸⁾.

IV. EXTINCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES PREDIALES

Existen en la legislación romana distintos medios de extinción de las servidumbres, a saber: a) Confusión. Se origina cuando un mismo propietario reúne la calidad de titular del fundo dominante y del sirviente. Se basa en el principio de que nadie puede ejercer servidumbre sobre la cosa propia (nemine res sua servit). b) Falta de ejercicio o uso de ella. Se exige para esto la inoperancia en su ejercicio en similar plazo que la usucapión, es decir, dos años para bienes muebles o inmuebles en el derecho clásico, y diez años entre presentes y veinte entre ausentes para los bienes inmuebles, y tres años para los muebles, según el derecho justiniano. c) Pérdida de la cosa gravada. Esto produce también su extinción. d) Deterioro padecido por la cosa gravada. Los cambios o destrucciones que sufra el bien gravado, que tornan imposible el ejercicio de la servidumbre, extinguen esta última, con la salvedad de que si estos cambios o destrucciones son parciales y el ejercicio de la servidumbre puede mantenerse, ésta continúa mientras exista la factibilidad de ser ejercida. Es menester aclarar que los juristas romanos deciden que aquellas servidumbres que se han extinguido por el cambio padecido en el bien sometido a servidumbre, renacen si éste recobra, por cualquier causa, su estado anterior, siempre que no se extinga primero por la falta de uso. e) Renuncia del titular. Finalmente, la renuncia llevada a cabo por el titular del fundo dominante también extingue la servidumbre. En igual sentido, en el supuesto de tratarse de un condominio, siendo menester la renuncia de todos los condóminos⁽¹⁹⁾.

V. LA DEFENSA DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE

La jurisprudencia romana protege el ejercicio del derecho de servidumbre mediante acciones in rem y acciones posesorias, que consisten en interdictos particulares aplicables a determinadas servidumbres.

En cuanto al primer aspecto, la acción más conocida durante el derecho justiniano es la "acción confesoria" (actio confessoriae). Esta acción se concede al titular del fundo dominante para ser ejercida contra el propietario o poseedor del fundo sirviente, y aun contra un tercero, con el fin de rechazar cualquier ataque o menoscabo que impida el ejercicio del derecho de servidumbre. La "acción confesoria" persigue el reconocimiento por parte del actor ante el juez del ejercicio del derecho de servidumbre perturbado por el demandado. El actor tiene como carga probar la titularidad del fundo dominante, la existencia de la servidumbre y la lesión sufrida en su derecho. La sentencia persigue la restitución del ejercicio dañado y la reparación de los daños ocasionados⁽²⁰⁾.

Respecto de la protección interdictal de las servidumbres, ésta consiste en lo siguiente: a) Interdicto destinado a que el titular de una servidumbre de paso haga valer su derecho cuando se le prohíba reparar el terreno por donde debe pasar (itinere actusque reficiendo). b) Interdicto a favor del titular de una servidumbre de acueducto al cual no se le permite limpiar y mantener en buen estado la acequia en la cual circula el agua (interdictum de rivis reficiendis). c) Interdicto destinado a enervar la prohibición contra el titular de la servidumbre de cloaca para impedirle mantenerla en buen estado (interdictum de cloacis). d) Interdicto cuyo objeto es detener la violencia por la cual se impide el ejercicio de su derecho (interdictum de fonte reficiendo). e) Interdicto a efectos de proteger la servidumbre de agua cuando una persona de modo cotidiano o en verano saca agua y luego se le impide hacerlo (interdictum de aqua quotidiana et festiva)⁽²¹⁾.

VI. LAS SERVIDUMBRES PERSONALES

Las servidumbres personales se configuran cuando se otorga a una persona distinta del propietario el uso y provecho de una cosa con carácter de derecho real. Este tipo de servidumbre tiene carácter personal, beneficia al titular y finaliza con la muerte de éste o con su "disminución de cabeza" (capitis deminutio). Estas servidumbres son el usufructo, el uso, la habitación y el operae servorum.

El usufructo es el derecho concedido a una persona de usar la cosa de otro (ius utendi) y percibir los frutos sin alterar su sustancia (ius fruendi), reteniendo el propietario de la cosa el derecho de

disposición (ius utendi)⁽²²⁾. Respecto de los frutos, sólo corresponden al usufructuario los considerados habituales, dado que aquellos que no lo son, pertenecen al propietario. El uso es el derecho concedido a una persona solamente de utilizar la cosa de otro (ius utendi) pero sin percibir ningún fruto⁽²³⁾. La habitación(habitatio) es el derecho concedido a una persona de habitar una casa ajena. Recién con Justiniano queda configurada la figura jurídica de la habitación, puesto que en el derecho clásico se la confundía con el uso y el usufructo⁽²⁴⁾. El "trabajo de los esclavos" (operare servorum) es el derecho de aprovecharse del trabajo de los esclavos ajenos. La jurisprudencia romana discrepa en cuanto a la naturaleza de este tipo de servidumbre, hasta que Justiniano decide que es un derecho real autónomo, aunque con semejanzas al uso (usus)⁽²⁵⁾.

VII. LOS DENOMINADOS "DERECHOS REALES PRETORIANOS"

El derecho honorario da forma a otros derechos reales que presentan todos los atributos de la propiedad, aunque con limitaciones, configurando una especie de dominio incompleto⁽²⁶⁾. Entre ellos podemos considerar, de un modo más o menos cronológico, el ius in agro vectigalis, la enfiteusis y la superficie. Es de destacar que éstos tienen como origen la gran extensión de tierras que Roma acumula, producto de las conquistas, con el fin de darles un destino útil al Estado y a los particulares.

1. El ius in agro vectigalis

Es el derecho real por el cual se les concede por largos plazos, casi a perpetuidad, a particulares tierras que pertenecen al Estado mediante el pago de un determinado canon anual (vectigal), generalmente en especie. Presenta la particularidad de que mientras se pague la renta puntualmente, el titular de este derecho no puede ser retirado de la tierra. En un principio se discute largamente la naturaleza jurídica del instituto, por cuanto, por un lado, se lo considera una especie de arrendamiento y, por el otro, un nuevo derecho real; esto es así, por cuanto en origen se encuentra protegido por "acciones personales", y más tarde el derecho honorario le concede "acciones reales", v.gr., la actio vectigali (similar a la reivindicatio), la "publiciana" y la "confesoria"⁽²⁷⁾.

2. La enfiteusis

Teniendo como fundamento el ius in agro vectigalis, aparece más tarde en la región oriental del imperio la enfiteusis, que consiste en un derecho real de uso y goce de un fundo perteneciente al erario público. La concesión es casi a perpetuidad y también mediante el pago de un canon anual. Los juristas clásicos discrepan sobre si se trata de una compraventa o de un arrendamiento, hasta que finalmente el emperador Zenón le pone fin, decidiendo que el derecho de enfiteusis tiene naturaleza propia⁽²⁸⁾. Finalmente, se concede al titular del derecho (enfiteuta) el ejercicio de los interdictos posesorios para protegerlo de aquellos que pretendieran adquirir por posesión la tierra sobre la que tiene el derecho de enfiteusis o contra aquellos que quieran hacer valer un derecho de servidumbre⁽²⁹⁾.

3. La superficie

Es el derecho real por el cual se permite a simples particulares levantar construcciones en terrenos públicos o privados, a cambio del pago de un canon. También se discute largamente respecto de su naturaleza jurídica. Se lo considera en principio dentro de los "derechos créditos", mas luego el derecho honorario crea un edicto especial de carácter real (interdictum de superficiebus). Finalmente, Justiniano le otorga una acción similar a la "reivindicación"⁽³⁰⁾. Debo añadir respecto de este instituto que el codificador Vélez Sarsfield no lo incluye en el Código Civil, lo cual ha sido enmendado por el actual Código, que lo contempla en los arts. 2114 a 2128.

VIII. DERECHOS REALES DE GARANTÍA

Son aquellos constituidos en favor del acreedor con el fin de asegurarle el cumplimiento por parte del deudor de la prestación debida. Tienen su origen también en el derecho honorario. Es el fin de la evolución de la idea de que el deudor debe cumplir hasta con su cuerpo la deuda que contrae, pasando al principio de que la garantía es su patrimonio y no su cuerpo. Como se advierte que esto último no es suficiente en todos los casos, el derecho honorario crea los denominados derechos reales de garantía, que son la fiducia, la prenda, la anticresis y la hipoteca.

1. La fiducia

Consiste en la entrega en propiedad al acreedor de una cosa que le pertenece al deudor mediante la mancipatio o la in iure cessio, con la finalidad de garantizarle al primero el pago de una deuda, acompañado por un "pacto de fiducia", por el cual el acreedor se compromete a transferirle nuevamente la propiedad de la misma cosa una vez percibido el crédito. El acreedor se convierte en verdadero propietario de la cosa, pudiendo ejercer la "acción de reivindicación" aun contra el deudor, y venderla para el caso de incumplimiento a los efectos de percibir su crédito⁽³¹⁾.

2. La prenda

Es la entrega de una cosa en garantía al acreedor por parte del deudor para garantizar el cumplimiento de la obligación contraída, pero, a diferencia de la fiducia, se hace en calidad de posesión y no de entrega de la propiedad. La cosa es retenida por el acreedor hasta que el deudor pague lo adeudado, y no puede utilizarla ni venderla, salvo autorización expresa del deudor. La prenda toma carácter de verdadera garantía real cuando el derecho pretoriano le brinda la protección interdital al acreedor pignoraticio, autorizándolo a rechazar el ataque de terceros, y también del mismo deudor prendario que tuviese como fin afectarlo en su posesión.

3. La anticresis

Es el pacto por el cual el deudor faculta al acreedor prendario a que utilice el bien dado en garantía, como así también que los frutos obtenidos los aplique al pago de los intereses y, una vez satisfechos éstos, al capital. Discrepan los juristas clásicos respecto de si se debe considerarla

dentro de los derechos reales de garantía o dentro de los pactos contractuales. Entiendo que por el modo contractual comercial romano, bien se puede considerar a la anticresis dentro de los derechos reales de garantía⁽³²⁾.

4. La hipoteca

Es el fin de la evolución de los derechos reales de garantía. Consiste en la afectación de un bien determinado en garantía del cumplimiento de una deuda. He dicho anteriormente que la garantía del acreedor es el patrimonio del deudor, pero para el caso de insolvencia se vende en bloque todo el patrimonio, diluyéndose dicha garantía; por dicha razón se crea la hipoteca, que es un derecho real específico sobre el objeto que garantiza el crédito, otorgándole un derecho de preferencia al acreedor. Evidentemente, la hipoteca tiene un carácter accesorio, por cuanto presupone siempre una obligación a la que debe garantizar su cumplimiento⁽³³⁾. La hipoteca se constituye mediante pacto, testamento, resolución judicial y por ley⁽³⁴⁾. Puede ser objeto de la hipoteca toda cosa que se encuentre en el comercio, recayendo sobre toda cosa corporal, ya sea mueble o inmueble; pero, en aplicación del principio que lo que se grava es el derecho real y no el objeto sobre el que éste recae, en la práctica se admite que pueda tener por objeto cosas incorpóreas como el usufructo, las servidumbres y la superficie⁽³⁵⁾. Por fin, la hipoteca se extingue por diversas causas, como, en relación con la deuda que garantiza, pago, novación, confusión, compensación, transacción, remisión de la deuda; además, por destrucción de la cosa gravada, renuncia a la garantía hipotecaria, prescripción, etc.⁽³⁶⁾.

FRANJA
MORADA

Capítulo XXII - Obligaciones

CAPÍTULO XXII - OBLIGACIONES⁽¹⁾

La obligación (obligatio) es el vínculo jurídico por el cual una persona, llamada sujeto activo o acreedor, tiene el derecho a constreñir a otro, denominada sujeto pasivo o deudor, a realizar una determinada prestación que puede consistir en un dar (dare), en un hacer (facere), en un no hacer (non facere) o en una prestación (praestare).

Las obligaciones en Roma se desarrollan a medida que surgen distintas necesidades en la vida práctica, relativas especialmente a las relaciones económicas que se originan entre los hombres. En los primeros tiempos, la simple deuda no configura un deber de cumplir la prestación, ya que ello no se encuentra previsto legalmente. Esta situación provoca la creación de la institución conocida como nexum, por medio de la cual el sujeto pasivo queda sujeto a una situación de dependencia con respecto al acreedor y garantiza el cumplimiento de la obligación con su propia persona.

El nexum crea una situación similar al señorío que tiene el propietario de una cosa sobre ella o el pater familiae sobre los integrantes de su núcleo familiar. Si el deudor no cumple, por medio del procedimiento de la manus iniectio queda en una situación de esclavitud respecto del acreedor. En el año 326 a.C., con motivo de los grandes abusos cometidos por los patricios, se sanciona la lex Poetelia Papiria, por la cual queda abolido el nexum al establecer que no se puede encadenar, vender o dar muerte al deudor, determinando, además, que éste responde únicamente con sus bienes y no con su propia persona por las obligaciones contraídas⁽²⁾. Así, el vínculo físico que une al acreedor con el deudor se convierte en un nexo jurídico dirigido hacia los bienes del deudor.

A fines de la República, por obra del pretor Rutilio Ruffo, nace la institución conocida con el nombre de bonorum venditio, que consiste en la venta en masa de los bienes del deudor para adjudicarlos al comprador que oferte la mayor suma, y así satisfacer los créditos reclamados. Luego, ésta es reemplazada por la denominada distractio bonorum, por medio de la cual se venden en detalle los bienes del deudor.

I. ELEMENTOS

Son los sujetos, el vínculo y el objeto.

1. Los sujetos

Son de dos clases, el sujeto activo (acreedor) y el sujeto pasivo (deudor). El acreedor, ya sea persona física o jurídica, es aquel que tiene derecho a exigir el cumplimiento de la prestación; y el deudor (ya sea persona física o jurídica) es aquel que está constreñido a satisfacerla, aun contra su voluntad⁽³⁾. Cada uno de estos roles se encuentra perfectamente determinado, conociéndose con certeza desde el inicio mismo de la obligación quién es el acreedor y quién el deudor.

2. Vínculo jurídico

Es la esencia de la obligación. Consiste en el deber que tiene el deudor de cumplir la prestación, haciéndose efectivo por medio del establecimiento de una sanción que tiene el efecto de compeler al deudor. Esto demuestra que el carácter esencial del vínculo jurídico es la coercibilidad, ya que si el deudor no cumple con la obligación que contrae, puede ser compelido judicialmente a que lo haga. En algunos casos, consiste en una "acción" (actio), que permite exigir coactivamente el cumplimiento de la obligación y, en otros, en la posibilidad de oponer una "excepción" (exceptio) ante la pretensión de quien cumple y luego manifiesta haber realizado un pago indebido.

3. Objeto

Es la prestación propiamente dicha y consiste, básicamente, en realizar una conducta, positiva o negativa. Ello incluye, en sentido amplio, cualquier conducta humana que sea susceptible de constituir el objeto de un derecho. El objeto debe cumplir los siguientes requisitos⁽⁴⁾, a saber: a) Debe ser física y jurídicamente posible; si el objeto es imposible, la obligación carece de relevancia jurídica. b) Lícito, es decir, debe ser acorde a la ley, la moral y las buenas costumbres. c) Determinado o por lo menos determinable. Desde el nacimiento de la obligación, debe saberse en qué consiste el objeto de la prestación o, al menos, ser susceptible de determinación. Incluso esto último puede depender del arbitrio de una de las partes o de un tercero. d) Contenido patrimonial. La prestación debe ser valuable en dinero.

Las fuentes romanas hablan de "dar" (dare), hacer (facere) o prestación (praestare)⁽⁵⁾.

Dare. Estas prestaciones tienen por objeto el traspaso al acreedor de la propiedad de la cosa o de un derecho real sobre ella. Comprende también, en un sentido más amplio, la entrega de una cosa o una prestación cualquiera.

Facere. La prestación consiste en un acto o hecho del hombre que no implique un dare e incluso puede involucrar una abstención (no hacer).

Praestare: Comprende la entrega de una cosa, pero con un fin diferente que el de transferir su propiedad o constituir sobre ella algún derecho real.

II. FUENTES

Entiendo por fuente de la obligación todo hecho jurídico que la origina. Los juristas romanos han discrepado en cuanto a ellas, advirtiéndose la siguiente evolución. Gayo ofrece una clasificación de las fuentes de las obligaciones (causae obligationum) de carácter bipartito⁽⁶⁾. Para éste, solamente pueden originar obligaciones los contratos y los delitos⁽⁷⁾. Mas es el mismo jurista quien advierte que la indicada clasificación es incompleta, por cuanto omite "una gran gama de causas generadoras de obligaciones que no se pueden tipificar como contratos ni como delitos"⁽⁸⁾. Señalan Peña Guzmán y Argüello al respecto que "el propio Gayo, en una obra cuya autoría se le adjudica⁽⁹⁾, completa su anterior división agregando otra fuente más bajo el rótulo de 'varias especies de causa' (ex variis causarum figuris)"⁽¹⁰⁾, convirtiendo la clasificación, entonces, en tripartita. Posteriormente, Modestino, quien también lleva a cabo una clasificación con respecto a las fuentes de las obligaciones, señala que "se contraen por una cosa, con palabras, o al mismo tiempo por ambas, o por el consentimiento o por la ley o por el derecho honorario o por necesidad o por delito"⁽¹¹⁾. Si bien se considera que esta clasificación, como tal, es un tanto desorganizada, tiene el mérito de ser la primera que incluye a la ley⁽¹²⁾. Es finalmente Justiniano quien adopta la siguiente clasificación cuatripartita⁽¹³⁾ respecto del tema, estableciendo que "las obligaciones nacen de un contrato o de un cuasicontrato o de un delito o de un cuasidelito"⁽¹⁴⁾.

III. SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

He señalado en distintas oportunidades que los juristas romanos clásicos han sido poco afectos a las teorías y clasificaciones, y que su labor se ha centrado fundamentalmente en dilucidar el "caso concreto" sometido a análisis. Por tal motivo se dice atinadamente que el derecho romano es casuístico. Lo mismo acontece en materia de obligaciones, donde tampoco se llega a crear una teoría general, y menos aún a formular una clasificación de ellas. Por dicho motivo considero oportuno no extenderme en profundidad en dicha consideración, dado que no son producto genuino de la jurisprudencia romana, siendo sistematizaciones de la doctrina moderna y, por ende, deberán ser estudiadas según las pautas brindadas por la asignatura curricular respectiva.

Sin perjuicio de lo expuesto, he de efectuar una breve referencia a ellas: a) Obligaciones del derecho civil y del derecho de gentes. Las primeras corresponden a los ciudadanos romanos en virtud del *ius civile*; y las segundas, por imperio del *ius gentium*, a todos los pueblos, es decir, tanto a los ciudadanos romanos como a los peregrinos⁽¹⁵⁾. b) Obligaciones civiles y honorarias. Las primeras son las que tienen fundamento en el *ius civile*; y las segundas, en el derecho pretoriano⁽¹⁶⁾. c) Obligaciones civiles y naturales. Se refieren al vínculo de la obligación. Las primeras son aquellas que se encuentran provistas de una acción que le permite al acreedor constreñir judicialmente al deudor que no cumple. Por el contrario, las segundas son las que carecen de acción alguna⁽¹⁷⁾. d) Obligaciones transitorias y continuas. Guardan relación con la duración de la actividad del deudor; así, las primeras son aquellas obligaciones en las que esta actividad se encuentra limitada de un modo pasajero; v.gr., las obligaciones del mutuario; y las segundas, son aquellas en las que la actividad se halla de modo permanente; por ejemplo, la obligación de no levantar edificios a partir de una determinada altura. e) Obligaciones simples y compuestas. Son simples las que contienen una sola prestación y, por el contrario, compuestas las que tienen varias. f) Obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales. Las primeras son las susceptibles de apreciación pecuniaria, y las segundas, las que no lo pueden ser; v.gr., las que derivan de la curatela. g) Obligaciones divisibles e indivisibles. Guardan relación con la divisibilidad de las cosas y, por ende, con la prestación misma. Las primeras son las que se pueden dividir sin desaparecer, y las segundas, por el contrario, no pueden ser divididas si no fenecen. h) Obligaciones determinadas e indeterminadas. Las primeras son aquellas cuyo objeto se encuentra perfectamente individualizado, mientras que las segundas no. i) Obligaciones genéricas y de cantidad. Las obligaciones de género son aquellas que tienen por objeto cosas que presentan determinadas cualidades naturales o económicas que les permiten ser sustituidas una por otra de la misma especie. Por su parte, las de cantidad son las que tienen por objeto la cantidad de cosas fungibles, que se determinan por su peso, número o medida. j) Obligaciones alternativas y facultativas. Las obligaciones alternativas son las que tienen por objeto una cosa de varias prestaciones independientes y distintas, correspondiéndole al deudor su elección de cumplimiento, salvo pacto en contrario. Las facultativas son las que, a pesar de tener un único objeto, se le permiten al deudor cumplir con otra prestación distinta. k) Obligaciones de sujeto fijo y obligaciones de sujeto variable. Las primeras son las obligaciones en las que el acreedor y el deudor son conocidos durante toda la relación creditoria, es decir, desde que se origina hasta que se extingue, mientras que las segundas no lo son, ya sea por que no se conocen al principio o cambian durante la relación, hasta que finaliza. l) Obligaciones correales. Son las obligaciones en las que existe pluralidad de acreedores o deudores, de modo tal que cualquiera de los acreedores puede exigir de cualquiera de los deudores el cumplimiento íntegro de la prestación adeudada. Esto puede acontecer por pacto previo o por disposición de la ley.

IV. EFECTOS

El efecto principal consiste en el cumplimiento de la obligación; es decir, el pago. Éste se debe analizar respecto de: 1) los sujetos (acreedor y deudor); 2) contenido de la prestación; 3) lugar del cumplimiento; 4) tiempo del cumplimiento.

1. Desde el punto de vista de los sujetos

Las consecuencias de una obligación, en principio, alcanzan al acreedor y al deudor.

El sujeto activo o acreedor es aquel que a través del vínculo jurídico constriñe al deudor al cumplimiento de la prestación, concediéndole los medios coercitivos suficientes para obtener el pago del crédito y, en caso de que ello no resulte posible, se encuentra facultado a exigir los daños y perjuicios pertinentes.

Para el deudor, el cumplimiento de la prestación extingue el vínculo jurídico existente y también las garantías y refuerzos accesorios que se han establecido a favor del acreedor, facultándolo además a repeler cualquier intento del acreedor a exigir nuevamente el cumplimiento de la deuda.

2. Respecto del contenido de la prestación

El deudor y el acreedor no deben ser obligados a entregar o recibir una cosa distinta de aquella que constituye el objeto de la obligación. El deudor debe cumplir íntegramente y no queda liberado si lo hace parcialmente o de una manera distinta a la pactada, salvo que exista conformidad expresa del acreedor. Hay excepciones a esta regla; por ejemplo, la "dación en pago" (*beneficium dationis in solutum*), en la que se entrega un objeto distinto al comprometido, ya que el deudor solvente que no cuenta con dinero o en efectos muebles, o no encuentra comprador para los inmuebles, puede obligar al acreedor a recibir dichos bienes raíces, cuyo valor es estimado oficialmente. Otra excepción es el "beneficio de competencia" (*beneficium competentiae*), el cual importa un pago parcial de la obligación, ya que el deudor que se vuelve insolvente tiene el derecho a no ser condenado a pagar más de lo que de buena fe puede abonar hasta tanto mejore su fortuna, pudiendo disponer entonces de lo necesario para vivir⁽¹⁸⁾. Esto último sólo rige en casos muy específicos, v.gr., cuando el padre le adeuda a su hijo o el patrón es deudor de su liberto⁽¹⁹⁾. El mencionado beneficio responde a cuestiones de equidad y no extingue el resto del crédito, sino que éste subsiste, a diferencia de la dación en pago. Además, la dación en pago puede ser voluntaria, es decir que el acreedor voluntariamente acepta extinguir la obligación a través del cumplimiento de una prestación distinta de la pactada.

3. El lugar del cumplimiento

Debe estarse a aquello que las partes han convenido directa o indirectamente y el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación en un lugar distinto de aquel que se ha fijado. En los casos en que no se determina el lugar del cumplimiento, hay distintas posibilidades, de acuerdo con la naturaleza de la obligación: a) En los casos de cosas inciertas o fungibles, el cumplimiento debe verificarse en el domicilio del deudor, porque es el lugar donde el acreedor puede exigir judicialmente su cumplimiento (*forum domicilii*). b) En los casos en que la prestación consiste en la entrega de un bien inmueble u otra cosa cierta, el lugar del cumplimiento es aquel en el cual se encuentran los bienes (*forum rei*)⁽²⁰⁾.

4. En cuanto al tiempo en que debe verificarse el pago

Depende de lo pactado entre las partes. Si no se ha fijado un plazo, opera en favor del acreedor, ya que éste puede exigir el cumplimiento en cualquier momento en virtud de la regla que estipula que la obligación es exigible desde que nace. Si hay un plazo estipulado, esto juega a favor del deudor y la obligación se torna exigible a su vencimiento⁽²¹⁾, aunque puede pagarlo antes, si así lo quiere. Si la obligación se encuentra sujeta a una condición suspensiva, su cumplimiento no puede tener lugar antes de que ella se verifique, ya que hasta ese momento se considera que la obligación no existe. Si la condición es resolutoria, la ejecución debe cumplirse en cualquier momento, antes de que se consume.

V. MORA. REQUISITOS

La mora es el incumplimiento de la obligación por parte del deudor a su debido tiempo. También incurre en mora el acreedor cuando no acepta la prestación que le es debida. En consecuencia, median dos tipos de mora, la del deudor y la del acreedor.

El derecho quiritarario no reconoce otros contratos más que los llamados "de derecho estricto" (stricti iuris) y se entiende que si el acreedor ejecuta la obligación fuera de término, o la prestación se torna imposible, el deudor queda liberado sin ningún tipo de sanción. Luego, con la vigencia del procedimiento denominado "acciones de la ley" (legis actiones), aparece el concepto de "obligaciones perpetuas" (perpetuatio obligationis), por medio del cual la obligación del deudor persiste aunque la prestación desaparezca por caso fortuito. Cuando adquieren importancia los contratos de buena fe, comienza a admitirse que el deudor debe indemnizar al acreedor con el objeto de que éste se encuentre en la misma situación que aquella que tendría si la obligación se hubiera cumplido en el lapso convenido.

Se deben cumplir los siguientes requisitos para la constitución de la mora, a saber: a) La obligación debe ser válida, es decir que no debe ser contraria a las leyes y las buenas costumbres y no debe tener vicios. b) La obligación debe ser exigible; ello implica que debe estar dotada de una acción a la cual no se le pueda oponer ninguna excepción, y además no debe estar sujeta a condición o plazo y, si lo está, éstos deben haberse cumplido. Además, no debe tratarse de una obligación natural⁽²²⁾. c) El retardo debe ser injusto, no debe haber justificación. d) El retraso debe ser imputable al deudor por dolo o culpa, es decir que no debe existir caso fortuito o fuerza mayor, ni tampoco culpa del acreedor. e) El acreedor debe haber exigido el pago mediante una interpelación. Ella consiste en un acto judicial o extrajudicial verificado por el acreedor con el objeto de lograr el cumplimiento de la prestación. Estaintimación, que origina la mora ex persona, no exige ningún formalismo y no es necesario que se efectúe por el acreedor en persona⁽²³⁾. También existe la mora ex re o "automática" en aquellos casos en que las partes estipulan que el solo vencimiento del tiempo convenido constituye en mora al deudor⁽²⁴⁾. La mora ex re también se produce cuando el deudor se ausentainjustificadamente sin designar representante; cuando la obligación tiene origen en una posesión de mala fe o violenta, o proviene de un delito; cuando el retardo en el cumplimiento equivale a la completa inejecución de la obligación o cuando el heredero no cumple a su debido tiempo con los legados o fideicomisos, dispuestos a favor de las iglesias o fundaciones pías⁽²⁵⁾.

Por otra parte, si el acreedor realiza actos u omisiones que le impiden al deudor cumplir con su obligación, el primero de los nombrados cae en mora. El deudor debe demostrar su intención de cumplir, realizando actos positivos⁽²⁶⁾. Hay mora por parte del acreedor cuando éste se rehúsa arbitrariamente a aceptar la prestación; cuando no se encuentra en el lugar convenido para su ejecución o no quiere realizar aquellos actos que resultan indispensables para su cumplimiento; también si se ausenta sin justa causa sin designar representante o cuando no concurre al acto en el cual va a llevarse a cabo la medición o peso de los objetos que debe recibir⁽²⁷⁾.

VI. EFECTOS DE LA MORA DEL DEUDOR Y DEL ACREEDOR

El deudor constituido en mora tiene la obligación de responder por los daños y perjuicios que su retardo le causa al acreedor, debiéndolo colocar en la misma situación en que se hubiera encontrado si él hubiera cumplido a tiempo. También la mora provoca un efecto especial, ya que perpetúa la obligación (perpetuatio obligationis). Así, los riesgos a los que la cosa objeto de la prestación se halla expuesta quedan a su cargo, y si ella se pierde por caso fortuito, debe pagar su valor estimado. Además, el acreedor se encuentra facultado para exigir los frutos civiles o naturales desde el momento de la interpelación, y si la obligación implica entregar una suma de dinero, los intereses se computan desde el día de la mora (usurae ex mora)⁽²⁸⁾.

El acreedor que queda constituido en mora se hace responsable en forma inmediata de todos aquellos perjuicios derivados de sus actos u omisiones que le impidan al deudor cumplir con su obligación en el tiempo debido. Es decir que el deudor se libera de los riesgos, salvo cuando de su parte hay dolo o culpa grave. Esta mora suspende el curso de los intereses y quedan en su cabeza los riesgos derivados de la pérdida de la cosa por caso fortuito, pudiendo el deudor oponer la "excepción de dolo" (exceptio doli) si el acreedor intenta exigir el cumplimiento de la prestación⁽²⁹⁾. Además, el deudor puede abandonar la cosa que debe entregar ante la mora del acreedor, y este último tiene el deber de restituirle los gastos que hubiera realizado para conservar la cosa después de la mora.

Justiniano dispone que cuando la obligación consiste en entregar una suma de dinero, el deudor puede depositarlo in publico (obsignatio), introduciendo así el principio del pago por consignación que extingue de pleno derecho (ipso iure) la obligación⁽³⁰⁾. Además, los intereses moratorios cesan ante la mora del acreedor y, luego de la consignación, ocurre lo mismo con los intereses pactados.

La mora del deudor cesa con el cumplimiento de la obligación o con un ofrecimiento válido de pago, mientras que ello ocurre con la del acreedor cuando éste acepta directamente el pago o cuando manifiesta expresamente que está dispuesto a recibirlo. También la mora culmina por acuerdo expreso o tácito de ambas partes y queda purgada cuando los dos sujetos de la relación incurrir en mora, operando entonces una especie de compensación, excepto cuando la mora de uno de los dos ha cesado⁽³¹⁾.

VII. INCUMPLIMIENTO

Esta situación se origina cuando el deudor no satisface la prestación a la cual se ha obligado. Este incumplimiento puede provenir de causas que le son imputables, como el dolo y la culpa, o puede deberse a sucesos respecto de los cuales no tiene ninguna responsabilidad, como el caso fortuito y la fuerza mayor.

1. Dolo

Consiste en la actitud voluntaria y maliciosa del deudor con el propósito de no cumplir su obligación y provocar un daño al acreedor. Es necesario que exista una relación de causalidad entre la conducta del deudor y la inejecución. El deudor debe llevar a cabo una conducta, positiva o negativa, evidenciando la intención o propósito deliberado de realizarla y generar así un perjuicio económico al acreedor. Además, este perjuicio necesariamente debe derivar del incumplimiento de la obligación⁽³²⁾. Se vislumbra así que no pueden incurrir en mora por dolo, por encontrarse exentas de responsabilidad aquellas personas que carecen de voluntad, por ejemplo, los dementes y los imputéberes.

Si se trata de una obligación de "dar" (dare), el deudor puede ser compelido a entregar la cosa por medio de violencia, quedando además obligado a pagar una suma de dinero por haber lesionado los intereses del acreedor.

El dolo no puede presumirse, sino que debe ser acabadamente probado por el damnificado, debido a sus graves implicancias. Cualquier convención que celebren las partes destinada a eliminar

la responsabilidad en caso de dolo, v.gr., el "pacto de no hacer valer el dolo" (pacto de non petendo dolo), carece de relevancia jurídica por ser contrario a las buenas costumbres, al orden público y a la moral. Pero si el acreedor quiere, puede pactar con el deudor sobre las consecuencias que implica actuar con dolo luego de que éste se consuma y, entonces, negociar sobre las pérdidas e intereses debidos, e incluso llegar a condonarlos.

El dolo del deudor no se atenúa en caso de que el acreedor actúe con culpa, porque la obligación de resarcir que ambas conductas originan es distinta y no pueden compensarse. La obligación, en caso de dolo, aún persiste a pesar de que el acreedor con su actitud haga imposible la prestación y, en ese caso, ella se traduce en una obligación pecuniaria tendiente al resarcimiento del daño causado al acreedor⁽³³⁾.

El acreedor también incurre en dolo si realiza actos tendientes a dificultarle al deudor el cumplimiento de la prestación, situación que se rige por los mismos principios.

2. Culpa

El deudor incurre en culpa cuando le ocasiona un daño al acreedor al impedir el cumplimiento de la obligación por falta de cuidado o por negligencia. En este caso no existe intención de dañar, sino que media por parte del deudor una falta de atención para el verdadero cumplimiento de la prestación. Entonces, la culpa existe cuando media falta de cuidado, desidia, negligencia, por parte del deudor. Probablemente, el concepto de culpa se origina en el campo de los delitos privados como consecuencia de la regulación establecida por la lex Aquilia, pasando posteriormente a la esfera contractual.

Los comentaristas, entonces, distinguen la culpa extracontractual de la contractual, incurriendo en esta última quien incumple una obligación. Los principios que regulan la culpa son consagrados en la compilación justineana, ya que se establece un sistema de responsabilidades en el cual se determinan distintas gradaciones, según la mayor o menor gravedad. Así, se distingue la culpa grave o magna (culpa lata) de la culpa leve (culpa levis). Esta última comprende la culpa in abstracto y la culpa in concreto. La culpa grave es definida por Ulpiano como "demasiada negligencia, esto es, no entender lo que todos entienden"⁽³⁴⁾. Implica un descuido extremo que hace que se parezca en sus efectos al dolo y no puede ser dispensada por acuerdo de las partes⁽³⁵⁾.

La culpa leve se configura cuando el deudor no ha puesto la debida diligencia que todo hombre normal debe prestar a los negocios en los que interviene. Los comentaristas distinguen, como ya señalara precedentemente, entre la culpa in abstracto, que se origina cuando el deudor omite los cuidados de un buen padre de familia, y la culpa in concreto, que está dada por la inobservancia del deudor de la diligencia que suele tener en sus propios negocios.

Algunos autores, tomando como punto de partida un texto de Ulpiano, consideran otra categoría o gradación, llamada "culpa levísima", entendiéndola como aquel caso en que no se ha puesto un cuidado extremadamente diligente, cuya previsión sólo puede ser concebida por individuos señaladamente inteligentes⁽³⁶⁾.

Las consecuencias de la culpa no son reguladas de la misma manera en las distintas épocas de la vida jurídica romana. Hasta el período de la jurisprudencia clásica, el deudor sólo responde cuando el incumplimiento de la obligación deriva de una conducta dolosa. Cuando los contratos consensuales se incorporan al ius civile, la jurisprudencia comienza a establecer que los deudores no sólo deben responder por sus conductas intencionales, sino también por su falta de diligencia. Luego, comienza a tenerse en cuenta el principio de utilidad que el negocio puede producirle a las partes (utilitas contrahentium) y, en consecuencia, se establece como norma general que el deudor sólo responde de la culpa grave cuando la relación se celebra en provecho exclusivo del acreedor, y por culpa leve cuando el negocio se realiza únicamente en su propio beneficio o en el de ambas partes⁽³⁷⁾.

Asimismo, se establecen excepciones a estos principios, ya sea responsabilizando al deudor por la culpa levis, aun cuando el negocio se celebra en beneficio exclusivo del acreedor, o eximiendo de responsabilidad al deudor a pesar de que la relación se constituye en su provecho. Un ejemplo del primer supuesto es el caso del mandatario o gestor; también el depositario en caso de depósito necesario, y los tutores y curadores, quienes responden de toda culpa⁽³⁸⁾. Por otra parte, como

ejemplo del segundo supuesto se encuentra el agrimensor que percibe una remuneración por sus servicios; el marido que recibe la dote de la mujer y los socios o comuneros, quienes no responden de la culpa leve porque se supone que han obrado de la mejor manera posible, ya que tienen un interés en el negocio⁽³⁹⁾.

La "custodia" es un supuesto en el cual la falta de diligencia origina responsabilidad por culpa. Por lo general, ésta se relaciona con los cuidados que debe tener un buen padre de familia en la conservación de los bienes ajenos y se evidencia en aquellos supuestos en que el deudor debe responder de la culpa in abstracto⁽⁴⁰⁾. Sin embargo, en algunos casos no se responde en caso de culpa, tal como sucede en los supuestos del naviero, del posadero y del dueño de estado por el daño o robo de las cosas confiadas a su guarda o a la de sus dependientes⁽⁴¹⁾.

3. Caso fortuito

No hay una conducta intencional o falta de diligencia por parte del deudor, sino que ocurre un evento que no le es imputable porque resulta imprevisible. Ulpiano considera que "ninguna humana inteligencia puede prever los casos fortuitos"⁽⁴²⁾. Exime de responsabilidad al deudor, salvo convención en contrario⁽⁴³⁾. Algunos ejemplos son las inundaciones, naufragios, terremotos, que una res cualquiera se convierta en res divini iuris, o una guerra. Excepciones a esta regla constituyen los casos del capitán del buque, del hotelero o del mesonero, quienes son responsables de los objetos dejados bajo su guarda, aun cuando ellos se pierdan por un hecho no imputable o cuando el caso fortuito sea consecuencia del dolo o culpa del acreedor⁽⁴⁴⁾.

El derecho romano establece el principio que consagra que las cosas se pierden para el acreedor (res perit creditoris). Esta regla se aplica rigurosamente⁽⁴⁵⁾. Pero al mismo tiempo se entiende que es el acreedor quien se beneficia por el aumento de valor o cualquier otro acrecentamiento que sufra la cosa en el lapso que media entre el momento en que se contrajo la obligación y su cumplimiento, comprendiendo no sólo los frutos, sino todas las otras accesiones que no provienen de algún hecho del deudor⁽⁴⁶⁾.

4. Fuerza mayor

Es todo aquel acontecimiento que, aunque previsto, no se ha podido evitar. Se aplican todas las consideraciones expuestas para el caso fortuito.

VIII. EFECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de la obligación por dolo o culpa del deudor genera para el acreedor el derecho a una indemnización pecuniaria por los daños y perjuicios sufridos, que pueden definirse como daño emergente y lucro cesante. Si bien esta terminología es netamente moderna, los conceptos ya existen en el derecho romano.

1. Daño emergente

Puede ser definido como la disminución real del patrimonio del acreedor que acaece en virtud del incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Su determinación en el derecho romano resulta más precisa que la definición de lucro cesante. En un principio se considera que cuando no hay una verdadera pérdida patrimonial tampoco hay lugar a una indemnización. Pero luego la legislación romana completa esta noción con el concepto de *lucrum cessans*, ampliando el resarcimiento no sólo al perjuicio positivo que el acreedor experimenta a raíz del incumplimiento, sino también a las ganancias frustradas⁽⁴⁷⁾. Estos conceptos tienen como objetivo una reparación integral, que coloque al acreedor en la misma situación en que se hubiera encontrado si la obligación se hubiera cumplido en su debido tiempo.

2. Lucro cesante

Consiste en la privación de una ganancia o utilidad que el acreedor ha dejado de percibir. Es necesario valorar los daños e intereses que debe abonar el deudor en concepto de indemnización. La legislación romana dispone que la determinación de su valor queda librada al arbitrio judicial o, en determinados casos, a la estimación efectuada por el acreedor.

Cuando la determinación la realiza el juez, éste debe tener en cuenta el valor real de la prestación no realizada y lo que ella significa para el acreedor. La discrecionalidad varía desde la fijación del valor común de la cosa (*verum rei pretio*) hasta una estimación amplia que comprende todas las consecuencias desventajosas para el acreedor derivadas del incumplimiento de la obligación (*id quod interest*). El derecho justinianeo establece que, tratándose del incumplimiento de obligaciones que tienen por objeto prestaciones de cantidad o de cosa cierta, la valoración del daño no debe resultar superior al doble de lo que importa la prestación⁽⁴⁸⁾.

Si es el acreedor quien efectúa la estimación, éste debe afirmar bajo juramento que ella es exacta (*in litem iurare*). A fin de evitar abusos, el derecho romano le otorga al juez la facultad de fijar de antemano un máximo o reducir la indemnización a un monto menor. Esta facultad del acreedor, en un principio, se reserva para aquellos casos en que el deudor se niega de mala fe a exhibir la cosa o restituirla, imposibilitando así su exacta valoración. En el derecho nuevo, esta facultad se extiende a los supuestos de inejecución de la obligación provocada por dolo, falta grave o contumacia del deudor⁽⁴⁹⁾.

La valuación también puede quedar sujeta al arbitrio de las partes cuando éstas incluyen en el contrato una cláusula penal que fija la indemnización de antemano para el caso del incumplimiento de la obligación, usando para este fin el contrato verbal de *stipulatio*. La cláusula penal exime al acreedor de las dificultades propias de probar los perjuicios ocasionados por la inejecución de la obligación y suple la apreciación judicial del valor de los daños e intereses⁽⁵⁰⁾.

IX. EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

Los principales modos de extinción de las obligaciones son: pago, novación, confusión, compensación, transacción y prescripción liberatoria. También encontramos en la jurisprudencia romana otros modos de extinción de las obligaciones, v.gr., la pérdida de la cosa debida, el mutuo desistimiento de las partes, el concurso de causas lucrativas, etc. Empero por razones prácticas sólo trataré las indicadas en primer término.

1. Pago

El pago (solutio) consiste en el cumplimiento de la obligación. Es el principal efecto que ésta persigue, y el modo habitual de su extinción. El pago en Roma no sólo es entregar una suma de dinero sino cumplir con la prestación debida, que puede ser la entrega de una cosa, o la realización de un hecho, o su abstención⁽⁵¹⁾. En consecuencia, siendo el pago el efecto normal de la obligación se aplican las consideraciones efectuadas respecto del cumplimiento de la prestación, es decir, sujetos intervinientes, prestación debida, lugar y tiempo pautados⁽⁵²⁾, remitiendo a lo expuesto oportunamente.

2. Novación

La novación (novatio) es el cambio o sustitución de una obligación por otra, de tal modo que la primera queda plenamente extinguida y en su reemplazo se constituye una nueva. Ulpiano la define como la "transfusión y traslación de una deuda anterior a otra obligación, esto es, cuando por virtud de otra causa precedente se constituyó una nueva, de modo que se extingue la primera"⁽⁵³⁾.

El requisito primordial de la novación es la intención de querer cambiar una obligación por otra (animus novandi), por la cual se extingue la primera originando una segunda. Sostiene Louzán de Solimano⁽⁵⁴⁾ que también es necesario, para llevarse a cabo la novación, el empleo de las formas exigidas por el derecho civil; y que la obligación resultante se diferencie de la antigua por un elemento nuevo⁽⁵⁵⁾. Finalmente, he de añadir que la novación origina la extinción de pleno derecho de la primera obligación con todos sus accesorios, produciendo una nueva, distinta de la anterior.

FRANJA MODADA

3. Compensación

La compensación (compensatio) de acuerdo con Modestino es "la contribución de una deuda y de un crédito entre sí"⁽⁵⁶⁾. Se origina cuando el deudor opone al acreedor un crédito que tiene a su vez contra el primero. Con la compensación se extingue la obligación si ambas deudas son iguales, y en el caso de disparidad se extingue hasta el importe de la menor, quedando subsistente la obligación por el saldo. El instituto de la compensación tiene origen eminentemente procesal porque se aplica mediante la interposición de excepciones, y luego tras el curso de la evolución del derecho romano varía en la consideración de los requisitos a tener en cuenta para su aplicación"⁽⁵⁷⁾. Finalmente Justiniano dispone que para que se aplique la compensación debe tratarse de deudas válidas, líquidas y exigibles, que los objetos sean de la misma especie, y que se trate de idénticos sujetos⁽⁵⁸⁾.

4. Confusión

La confusión (confusio) se origina cuando en una misma persona convergen la calidad de acreedor y deudor, produciendo la extinción de pleno derecho de la obligación como si fuera un pago, pero hay que tener en cuenta que si por cualquier causa desaparece el motivo que origina la confusión la obligación renace con toda su fuerza en virtud de que se trata de una imposibilidad de ejecución (nadie puede accionar contra sí mismo) más que un modo de extinción propiamente dicho⁽⁵⁹⁾.

5. Transacción

La transacción (transactio) es la extinción de obligaciones litigiosas mediante concesiones, o renunciaciones, recíprocas, efectuadas de común acuerdo por las partes. Se trata de relaciones obligatorias dudosas, litigiosas, a las que las partes deciden poner fin mediante un acuerdo, lo cual implica que deben renunciar a una porción de sus pretensiones en modo recíproco⁽⁶⁰⁾.

6. Prescripción liberatoria

La prescripción liberatoria (praescriptio) es la extinción de la obligación por el transcurso de un determinado período de tiempo sin que el actor exija su cumplimiento. La jurisprudencia romana al respecto varía en cuanto a la consideración de los plazos. En principio, las acciones provenientes del derecho civil son perpetuas, o sea imprescriptibles; luego, el derecho honorario innova e incluye el plazo de un año respecto de ellas. Empero, no se puede afirmar que en la cuestión de los términos de prescripción exista cierta uniformidad entre los juristas romanos; hay disparidad de criterios, lo que de algún modo exige a Teodosio II, en el año 424, fijar el plazo de treinta años para la extinción de toda clase de acción con excepción de las que estuviesen sujetas a plazos especiales⁽⁶¹⁾.

X. DESARROLLO DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES EN PARTICULAR

Desarrollaré a continuación las fuentes que, como dijera ut supra, son el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito.

CAPÍTULO XXIII - CONTRATOS

El contrato es la fuente más importante y fecunda de las obligaciones y puede definirse como un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos dirigido a crear obligaciones. Si bien los romanos no efectúan una definición acabada del contrato, este término se aplica a aquellas convenciones reconocidas como obligatorias por encontrarse dotadas de una causa civil y provistas de una acción⁽¹⁾.

En el derecho romano no todo acuerdo de voluntades implica la celebración de un contrato, sino que sólo se le otorga tal calidad a aquellos convenios a los que la ley les atribuye el efecto de hacer nacer obligaciones civilmente exigibles, es decir, protegidas por una acción (actio). Los textos romanos utilizan expresiones que parecen tener un significado semejante, como "convención" (conventio), "pacto" (pactum) y "contrato" (contractus).

El antiguo ius civile no elabora una teoría general acerca de los contratos, sino que crea un catálogo de los distintos tiposexistentes. Lo que determina, para que una convención entre dos personas constituya un contrato, es la forma especial con que ella se celebra, otorgándose, entonces, prioridad a las solemnidades que la ley establece para su perfeccionamiento. Luego, comienza a contar con mayor relevancia el concurso de voluntades, hasta que finalmente ello se convierte en el elemento fundamental de todo contrato. En el derecho justinianeo se considera que el contrato es aquel acuerdo de voluntades capaz de constituir a una persona en deudora de otra y puede versar acerca de la creación, modificación o extinción de cualquier relación jurídica.

Recientemente, el romanista Di Pietro ha investigado en profundidad todo lo relacionado con "el tema del contrato" en Roma⁽²⁾. Señala el prestigioso autor que nexum, sponsio, stipulatio, "no eran propiamente contratos", sino que "lo relacionado con el 'contrato' tuvo su aparición con posterioridad"⁽³⁾. También coincide en afirmar que "no existió en el derecho romano una 'teoría general del contrato'; ésta se irá formando lentamente con la romanística posterior que, aprovechando ciertos rasgos propiamente romanos, alcanzará dicha sistematización generalizadora en el pensamiento jurídico moderno"⁽⁴⁾.

Los distintos tipos de contratos nacen en Roma al compás de las transformaciones políticas, económicas y sociales que experimenta la sociedad. A las figuras consagradas por el ius civile se agregan las que derivan del ius gentium.

El primer contrato que se conoce es el nexum, caracterizado por la rigidez en la solemnidad de aquellos actos que deben realizarse para su perfeccionamiento, tales como la balanza, el pesar el cobre y la presencia del librepens y los cinco testigos. Luego, entre los ciudadanos romanos comienza a emplearse con mayor frecuencia la sponsio, que consiste en la utilización de palabras sacramentales como: Spondes?, ante lo cual el obligado debe responder: Spondeo. Los no ciudadanos utilizan la stipulatio, ya que no requiere expresiones determinadas o sacramentales, pero sí que la pregunta y su correspondiente respuesta sean congruentes. Así, con la sponsio y la stipulatio, nacen los contratos verbales (verbis). Posteriormente comienzan a celebrarse contratos cuyo perfeccionamiento depende de las anotaciones realizadas en un registro, naciendo entonces los contratos literales (litteris).

Si bien en Roma los contratos mediante los cuales se acuerda la entrega de una cosa se celebran mediante el nexum, este tipo de operación se vuelve más frecuente cuando se admite que la simple tradición de la cosa es suficiente para originar una obligación civil, naciendo así los contratos reales (re). Finalmente, cuando la legislación romana convierte en elemento preponderante de los contratos al acuerdo de voluntades, comienza a aceptarse que ellos puedan perfeccionarse por el mero consentimiento de las partes, emergiendo los llamados contratos consensuales (solo consensu).

La legislación romana sólo le otorga, excepcionalmente, el valor de un contrato a la simple promesa, apartándose del principio que establece que para crear un contrato es necesario el acuerdo de voluntades, cuando ella ha sido hecha a favor de una res publica, ciudad o municipio, siempre que exista una causa justa o principio de ejecución o cuando se ha consagrado una cosa a la divinidad⁽⁵⁾.

I. SOBRE EL ORIGEN DEL TÉRMINO "CONTRATO"

Siguiendo a Di Pietro en su exhaustiva obra, debo señalar que "el vocablo contractus, como sustantivo en su forma nominativa, no figura en los primeros tiempos ni tampoco se lo conoce como un término abstracto jurídico en el sentido en que lo conocemos hoy. Su aparición es, en términos históricos relativos, más bien tardía"⁽⁶⁾. Es más, sostiene el romanista argentino que "lo que resulta un dato curioso y sorprendente es que el vocablo 'contrato' se encuentra absolutamente ausente en el Edicto del Pretor"⁽⁷⁾; y que "el 'término contractus se conforma a partir del verbo contrahere, el cual era muy usado en la lengua latina. Al igual que el término castellano 'contraer' (y también el 'contractar'), significa 'estrechar, constreñir una cosa con otra'"⁽⁸⁾.

El término "contrato" debe ser hallado después de desmenuzar la obra de Gayo, el pasaje en el Digesto de Labeón que cita a Ulpiano⁽⁹⁾, y de Justiniano, para arribar por fin a la definición de Teófilo en Paráfrasis de las Instituciones de Justiniano, que dice: "contrato es la convención y el consenso de dos o más sobre el mismo asunto, de manera que se constituya una obligación y uno se halle obligado respecto del otro"⁽¹⁰⁾. Posteriormente, de acuerdo a Di Pietro, el concepto de "contrato" continúa su evolución mediante el trabajo de los "comentaristas medievales", tal el caso de Donello y Cuiaccio⁽¹¹⁾. Señala el maestro argentino que luego, "cuando llegamos a la época del modernismo, nos encontramos con el holandés Hugo Grocio (1583-1645), quien tendrá una importancia muy decisiva en el desarrollo de la concepción del 'consensualismo' en materia contractual"⁽¹²⁾. Más adelante, "la influencia de Grocio se verá reflejada en los juristas franceses Jean Domat (1625-1696) y Robert Joseph Pothier (1699-1772), quienes tratan la cuestión del contrato de manera genérica, sin mencionar las incursiones jusfilosóficas que había hecho Grocio"⁽¹³⁾. Corresponde después a Savigny "ampliar aún más el concepto contractual, extendiéndolo fuera incluso del ámbito de las obligaciones propiamente dicho, definiendo al contrato como, 'el acuerdo de varias personas sobre una manifestación común de voluntad destinada a regir sus relaciones jurídicas'"⁽¹⁴⁾; concepto luego adoptado casi de modo literal por Vélez Sarsfield, autor del Código Civil argentino⁽¹⁵⁾.

1. Elementos

Los elementos del contrato son los siguientes:

a) Sujetos. Se requiere, como mínimo, el concurso de dos voluntades, es decir, la promesa del deudor y su aceptación por parte del acreedor. b) Capacidad de las partes. Es fundamental que las partes tengan capacidad. c) Objeto. Debe ser determinado o determinable y posible, tanto física como jurídicamente. d) Consentimiento. Puede ser expreso o tácito; en el primer caso, se otorga en forma verbal o por escrito, y en el segundo, mediante gestos o actitudes.

II. LOS CONSIDERADOS CONTRATOS ROMANOS ANTIGUOS

Considero como contratos romanos antiguos a los denominados contratos "verbales" (verbis) y "literales" (litteris).

1. Los contratos "verbales" (verbis)

Son aquellos que se perfeccionan mediante el empleo de palabras solemnes exigidas por la ley. Son contratos formales porque las partes deben cumplir con los requisitos orales prescriptos por la ley. También son de derecho estricto, debido a que la facultad del juez para interpretarlos se limita a aquello que expresamente han convenido las partes, y unilaterales, ya que sólo constituyen obligaciones a cargo del sujeto pasivo o deudor. Los contratos verbales más antiguos son los denominados nexum y sponsio. También se incluyen dentro de esta categoría la stipulatio, la promesa de dote (dictio dotis) y el juramento provisorio del liberto (promissio iurata liberti).

1.1. Nexum

Para llevarlo a cabo se utiliza un procedimiento con características similares a la mancipatio, debiéndose recurrir, entonces, a la pesada del cobre sobre la balanza en presencia de las partes, el libripens y cinco testigos, agregándose una declaración del acreedor que determina la naturaleza del acto. La realización de dicho procedimiento autoriza al acreedor a utilizar la manus iniectiones respecto del deudor que no cumple con su obligación⁽¹⁶⁾, y constituye, así, una forma de garantizar su cumplimiento. El estado de servidumbre en el cual queda sumido el deudor que incumple su obligación no es permanente, sino que el acreedor se compromete, en el mismo acto contractual, a emanciparlo una vez que éste cumpla la prestación. Tal liberación puede exigirse mediante medios ejecutivos. La injusta situación en que queda sumido el deudor genera que en el año 326 a.c. la lex Paetelia Papiria deje sin efecto al nexum, al prohibir el encadenamiento de un ciudadano, su venta o muerte, a menos que la obligación provenga de un delito, disponiendo que en adelante el deudor responde solamente con sus bienes, siempre que asegure que ellos son suficientes para cubrir la suma adeudada. Además, decreta la libertad de todos los nexis⁽¹⁷⁾. Entiendo que esta disposición es el vestigio más antiguo del adagio constitucional moderno de la inexistencia de prisión por deudas.

1.2. Sponsio

Es una figura utilizada únicamente por los ciudadanos romanos. También se celebra en forma oral, mediante una pregunta formulada por el acreedor en términos sacramentales, seguida de la respuesta brindada por el deudor⁽¹⁸⁾, no pudiéndose utilizar otro verbo. Este tipo de contrato puede emplearse en todo tipo de relaciones jurídicas privadas y públicas, ya que cualquier convenio puede concertarse utilizando esta modalidad. También sirve para formalizar la promesa de esponsales y para concertar tratados de paz o alianzas con países extranjeros⁽¹⁹⁾.

1.3. Stipulatio

Por la facilidad con que puede celebrarse se convierte en la forma más habitual de contraer una obligación unilateral, que posteriormente también puede ser utilizada por los peregrinos. En un principio, se lleva a cabo empleando la forma de la sponsio, es decir que el acreedor utiliza la palabra spondes para formular la pregunta, y el deudor le responde spondeo. Cuando el derecho honorario, influenciado por el ius gentium, comienza a regular las relaciones jurídicas entre ciudadanos y extranjeros, se le reconoce validez a otros términos para formular las preguntas y las respuestas⁽²⁰⁾.

Los requisitos para que se perfeccione son: oralidad, unidad del acto, congruencia entre pregunta y respuesta y la presencia de las partes intervinientes. Son incapaces, entonces, de

formular este tipo de contratos el sordo, el mudo y el menor infans, que no tienen discernimiento para comprender las preguntas y las respuestas⁽²¹⁾. Tampoco puede celebrarse este tipo de contrato entre ausentes⁽²²⁾. La unidad del acto implica la inmediación entre la pregunta y la respuesta, sin que existan interrupciones entre ellas. Asimismo, el deudor debe estar de acuerdo con lo que el acreedor pretende y debe existir congruencia entre lo que se reclama y lo que se promete⁽²³⁾. La respuesta debe ser la reproducción de la pregunta y el deudor no puede cambiar su sentido⁽²⁴⁾. Aquellas formalidades exigidas en un primer momento se mitigan paulatinamente, hasta que son completamente eliminadas por medio de una Constitución del emperador León, del año 472, que le otorga validez a todas las estipulaciones, aun cuando no se hayan efectuado con palabras solemnes. Al mismo tiempo, la oralidad pierde su importancia fundamental al permitirse que se redacten documentos como medio de prueba de la existencia del contrato, a los que se llama *cautio*⁽²⁵⁾. A esto también contribuye que el acuerdo entre las partes se convierta en el elemento fundamental del acto, y no ya la formalidad con la cual éste se celebra. Además, se atenúa el requisito que establece que las partes deben encontrarse presentes.

Si bien en un principio se emplea a la *stipulatio* para contraer obligaciones de dar sumas de dinero, luego se extiende esta modalidad a otras prestaciones de dar cosa cierta, y aun a la de entregar cosa incierta, por la facilidad con que puede celebrarse este contrato. También sirve para convenir la novación de una obligación o para confirmar un acuerdo ya existente. Además, se emplea para asegurar otro tipo de obligación, y entonces puede celebrarse la *adpromissio*, promesa solemne por medio de la cual una persona se obliga accesorariamente al deudor principal, garantizando al acreedor en caso de que aquél sea insolvente, o la *adstipulatio*, mediante la que se acuerda que existe un acreedor accesorio, que conviene la misma prestación con el deudor que el acreedor principal y puede accionar directamente contra el primero, porque obra como mandatario en beneficio del acreedor principal⁽²⁶⁾.

También se utiliza a la *stipulatio* para establecer "cláusulas penales" (*stipulatio poenae*), mediante las cuales el deudor debe abonar la pena convenida en caso de no cumplir con la prestación. Las estipulaciones se clasifican del siguiente modo: a) Judiciales. Son las promovidas por el juez de oficio cuando las partes se encuentran "en juicio" (*in iudicio*). b) Pretorianas. Son las originadas por el pretor, como las relativas al daño inminente y los legados. c) Convencionales. Acordadas por las partes sin que intervengan ni el juez ni el pretor, pudiendo existir tantas especies como obligaciones se conocen. d) Comunes. Que pueden ser judiciales o pretorianas. Son aquellas que deben otorgar los tutores o curadores a favor de sus pupilos, a fin de garantizar el cumplimiento de su gestión y pueden ser estipuladas por el juez o el pretor⁽²⁷⁾.

1.4. "Promesa de dote" (*dictio dotis*)

Consiste en el uso de formalidades orales para dar fuerza obligatoria a una promesa de dote. Ella puede efectuarla la mujer, si *essui iuris*, o su padre o ascendiente agnado, si ella es *alieni iuris*⁽²⁸⁾. Para que quede perfeccionado no se requiere que el marido sea previamente interrogado, ni que acepte expresamente la dote, bastando para ello la declaración unilateral de la mujer o su ascendiente agnado⁽²⁹⁾. Se puede prometer la *dictio dotis* tanto respecto de bienes muebles como inmuebles, corporales o incorporeales. En el derecho clásico se utiliza este tipo de contrato para transferir al marido la deuda que un tercero tiene con su mujer, pero ello cae en desuso cuando Teodosio II le concede fuerza obligatoria a la promesa de dote llevada a cabo sin respetar ninguna formalidad (*pactum dotis*)⁽³⁰⁾.

1.5. "Promesa jurada del liberto" (*Promissio iurata liberti*)

Es la declaración unilateral del esclavo, prestada bajo juramento, por medio de la cual se compromete a realizar determinadas obras o servicios para el patrón luego de su manumisión⁽³¹⁾. Esta promesa se sustenta en un vínculo religioso y no genera ninguna consecuencia jurídica. Para lograr este último resultado, es decir, para conseguir el nacimiento de una obligación civil, se

requiere la realización de un segundo juramento por parte del liberto una vez que ya ha sido manumitido.

2. Los contratos "literales" (literes)

Son aquellos que se perfeccionan con la escritura. Se caracterizan por ser formales, unilaterales y de derecho estricto. Llegamos a su conocimiento por las obras de Gayo, Tito Livio, Cicerón y el Manuscrito de Verona. Son los siguientes:

2.1. *Nomina transcriptitia*

Tiene su origen en los registros domésticos contables que debe llevar el pater familia. Éste debe consignar a los efectos del censo el estado patrimonial de su familia en dos libros; en uno (adversaria) se anotan las entradas y salidas diarias; y el otro, de anotación periódica (codex accepti et expensi), dividido en dos columnas en que se indican las entradas y las salidas, respectivamente. En un principio, estas anotaciones constituyen únicamente un medio de prueba. Más tarde, configura un contrato del tipo escrito, permitiendo la transformación de una obligación preexistente en otra distinta cuando se adopta la costumbre de llevar a cabo la nomina transcriptitia, que consiste en una operación de doble entrada, en la cual una anotación en el acceptum significa la cancelación de una deuda anterior, cualquiera sea su causa; y un registro realizado a continuación en el expensum, con la anotación de idéntica cantidad como entregada a una persona, indica la realización de un pago. Así, se transforma una obligación preexistente en una abstracta sin expresión de causa, la cual puede estar a cargo del mismo deudor o de otro distinto⁽³²⁾. La anotación en el libro del acreedor se efectúa con el consentimiento del deudor, quien puede brindarlo verbalmente cuando el acreedor se encuentra presente, y además debe asentarse la causa de la obligación.

Son distintas clases de nomina transcriptitia las siguientes. Por un lado, la transcriptitia a re in personam, cuando las partes convierten en otra obligación de igual naturaleza a través de la utilización de la doble anotación⁽³³⁾; v.gr., transformar una obligación de buena fe en una obligación de derecho estricto o una obligación natural en una obligación civilmente exigible. Por otro, la transcriptio a persona in personam, que consiste en cambiar la figura del deudor por otro, es decir, cuando la cantidad debida por una persona se coloca a cargo de otra persona, que desde ese momento figura como deudor en lugar del anterior⁽³⁴⁾.

La nomina transcriptitia se celebra sólo entre ciudadanos romanos y versa sobre sumas ciertas de dinero. Puede concertarse entre ausentes, pero no estipularse bajo condición⁽³⁵⁾. Esta forma cae en desuso a partir del derecho romano helénico, ya que los ciudadanos dejan de realizar anotaciones en los libros, conservándose únicamente para los banqueros la obligación de llevar libros de contabilidad.

2.2. *Chirographa*

Se utiliza para concertar obligaciones entre los peregrinos⁽³⁶⁾. Lo cita Gayo en su obra. Son documentos únicos, firmados por el deudor, que quedan en poder del acreedor y en los que se reconoce el negocio celebrado entre ellos. Salvando las distancias, encuentro en éste el origen del pagaré moderno o de reconocimiento de deuda. Tienen un efecto meramente probatorio. Durante el Bajo Imperio los utilizan frecuentemente los usureros, porque les hacen firmar al deudor el documento antes de efectuarle el préstamo, y después lo completan con una suma de dinero

superior a la que efectivamente le entregan al deudor, encubriendo de esta manera la aplicación de un interés muy alto.

2.3. Syngrapha

Los peregrinos también utilizan esta modalidad para contraer obligaciones, al igual que la anterior, pero redactadas en doble ejemplar, suscriptos por ambas partes, insertándose en ellos sus sellos y los de los testigos de la celebración del acto. Cuentan con fuerza obligatoria por sí mismos, constituyéndose dicho documento en causa de la obligación. Este tipo de contratos desaparece cuando todos los súbditos del imperio adquieren la ciudadanía en virtud del Edicto de Caracalla, mientras que los *quiographas* continúan empleándose como medios probatorios. Estos contratos, al igual que los *quiographas*, sólo tienen efectos probatorios entre los ciudadanos romanos. En mi opinión, nos encontramos en el umbral del contrato común actual.

III. LOS CONSIDERADOS CONTRATOS ROMANOS MODERNOS

Son aquellos conocidos actualmente como reales y consensuales.

1. Los contratos reales (*re contrahitur obligatio*)

Son aquellos que se perfeccionan con la entrega o tradición de la cosa, y son los siguientes:

1.1. *Mutuo (Mutuum)*

Conocido también como "préstamo de consumo". Puede definirse como el acuerdo de voluntades mediante el cual una persona, llamada mutuante o prestamista, le entrega en propiedad a otra, llamado mutuario o prestatario, una determinada cantidad de cosas fungibles, con la obligación por parte de esta última de restituir dentro de cierto plazo la misma cantidad del mismo género y calidad⁽³⁷⁾.

En un principio, este tipo de contrato requiere para su perfeccionamiento las mismas solemnidades que el *nexum*, pero en la época clásica sólo se exige el consentimiento de las partes, seguido de la tradición de la cosa.

Es un contrato unilateral, ya que sólo genera obligaciones para el deudor; de derecho estricto, porque los jueces deben remitirse a aquello que expresamente han convenido las partes; real, debido a que se perfecciona con la mera entrega de la cosa; no formal y gratuito, porque el mutuario no puede devolver una cantidad mayor de la cosa. Además, el objeto debe versar acerca de cosas que puedan ser determinadas por su número, peso o medida.

La transferencia de la cosa implica el traspaso de la propiedad, porque, tratándose de un préstamo de consumo, la cosa debe pertenecerle al deudor para que la pueda consumir. Por ello, el prestamista debe tener capacidad para enajenar, tener el dominio sobre la cosa que va a transmitir y dicha transmisión debe llevarse a cabo por medio de la tradición⁽³⁸⁾. Si la cosa le es ajena al

prestamista, hay que distinguir si el adquirente es de buena o mala fe. En el primer caso, el mutuo es válido, porque hay traslado de propiedad, mientras que en el segundo supuesto, el tercero propietario de la cosa está autorizado a recuperarla, ejerciendo la "acción de reivindicación", y en caso de que las cosas sean consumidas por el adquirente, éste queda obligado a restituir una suma de dinero equivalente a su valor⁽³⁹⁾.

También se admite que se lleve a cabo la tradición de la cosa a través de representantes o gestores y la tradición simbólica, es decir, la traditio brevi manu o por el constitutum possessorium⁽⁴⁰⁾.

Como ya señalé precedentemente, su objeto debe estar constituido por cosas fungibles, es decir, por bienes que son susceptibles de ser reemplazados por otros de la misma especie y cantidad; v.gr., comestibles, dinero, etc⁽⁴¹⁾. La simple promesa de mutuo no autoriza al mutuante a exigir su cumplimiento porque, al tratarse de un contrato real, la promesa sólo constituye un precontrato y, como tal, origina únicamente una obligación natural⁽⁴²⁾.

Si bien el mutuario no puede obligar a devolverle al mutuante más cantidad que la que ha recibido, las fuentes admiten, entonces, que las partes puedan acordar que el deudor debe devolver siempre una cantidad menor, considerándose que la diferencia implica una donación⁽⁴³⁾. La pérdida por caso fortuito no libera al mutuario de su obligación. Sólo se puede exigir la restitución al operar el vencimiento del plazo convenido por las partes⁽⁴⁴⁾. Si no lo han estipulado, el acreedor puede exigir su cumplimiento en cualquier momento, exigencia que queda condicionada al término dispuesto por el juez, luego de hecho el requerimiento al obligado⁽⁴⁵⁾. También las partes pueden convenir que el mutuo esté sujeto a una condición y entonces la transferencia de la propiedad opera una vez que ella se cumple⁽⁴⁶⁾. Además, este tipo de contrato admite las mismas modalidades que la estipulación⁽⁴⁷⁾.

FRANJA

1.1.1. El mutuo y los intereses

Como el mutuo es un contrato gratuito, los romanos introducen la modalidad cuando el objeto del contrato es una suma de dinero, de convenir intereses (usurae), que representan el equivalente al uso de la cosa del que se encuentra privado el prestamista. Solamente se pueden pactar intereses concertando un negocio distinto por medio de la "estipulación" (stipulatio). También pueden convenirse intereses mediante un simple pacto, pero ello sólo genera una obligación natural⁽⁴⁸⁾. Finalmente, se acepta su validez en préstamos que tienen por objeto sumas de dinero, como los préstamos efectuados por el fisco y las ciudades, los otorgados por los banqueros y los mutuos de dinero destinados al comercio marítimo⁽⁴⁹⁾.

Antiguamente, la tasa de interés que podía cobrarse no tenía ninguna limitación, pero ello provoca abusos; entonces la Ley de las XII Tablas establece un máximo de una onza por ciento al mes (uncia) (equivale a un 8,33%)⁽⁵⁰⁾. En el año 355 a.C., la lex Duilia Maenenia fija la tasa de interés en el uncium fenus⁽⁵¹⁾. En el año 347 a.C., un plebiscito reduce la tasa de interés a la mitad de la uncia y la lex Genucia del año 342 a.C. prohíbe el préstamo a interés, aunque ello, en la práctica, nunca se cumple⁽⁵²⁾.

Además, la situación de los deudores se agrava, ya que se cuentan los intereses por mes, agregándose al capital el interés mensual ya vencido, y éste, a su vez, genera un nuevo interés para el mes siguiente⁽⁵³⁾. Esto lleva a que en la época de Sila se determine que el interés debe ser del 1% mensual, es decir, del 12% anual, y luego Justiniano lo reduce al 6% anual⁽⁵⁴⁾. Sin embargo, estas tasas pueden modificarse atendiendo a la condición del deudor o a la naturaleza de las transacciones⁽⁵⁵⁾. También Justiniano dispone que todo pago de incremento de intereses debe imputarse al capital⁽⁵⁶⁾. El "senadoconsulto macedoniano" prohíbe que se efectúen préstamos a los hijos de familia sin consentimiento del pater y, si esto no es así, no son exigibles, constituyendo una obligación natural.

1.2. Comodato (commodatum)

Denominado también "préstamo de uso". Es el acuerdo de voluntades por medio del cual una persona (comodante) entrega gratuitamente a otra (comodatario) el uso de una cosa no fungible, debiendo esta última devolverla en el lugar y tiempo convenidos⁽⁵⁷⁾. Es un contrato real, sinalagmático imperfecto, porque sólo accidentalmente genera obligaciones a cargo del comodante; gratuito y de buena fe, por la amplitud de facultades que tiene el juez para su apreciación.

Se requiere que el comodante efectivamente le entregue la cosa al comodatario y la simple promesa no engendra ninguna obligación. Las partes deben tener la intención común de que aquel que recibe la cosa la utilice o se sirva de ella, por lo que el comodatario no adquiere su propiedad, ni la posesión, sino sólo la simple tenencia⁽⁵⁸⁾. El objeto del contrato debe ser una cosa no fungible, mueble o inmueble, ya que el mutuario debe devolver el mismo bien⁽⁵⁹⁾. Excepcionalmente se permite el préstamo de uso de cosas consumibles, cuando, por ejemplo, se entregan monedas para su exhibición, pero en realidad ellas en este caso se consideran como cosas no fungibles⁽⁶⁰⁾.

El comodatario debe utilizar la cosa en la forma que se conviene y, en caso de que nada se pacte, debe servirse de ella misma de acuerdo con su uso común. Aquel que emplea la cosa de una manera no autorizada es sancionado con las mismas penas que aquel que comete un hurto de uso (furtum usus)⁽⁶¹⁾. Además, debe devolver la cosa en el lugar y tiempo convenidos, con todos aquellos frutos y productos que se le han agregado⁽⁶²⁾. Como el comodante no obtiene ningún beneficio, el comodatario, ante la pérdida de la cosa, es responsable por dolo y por toda culpa⁽⁶³⁾. Además, se puede estipular que debe responder por caso fortuito y también en aquellos casos en que se estima que la cosa es de todo riesgo o cuando el hecho que provoca el caso fortuito le es imputable⁽⁶⁴⁾. Pero si el bien se entrega en interés del comodante, el comodatario sólo responde por la pérdida de la cosa en caso de que actúe con dolo.

Por otra parte, eventualmente pueden surgir obligaciones a cargo del comodante por hechos suyos o como consecuencia de la cosa. Ello, cuando éste perturba al comodatario en el uso y goce de la cosa o cuando conoce los vicios o defectos ocultos que ésta tiene y con ello le ocasiona un daño al comodatario. También éste tiene la obligación de resarcir aquellos gastos extraordinarios que el comodatario efectúe para conservar la cosa, no así respecto de los gastos comunes⁽⁶⁵⁾. El comodatario puede retener la cosa prestada hasta tanto el comodante resarza los gastos que haya efectuado para conservar la cosa en condiciones⁽⁶⁶⁾.

1.3. Depósito (depositum)

Es el acuerdo de voluntades por el cual una persona (depositante) le entrega una cosa mueble a otra (depositario) para que la guarde o custodie gratuitamente, y se la devuelva ante el primer requerimiento o ante el vencimiento del plazo convenido⁽⁶⁷⁾. Puede considerarse como un contrato real, de buena fe, sinalagmático imperfecto y gratuito. En el derecho justinianeo se le permite percibir al depositario una retribución por la guarda de la cosa⁽⁶⁸⁾.

Para que se perfeccione este contrato se requiere que el depositante le entregue una cosa mueble al depositario, quien sólo adquiere su tenencia, y por ello no se necesita que aquel que entregue la cosa sea su propietario, sino que basta con que pueda disponer materialmente de ella. El simple acuerdo sobre este punto no configura el contrato⁽⁶⁹⁾.

El depositario tiene la obligación de devolver la misma cosa cuya custodia se le encomienda⁽⁷⁰⁾. Debe conservarla en el mismo estado en el cual la recibe y no puede utilizarla. Si no cumple con esta obligación, incurre en el delito de uso ilícito (furtum usus)⁽⁷¹⁾. Esta obligación persiste durante todo el plazo convenido, pero el depositante puede retirar la cosa en cualquier momento⁽⁷²⁾. Luego de transcurrido el plazo estipulado, el depositario debe devolver la cosa en el estado en que le ha sido entregada, con los frutos o productos que se le han agregado⁽⁷³⁾. El depositario debe cumplir con esta obligación y no puede argumentar, para no hacerlo, que el depositante es a su vez su deudor o que la cosa no le pertenece o que es el verdadero propietario de la cosa⁽⁷⁴⁾. Ante la pérdida de ésta, el depositario responde por dolo y culpa grave⁽⁷⁵⁾.

El depositante, por su parte, debe resarcir aquellos gastos que el depositario efectúa para la conservación de la cosa o aquellos que se lleven a cabo con el objeto de restituirla. Además, es

responsable por toda culpa, porque el depósito siempre se efectúa en su propio beneficio, y también debe resarcir aquellos daños que puede sufrir el depositario a causa de la custodia de la cosa⁽⁷⁶⁾.

La jurisprudencia romana también admite otros tipos de depósito; así, el depósito necesario o miserable, el secuestro y el depósito irregular.

1.3.1. Depósito necesario o miserable

Tiene lugar con motivo de una calamidad pública, tumulto, incendio, ruina, naufragio o cualquier otra situación imprevista que, originando un riesgo inminente para determinados bienes, impiden que el depositante pueda elegir libremente a quién le va a confiar su depósito⁽⁷⁷⁾. Por ello el depositario responde por toda culpa⁽⁷⁸⁾.

1.3.2. Secuestro

Se origina cuando dos o más personas le dan a otra la custodia de un bien, y ésta debe entregársela a un individuo designado previamente, o a quien llegue a encontrarse en determinada situación⁽⁷⁹⁾. Este tipo de depósito puede ser voluntario, como por ejemplo cuando se celebra una apuesta y el premio se deja en manos de un tercero, o necesario, o judicial; v.gr., cuando existe una controversia sobre una cosa y ésta queda en custodia de un tercero que luego debe entregársela a quien el juez considere ganador del litigio⁽⁸⁰⁾. Asimismo, puede tener por objeto cosas muebles o inmuebles⁽⁸¹⁾. En estos casos no puede exigirse la restitución de la cosa hasta que no ocurra el evento que se tiene en cuenta para acordar el secuestro⁽⁸²⁾.

1.3.3. Depósito irregular

Tiene lugar cuando se entrega la custodia de cosas fungibles, generalmente dinero, y el depositario tiene la obligación de devolver otras cosas del mismo género. Es semejante al mutuo⁽⁸³⁾. Sin embargo, este depósito se celebra en interés del depositante, ya que éste le entrega la custodia de los bienes al depositario por la responsabilidad y confianza que éste le inspira. En este caso, basta el simple pacto de interés, ya que se trata de un contrato de buena fe. Se lo considera el antecedente de los depósitos bancarios.

1.4. Prenda (pignus)

Es el acuerdo de voluntades por el cual una persona (pignorante) le entrega a otra (pignoratario) la posesión de una cosa corporal para garantizar una deuda propia o ajena, con la obligación de quien la recibe de conservarla y restituirla cuando ella se salde⁽⁸⁴⁾. Es un contrato real, sinalagmático imperfecto, de buena fe, no formal y accesorio.

Para que este contrato se perfeccione, se requiere que se le otorgue la posesión de la cosa al acreedor. Por ello, el bien dado en garantía puede ser mueble o inmueble y pertenecerle al deudor o a un tercero⁽⁸⁵⁾.

El acreedor prendario debe conservar la cosa, pero no puede utilizarla, y ante su pérdida responde por dolo y por toda culpa. No ocurre lo mismo con el caso fortuito, ya que ambas partes tienen un interés en su celebración. Si el acreedor utiliza la cosa, incurre en el *furtum usus*⁽⁸⁶⁾. El acreedor pignoraticio debe restituir la cosa junto con los frutos que ésta genera una vez que el deudor cumpla con su obligación⁽⁸⁷⁾. Ello no ocurre cuando las partes convienen el "pacto de anticresis" (*pactum antichreticum*), en cuyo caso los frutos se imputan al pago de los intereses y luego al capital, en caso de que exista un sobrante⁽⁸⁸⁾. Si la deuda no se paga, el acreedor puede retener la cosa o venderla para cobrar y devolverle el remanente al deudor⁽⁸⁹⁾.

El deudor puede encontrarse obligado a devolverle al acreedor el equivalente de dinero empleado para conservar la cosa y reparar también los daños que ella le origina, excepto cuando éstos no le sean imputables⁽⁹⁰⁾. Además, debe garantizar la calidad de la cosa objeto de la prenda y, en consecuencia, responde por los vicios y defectos ocultos⁽⁹¹⁾.

2. Los contratos consensuales (solo consensu contrahitur obligatio)

Este tipo de contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, sin importar la forma en que éste se manifiesta, y tampoco se requiere la entrega de la cosa, ni el cumplimiento de determinadas formalidades⁽⁹²⁾. Los contratos en particular son los siguientes:

2.1. *Compraventa (Emptio venditio)*

Es el acuerdo de voluntades por el cual una de las partes (vendedor) se obliga a entregar a otra (comprador) la propiedad de una cosa a cambio de una suma cierta de dinero llamada precio.

Este tipo de contrato varía a lo largo del tiempo. Su forma más antigua es la permuta o trueque, mediante la cual las personas se procuran aquellos elementos que les resultan necesarios para su subsistencia. En virtud de los inconvenientes que este último tipo de contrato genera, en algunas ocasiones se busca un elemento común de cambio. En un principio, los metales preciosos reemplazan el trueque de "cosa por cosa". Luego, aparece la moneda, piezas que tienen un valor determinado y fijo, que cuentan con garantía para ser empleadas como medio de cambio porque son acuñadas por el Estado. La moneda resulta más fácil para el intercambio, dado que su valor se encuentra predeterminado, facilitando el nacimiento del contrato consensual de compraventa.

En sus comienzos, para poder concertar este tipo de contrato, se recurre a la forma de la *mancipatio*, puesto que el consentimiento no cuenta con el lugar privilegiado que ocupa hoy en día. En dicha época, la compraventa es la causa que origina la adquisición real de la propiedad, y no una fuente creadora de obligaciones. A fines de la República, cuando ya prepondera el "derecho de gentes" (*ius gentium*), se configura el contrato consensual de compraventa como generador de obligaciones.

En el derecho romano, el vendedor se obliga a transmitir la posesión de la cosa, garantizando su pacífico uso y goce y, a su vez, el comprador tiene la obligación de transmitir la propiedad del dinero que entrega como precio⁽⁹³⁾.

La compraventa, cuyo concepto ha sido plasmado *ut supra*, puede celebrarse entre ausentes, por carta o mandatario⁽⁹⁴⁾. Es un contrato bilateral, sinalagmático perfecto, oneroso, conmutativo y de buena fe.

Es necesario que las partes tengan capacidad tanto para enajenar como para obligarse; v.gr., los administradores de un patrimonio ajeno no pueden celebrar este tipo de contrato respecto de los bienes de sus administrados, salvo que la compra se haga públicamente y de buena fe⁽⁹⁵⁾. La misma incapacidad tienen los tutores, curadores, mandatarios, gestores y los administradores de la cosa pública⁽⁹⁶⁾. Por su parte, los militares y funcionarios públicos no pueden adquirir inmuebles en el territorio donde ejercen sus funciones⁽⁹⁷⁾.

Los celebrantes deben encontrarse de acuerdo sobre las obligaciones que cada uno va a tener y el consentimiento que prestan al respecto debe adolecer de vicios. Pueden estipular que el contrato se redacte por escrito y, en ese caso, el contrato recién se perfecciona y comienza a tener validez jurídica desde que es firmado por ambas partes⁽⁹⁸⁾. Sólo en casos excepcionales se deja de lado la voluntad de las partes; por ejemplo, en aquellos supuestos de venta obligatoria al Estado por causa de utilidad pública⁽⁹⁹⁾.

En cuanto a los elementos específicos que integran este contrato, en primer lugar debe tratarse de una cosa susceptible de apreciación económica, que se encuentre en el comercio, que pueda integrar un patrimonio y su enajenación no debe estar prohibida expresamente por ley⁽¹⁰⁰⁾. Por ello, el objeto de este contrato lo constituyen, fundamentalmente, bienes corporales, tanto muebles como inmuebles. Cuando se admite que el derecho de hipoteca y las servidumbres prediales pueden enajenarse, siempre que se transmita al mismo tiempo el crédito al que accede la hipoteca o el fundo al que grava la servidumbre, se acepta que las "cosas incorpóreas" (res incorporis) puedan ser objeto de este tipo de contrato⁽¹⁰¹⁾. El usufructo no puede ser vendido, pero puede transmitirse por dicha vía el uso de ese derecho, manteniéndose al usufructuario como titular⁽¹⁰²⁾. También este tipo de contrato resulta idóneo para transmitir la simple posesión y se admite que la herencia pueda ser vendida, como así también todos los créditos y derechos que la componen, aunque estén sujetos a término o condición⁽¹⁰³⁾.

Por otra parte, no se permite la compra de la cosa propia, pero es válida la compra de la posesión o del usufructo que un tercero ejerce sobre ella⁽¹⁰⁴⁾. Una persona también puede adquirir la parte ajena de una cosa que le pertenece en condominio con otra, con la respectiva reducción en el precio⁽¹⁰⁵⁾.

Asimismo, las cosas futuras pueden ser objeto de este contrato. La compra de una simple esperanza se da cuando una persona compra el resultado eventual de un hecho; por ejemplo, todos los peces que se obtengan luego de tirar una red al agua una sola vez. La compra surte todos sus efectos aunque la cosa nunca llegue a existir, ya que está librada al azar⁽¹⁰⁶⁾. La compra de una cosa esperada tiene lugar cuando se adquiere; v.gr., el trigo que resulte de la cosecha de determinado fundo. Dicha compra queda sujeta a que efectivamente se obtenga el producto. Si esto no llega a ocurrir, el comprador no está obligado a pagar el precio ni tampoco el vendedor a entregar nada⁽¹⁰⁷⁾.

El otro elemento del contrato de compraventa es el precio, que consiste en una suma cierta y verdadera de dinero⁽¹⁰⁸⁾. El precio debe estar determinado o ser determinable⁽¹⁰⁹⁾. Si el precio se deja librado a la voluntad de un tercero elegido por las partes, la venta se considera efectuada bajo condición, y si el tercero se niega o no puede estimar el precio, el negocio no se realiza por no haber sucedido el evento previsto⁽¹¹⁰⁾. La compraventa es nula si el vendedor o el comprador fijan exclusivamente el precio sin el consentimiento de la otra parte⁽¹¹¹⁾. El precio debe ser serio y no simulado, es decir que no resulte irrisorio con respecto al valor de la cosa, y que el precio que figura como convenido sea el que realmente hay que abonar⁽¹¹²⁾. Además, el precio tiene que ser justo, es decir que debe ser coherente con el valor de la cosa que se enajena⁽¹¹³⁾.

La obligación principal del comprador es pagar el precio convenido en el lugar y plazo determinados en el contrato o después de su celebración, si no se estipula un término para hacerlo⁽¹¹⁴⁾. El comprador que no lo hace no puede exigirle al vendedor la entrega de la cosa, porque las obligaciones que tienen cada uno a su cargo son conexas entre sí⁽¹¹⁵⁾. Además, está obligado a sufragar los gastos que el vendedor efectúe para el mantenimiento de la cosa después de la venta, y a pagar los intereses sobre el precio adeudado a partir de la fecha en que se hace efectiva la entrega de la cosa en aquellos casos en que la venta se efectúa a plazo⁽¹¹⁶⁾.

Una vez perfeccionada la venta, antes que se realice la entrega del objeto, los riesgos de la pérdida o deterioro de la cosa, ya sea por su propia naturaleza o por caso fortuito, se encuentran en cabeza del comprador, salvo que expresamente se convenga algo distinto. Si el bien perece después de celebrado el contrato, el vendedor no tiene ninguna responsabilidad, salvo que actúe con dolo o culpa, y el comprador igual debe abonar el precio, si aún no lo hizo. Por esta misma razón, aquellos frutos o productos que incrementen la cosa durante este período le pertenecen al comprador⁽¹¹⁷⁾. Esta regla no se aplica en aquellos casos en que el vendedor pierde la cosa en virtud de un acto emergente de la autoridad estatal; es el caso de la expropiación por causa pública, porque el comprador puede solicitar la restitución del precio que ha pagado⁽¹¹⁸⁾.

La venta puede estar sometida a condición, y cuando el contrato versa acerca de la venta de cosas que se determinan por su número, peso o medida, hay que distinguir si han sido vendidas en conjunto o por pieza, peso y medida⁽¹¹⁹⁾. En el primer caso, vendida la cosa globalmente a un precio único, los riesgos, desde el momento en que se perfecciona el contrato, se encuentran a cargo del comprador, mientras que en el segundo supuesto, la venta está condicionada a que las cosas se

pesen o midan, porque el precio recién se determina cuando ello se lleva a cabo y entonces el riesgo de la pérdida recae, hasta ese momento, en el vendedor⁽¹²⁰⁾.

Por su parte, el vendedor debe entregarle la cosa al comprador, así este último puede adquirir la posesión de la cosa y gozar de ella como si fuera el propietario⁽¹²¹⁾. Como este contrato no tiene la facultad de transmitir al comprador la propiedad de la cosa vendida, ya que su obligación radica en transferir la posesión pacífica de la cosa, resulta necesario que la transferencia del dominio se lleve a cabo por alguno de los medios idóneos consagrados por la ley. Así, en el derecho clásico se realiza a través de la *mancipatio* y en el derecho justinianeo mediante la *traditio*⁽¹²²⁾.

2.1.1. La evicción

El vendedor, por su parte, debe entregar todos aquellos títulos y documentos correspondientes al bien, de tal forma que el comprador pueda ejercer todos los derechos inherentes a ella, como así también todas aquellas acciones que puedan corresponderle⁽¹²³⁾. Está de más aclarar que el vendedor debe entregar la cosa con las mismas calidades que con las que se compromete con el comprador. También responde por evicción frente al comprador, es decir, por los vicios jurídicos que afecten a la cosa y por las calidades prometidas y los defectos ocultos, o sea, los vicios materiales que presente.

La evicción se produce cuando el comprador es privado de la cosa por una resolución judicial dictada a favor de un tercero⁽¹²⁴⁾, ya sea por el ejercicio de la acción de reivindicación que le otorga el carácter de propietario o por el ejercicio de acciones reales como la hipotecaria, que reconocen el derecho que tiene un tercero sobre la cosa, gravándola.

Como el vendedor debe garantizarle al comprador la libre posesión de la cosa, en caso de evicción, este último se encuentra facultado a exigirle que intervenga en el juicio en su defensa, y si éste se niega, o un tercero lo vence en el pleito, puede reclamarle los daños y perjuicios que la pérdida de la cosa le ocasiona⁽¹²⁵⁾. También se considera que se encuentra incluido dentro del supuesto de evicción si el fundo se encuentra gravado con una servidumbre, porque ello impide la libre disposición del bien⁽¹²⁶⁾. Para que funcione esta garantía se exige que la evicción provenga de vicios inherentes al derecho que el vendedor tiene sobre la cosa, por no ser éste su propietario, o porque ella se encuentra gravada y que estas causas sean anteriores a la venta⁽¹²⁷⁾. Además, se requiere que exista una resolución judicial en favor de un tercero que despoje al comprador de la posesión de la cosa⁽¹²⁸⁾.

El comprador debe citar de evicción al vendedor, es decir, obligarlo a comparecer en el proceso a fin de asumir su defensa frente al tercero demandante y neutralizar la acción, independientemente de aquellas que pueda esgrimir el comprador⁽¹²⁹⁾. Si el comprador omite hacerlo, y luego pierde el pleito, no tiene recurso alguno. Sin embargo, tiene derecho a reclamarle al vendedor por la evicción, si puede probar que no tiene forma de triunfar en el litigio o que el vendedor se encuentra ausente o que por su culpa no lo ha podido citar⁽¹³⁰⁾.

Las partes pueden estipular que el vendedor no se responsabiliza por la evicción de la cosa⁽¹³¹⁾. Por otra parte, el comprador no puede invocar esta garantía cuando ya conoce el vicio jurídico que afecta a la cosa, a menos que se convenga que el vendedor responde en cualquier caso por la evicción del bien⁽¹³²⁾. La pérdida de la cosa por caso fortuito o su abandono por el comprador eliminan la responsabilidad por evicción del vendedor⁽¹³³⁾.

2.1.2. Los vicios redhibitorios

También el vendedor debe indemnizar al comprador por los vicios redhibitorios, es decir, por los defectos ocultos que presente la cosa que la vuelvan impropia para su destino o que disminuyan su valor. Para poder exigirlo, el comprador debe ignorar su existencia, porque, de conocerlos o de ser los mismos aparentes, se presume que han sido tenidos en cuenta al fijar el precio y no se puede

formular reclamo alguno. Estos vicios deben existir al momento de la venta y no surgir con posterioridad, ya que por estos últimos el vendedor no tiene ninguna responsabilidad, como así tampoco por aquellos vicios que existen al momento de efectuar la operación, pero que luego desaparecen⁽¹³⁴⁾.

El vendedor no se exime de responsabilidad porque desconozca la existencia de estos vicios, ya que se presume que él conoce perfectamente aquello que está vendiendo y que la existencia de ellos le acarrea perjuicios al comprador⁽¹³⁵⁾. Estos vicios incluyen, por ejemplo, una enfermedad mental que afecte al esclavo vendido, un animal que se adquiere para reproducir y es estéril, etc., pero no comprende los elogios que el vendedor efectúe respecto de la cosa y que después no se cumplan⁽¹³⁶⁾. También esta garantía abarca las cosas accesorias, si han sido adquiridas junto con la principal como cuerpo cierto y determinado⁽¹³⁷⁾. Esta responsabilidad puede dispensarse por el acuerdo de ambas partes, siempre que el vendedor actúe de buena fe, ya que, si conoce el defecto, ha actuado con dolo⁽¹³⁸⁾.

La "acción redhibitoria" tiene por finalidad volver las cosas a su estado anterior, de tal manera que el vendedor debe devolver el precio con sus intereses, y el comprador debe restituir la cosa que le ha sido entregada con todos sus accesorios y aumentos⁽¹³⁹⁾. El comprador también le puede exigir al vendedor que le reintegre los gastos que ha efectuado para conservar la cosa y, a su vez, debe indemnizar al vendedor por el deterioro que la cosa sufra mientras se encuentra en su posesión, siempre que dicho deterioro se origine por su culpa, la de sus familiares o sus representantes, y además debe liberar la cosa de cualquier derecho real con el cual la haya gravado⁽¹⁴⁰⁾.

2.1.3. La evicción, los vicios redhibitorios y los elementos naturales del negocio jurídico

En efecto, como lo he señalado cuando he tratado los elementos del negocio jurídico, la evicción y los vicios redhibitorios, en mi opinión, no deben considerarse elementos naturales del acto jurídico, por cuanto sólo tienen aplicación en la compraventa, que en definitiva es un negocio jurídico en particular y, por ende, no se puede generalizar para todos los negocios jurídicos.

2.1.4. Rescisión de la venta por causa de lesión

Tiene lugar cuando una persona enajena una cosa por un precio menor a la mitad de su valor real⁽¹⁴¹⁾. Esta posibilidad de rescindir el contrato nace por motivos de equidad, ya que se presume que aquella persona que vende un bien de su propiedad por un precio mucho menor al real se ha visto obligada a hacerlo por encontrarse atravesando un estado de necesidad que, para la ley, no puede pasar desapercibido. Por tal motivo, esta causal de rescisión del contrato es reconocida por los emperadores Diocleciano y Maximiano. Es el antecedente directo de la actual "lesión enorme o subjetiva".

2.1.5. Cláusulas adicionales en el contrato de compraventa

Entre ellas se encuentran:

— Pacto de adjudicación a término (*pactum in diem addictio*). El vendedor se reserva la facultad de rescindir el contrato en caso de que en cierto plazo se presente otro comprador y le ofrezca mayores ventajas; v.gr., un precio más alto.

— Pacto de retroventa (*pactum de retrovendendo*). Le permite al vendedor reservarse la facultad de volver a comprar la cosa dentro de cierto plazo por el mismo precio o por un precio diferente, ya determinado o a determinarse. Si este mismo pacto se estipula a favor del comprador, recibe el nombre de *pactum de retroemendo*.

— Pacto comisorio (*lex commissoria*). Implica que el contrato se tiene por no celebrado si el deudor no paga el precio en el lapso estipulado, debiendo por ende restituir la cosa con los frutos percibidos.

— Pacto de preferencia (*pactum protimeseos*). En caso de que el comprador desee vender la cosa, le otorga al vendedor prioridad sobre cualquier otro comprador para adquirirla en igualdad de condiciones.

— Pacto de reserva de hipoteca (*pactum reservatae hypothecae*). Le permite al vendedor reservarse el derecho de hipotecar la cosa vendida como garantía del pago del precio o del saldo que reste abonar.

— Pacto de no enajenar (*pactum de non alienando*). Por medio de este pacto el comprador puede comprometerse a no enajenar la cosa o a no vendérsela a una persona determinada.

2.2. Locación (*locatio conductio*)

Es el acuerdo de voluntades por el cual una de las partes (locatario) se obliga a pagar a la otra (locador) un precio cierto en dinero a cambio de que ésta le proporcione el uso y disfrute temporal de una cosa o le preste determinado servicio o realice una obra.

Este concepto abarca las tres especies que puede presentar este contrato: locación de cosas (*locatio conductio rei*), de servicios (*locatio conductio operarum*) y de obra (*locatio conductio operis*).

El contrato de locación se caracteriza por ser consensual, perfectamente bilateral, de buena fe, oneroso y conmutativo. Para que éste se perfeccione, se necesita que ambas partes presten su consentimiento, y para ello no se requiere ningún tipo de formalidad⁽¹⁴²⁾.

En caso de que el locatario estime que el precio que debe pagar es menor al que realmente corresponde, se entiende que el contrato no ha quedado perfeccionado, porque éste no ha prestado su consentimiento para pagar un precio mayor. Si se da el supuesto inverso, el contrato es válido, porque ambos prestaron su consentimiento respecto del precio menor⁽¹⁴³⁾.

La particularidad del contrato es que su objeto no sólo puede ser un elemento material, sino que también puede consistir en la realización de determinado servicio u obra. Por su parte, el precio debe ser cierto, verdadero y puede ser fijado por un tercero⁽¹⁴⁴⁾.

2.2.1. Locación de cosas (*locatio conductio rei*)

Implica que el locador debe procurarle al locatario el goce y uso pacífico de una cosa a cambio del pago de una suma de dinero. Este uso y goce es temporal, no origina un derecho real sobre la cosa y comprende también los frutos. Pueden ser objeto de este tipo de contrato las "cosas que se encuentren en el comercio" (*res in commercium*), tanto muebles como inmuebles. Las "cosas incorporales" (*res incorporis*) sólo pueden arrendarse junto con el fundo dominante, ya que son servidumbres prediales y constituyen un derecho real accesorio. Por su parte, las servidumbres personales pueden ser alquiladas directamente⁽¹⁴⁵⁾.

Además, el propietario de la cosa puede llegar a ser locatario cuando no hace uso de ella, ya sea porque la ha dado en usufructo o en prenda⁽¹⁴⁶⁾. No son objeto de la locación las cosas consumibles, puesto que el locatario debe restituir la misma cosa que le ha sido entregada al término del contrato⁽¹⁴⁷⁾.

El locatario también puede subarrendar el bien completo o sólo una parte, salvo que se pacte lo contrario⁽¹⁴⁸⁾. En estos casos, la legislación romana estipula una hipoteca legal a favor del locador, en los fundos urbanos, sobre las cosas muebles introducidas por el sublocatario, y en los fundos rústicos, sobre los frutos que le pertenecen, garantizándole así al locador que el locatario principal pagará el precio del arrendamiento⁽¹⁴⁹⁾.

En cuanto a los efectos de este contrato, el locador debe entregar la cosa con todos sus accesorios, confiriendo al locatario su uso y goce, debiendo conservarla en buen estado⁽¹⁵⁰⁾. El locador es responsable por los vicios ocultos y por evicción frente a cualquier turbación que sufra el locatario por parte de un tercero que no le permita gozar de la cosa pacíficamente. Si el locatario es turbado por el propio locador, y éste es de buena fe, el último pierde el pago del precio, aunque puede evitarlo entregándole al locatario otra cosa que le brinde la misma utilidad que la anterior. Si el locador actúa con culpa o mala fe, también le debe al locatario el resarcimiento por los daños y perjuicios⁽¹⁵¹⁾.

Por su parte, si la cosa presenta defectos o vicios ocultos y el locador actúa de buena fe, opera una reducción proporcional en el monto del precio, pero si éste conoce su existencia o lo ignora por negligencia, responde por todo el daño que le provoca al locatario con su conducta⁽¹⁵²⁾. El locador debe devolverle al locatario los gastos necesarios y útiles que efectúa para el mantenimiento de la cosa⁽¹⁵³⁾. Cuando la cosa desaparece por caso fortuito, el contrato queda disuelto, sin que el locador tenga alguna responsabilidad incluso se encuentra autorizado a cobrar el alquiler por el tiempo que dure el arrendamiento⁽¹⁵⁴⁾.

El locatario debe abonar el alquiler en el tiempo y lugar determinados en el contrato y si las partes nada estipulan, debe hacerlo de acuerdo a la costumbre del lugar⁽¹⁵⁵⁾. Ello está condicionado a que el locatario tenga realmente el uso y goce de la cosa y, si ello no se cumple, puede exigir una reducción del precio en proporción al tiempo que no ha podido hacerlo, siempre que se den algunos requisitos, a saber: la pérdida de la cosa debe ser total o por lo menos considerable, la misma ha de producirse como resultado de un acontecimiento extraordinario y este hecho debe ser anterior a la percepción de los frutos⁽¹⁵⁶⁾. El arrendatario no puede reclamar nada cuando la privación en el uso y goce de la cosa arrendada proviene de su dolo o culpa⁽¹⁵⁷⁾. Además, debe utilizar la cosa poniendo los cuidados de un buen padre de familia y, en virtud de ello, no puede abandonarla o brindarle un destino ilícito, como así tampoco disponer de la misma. Su responsabilidad desaparece si actúa en virtud de un temor legítimo⁽¹⁵⁸⁾. Al término de la locación, el locatario debe devolver la cosa en el mismo estado en que la ha recibido, salvo aquellos deterioros originados en su uso normal o por casos de fuerza mayor⁽¹⁵⁹⁾.

Este contrato puede concluirse a pedido del locador o del locatario, de pleno derecho y por mutuo disenso⁽¹⁶⁰⁾. El locador está facultado para solicitar la rescisión del contrato antes de su vencimiento si el locatario deja de pagar el alquiler durante dos años o no utiliza la cosa como un buen padre de familia. También puede operar la rescisión del contrato cuando el locador necesita habitar la cosa o realizar en ella reformas urgentes o necesarias⁽¹⁶¹⁾.

El locatario puede hacer lo propio cuando el locador no le entrega la cosa conforme a lo convenido, le entrega una que no sea útil para el uso al que está destinado o cuando el locador le da una cosa que le puede acarrear graves riesgos⁽¹⁶²⁾.

Por su parte, la locación de cosas se extingue de pleno derecho por la pérdida total o parcial del objeto, siempre que en este último caso el locatario se encuentre a raíz de ello en la imposibilidad material de utilizarla. Por supuesto que también la locación se extingue al vencimiento del plazo convenido por ambas partes, que generalmente es de cinco años⁽¹⁶³⁾.

El contrato puede prorrogarse por acuerdo expreso de ambas partes o por tácita reconducción. Este último supuesto se da cuando el locador, vencido el plazo convenido, le permite al locatario continuar con el uso de la cosa. El contrato queda sujeto a las mismas condiciones que el original, salvo en aquellos casos en que la prórroga se origina por tácita reconducción, y como este supuesto no lleva implícita la fijación de un nuevo plazo, en el arriendo de fundos rurales éste se prolonga hasta que cualquiera de las dos partes solicite su conclusión⁽¹⁶⁴⁾.

2.2.2. Locación de servicios (*locatio conductio operarum*)

El locador se obliga a trabajar o prestar determinados servicios al locatario a cambio del pago de un precio. Esta figura no alcanza a tener un gran desarrollo en Roma, al contrario de lo que sucede en la actualidad, porque los romanos dejan las actividades manuales casi exclusivamente en manos de los esclavos. Ello determina que los servicios que prestan quienes ejercen profesiones liberales, como por ejemplo, médicos, abogados, etc., no se encuadren dentro de esta especie. Por ello, por un tiempo prolongado, no se les permite a los profesionales exigir una retribución en dinero a cambio de sus servicios. Finalmente, en la época del proceso extraordinario (*cognitio extraordinem*), se les otorga la facultad de recurrir ante los magistrados para reclamar una recompensa por sus servicios, a la que se llama "honorarios o remuneración" (*honoraria o munera*)⁽¹⁶⁵⁾.

El locador debe realizar los trabajos en la forma, tiempo y lugar convenidos, respondiendo en caso de incumplimiento por dolo y toda culpa, pero no por caso fortuito. El locatario, por su parte, debe abonar el precio convenido o, caso contrario, aquel determinado por el uso y la costumbre. Esta obligación no desaparece, aun cuando el locador no efectúe los trabajos convenidos por fuerza mayor⁽¹⁶⁶⁾. Esta especie de contrato concluye por las mismas razones que en la locación de cosas, y también en caso de fallecimiento del locador, ya que los servicios deben prestarse personalmente (*in personam*).

2.2.3. Locación de obra (*locatio conductio operis*)

Se configura cuando una persona se compromete a realizar una obra o trabajo determinado a cambio de un precio en dinero. La persona que contrata la obra resulta ser el locador y quien debe realizarla recibe el nombre de locatario. Este último no está obligado a realizar el trabajo personalmente, ya que está facultado para contratar operarios que trabajen para él, y puede darse también el caso de que la misma persona sea también locatario de obra y locador de servicios. El locador debe realizar la obra de acuerdo con lo que se conviene y, si nada se establece al respecto, conforme a las reglas de equidad y buena fe. Responde por su dolo, culpa o impericia, pero no por caso fortuito o fuerza mayor, y su responsabilidad se extingue una vez que le entrega la cosa al locador. Este último debe aceptar la obra y pagar el precio. También debe responder por los daños que le ocasionan al locatario los materiales que él le suministra⁽¹⁶⁷⁾. Este contrato se extingue por las mismas circunstancias que la locación de cosas y la muerte del locatario sólo lo disuelve cuando el contrato se celebra teniendo en cuenta alguna característica, condición especial o técnica de éste⁽¹⁶⁸⁾.

2.3. Sociedad (*societas*)

Es el acuerdo de voluntades por el cual dos o más personas, denominados socios, se obligan recíprocamente a aportar bienes o actividades para un fin lícito de utilidad igualmente común⁽¹⁶⁹⁾. Esta institución tiene sus orígenes en el "derecho de gentes" (*ius gentium*). Es un contrato sinalagmático perfecto, de buena fe, oneroso y conmutativo.

Se requiere la unión de dos o más personas que tengan un interés común y la intención de constituir una sociedad (*affectio societatis* o *animus contrahendae societatis*). Los socios deben realizar un aporte, que puede consistir en una suma de dinero, bienes muebles o inmuebles, mercaderías, créditos, trabajo personal, etc. Los socios aportan aquello que han convenido, ya que, si no lo hacen, no hay contrato de sociedad y, en consecuencia, nace una obligación jurídica distinta⁽¹⁷⁰⁾. Además, éstos deben perseguir un fin común lícito, porque si no la convención es nula⁽¹⁷¹⁾.

Cada uno de los socios tiene una participación en las ganancias y en las pérdidas, de acuerdo con lo que han convenido. No se puede acordar que uno de ellos participe únicamente de las pérdidas y no de las ganancias. Sin embargo, tiene validez que los socios estipulen que alguno de ellos sólo participará de las ganancias⁽¹⁷²⁾.

Tampoco invalida el contrato el hecho de que no se obtengan beneficios de la sociedad, ya que se considera que ella existe desde el momento en que los contratantes manifiestan su intención de constituirla con el objeto de perseguir un resultado cualquiera, siempre que sea común a todos sus integrantes⁽¹⁷³⁾.

Los socios pueden prestar su consentimiento expresa o tácitamente, de modo verbal, escrito, carta o mensajero. En el derecho justiniano se admite la celebración de este contrato bajo condición suspensiva, por ejemplo, si el ingreso de un socio queda supeditado a que adquiera determinado cargo⁽¹⁷⁴⁾. Por otra parte, el *affectio societatis* debe perdurar entre los integrantes de la sociedad, porque si no la misma se disuelve⁽¹⁷⁵⁾.

2.3.1. Distintas clases de sociedad

Desde el punto de vista de la prestación, las sociedades se distinguen en cuanto se trate sólo de aporte de bienes (*rerum*), cuando está representada por trabajo o actividad que deben efectuar los socios (*operarum*) y cuando el aporte implica la entrega de bienes y al mismo tiempo la realización de determinado trabajo (*mixtae*).

También, pueden dividirse en "sociedades que persiguen un fin de lucro" (*societas quaestuariae*) y que "no persiguen un fin de lucro" (*societas non quaestuariae*).

Además, pueden clasificarse en universales, cuando comprenden la totalidad o una parte alícuota del patrimonio de los socios, y en particulares, cuando el aporte se encuentra representado por una cosa determinada⁽¹⁷⁶⁾.

Las denominadas "sociedades universales", a su vez, presentan dos tipos: las que involucran la totalidad de los bienes de los socios (*societas omnium bonorum*) y las que abarcan la totalidad de las ganancias que éstos obtengan en virtud del funcionamiento de la sociedad (*societas universorum quae ex quaestu veniunt*).

En las primeras (*societas omnium bonorum*), el ente social queda obligado a pagar las deudas de los socios, ya que éstos han quedado prácticamente desprovistos de patrimonio al conformar la sociedad, con excepción de aquellas deudas que se originan en un acto ilícito de uno de sus miembros⁽¹⁷⁷⁾. Los integrantes de la sociedad deben transmitir todos sus bienes y derechos reales mediante la tradición y, una vez conformada la sociedad, tiene la obligación de aportarle todos aquellos bienes que ingresen a su patrimonio⁽¹⁷⁸⁾. El socio no puede ofrecer como aporte aquellos bienes que ha conseguido a través de la realización de un delito, pero en caso de hacerlo con la conformidad de los restantes miembros, la sociedad es responsable por los daños y perjuicios que deriven de ello⁽¹⁷⁹⁾. Este tipo de sociedad se emplea especialmente para regular las relaciones patrimoniales de los esposos⁽¹⁸⁰⁾.

Por su parte, en las segundas, las "sociedades universales de ganancias" (*societas universorum quae ex quaestu veniunt*), ni los bienes presentes de los socios ni los que en el futuro adquieran por otra actividad que no sea la propia de la sociedad, como por ejemplo por un legado o una donación, ingresan al caudal social⁽¹⁸¹⁾. Este tipo de sociedad encuentra su más antigua aplicación en la asociación de esclavos manumitidos por un mismo patrón, que, como no tienen ningún bien, se asocian para utilizar su actividad o trabajo en beneficio de todos⁽¹⁸²⁾.

Las "sociedades particulares" surgen con posterioridad y en sus inicios tienen como principal objeto la compra y venta de esclavos y el préstamo a interés⁽¹⁸³⁾. En este tipo de sociedades, el activo social se forma por los aportes de cosas determinadas que efectúa cada uno de los socios. Las ganancias se obtienen en virtud del desarrollo de la actividad social y las deudas son aquellas que surgen en virtud de las operaciones sociales⁽¹⁸⁴⁾.

Estas sociedades se diferencian, por un lado, en aquellas en que los socios ponen en común el uso o propiedad de uno o varios bienes, para explotarlos y repartir los beneficios (*unius rei*)⁽¹⁸⁵⁾, y, por el otro, las que tienen por finalidad la realización de varias operaciones del mismo género, siendo su principal especie las sociedades de banqueros y de publicanos, que son aquellas que se dedican a arrendar el derecho de percibir los tributos públicos a cambio de pagar al Estado un precio convenido (*alicuius negotiationis*)⁽¹⁸⁶⁾.

2.3.2. *La societas vectigalium*

Este tipo de sociedad tiene como finalidad la explotación de minas y salinas. El patrimonio social es independiente de aquel de cada uno de los socios que la integran, y la entidad tiene distintos derechos; v.gr., poseer esclavos, manumitirlos y hasta heredarlos en calidad de patrono. Además, puede ser representada por una persona ajena a aquélla, que está facultada a contraer derechos y obligaciones en su nombre. En mi opinión, nos encontramos con el antecedente de la actual sociedad colectiva.

2.3.3. *Efectos del contrato de sociedad*

Los socios quedan obligados a efectuar el aporte convenido, debiendo entonces realizar la tradición de los bienes, la delegación o cesión de los créditos y la realización de los trabajos prometidos. Como consecuencia de ello, cada socio garantiza la evicción y los defectos ocultos de las cosas que aportan y su existencia puede dar lugar a la disolución del contrato de sociedad, siempre que no se trate de una *societas omnium bonorum*⁽¹⁸⁷⁾.

Si el socio ofrece la propiedad de un objeto, los riesgos se encuentran a cargo de la sociedad, por la aplicación de las reglas de la venta, pero si, en cambio, el socio sólo aporta su uso y goce, los riesgos continúan a su cargo, conforme a los principios de la locación. Cuando los aportes son "en género" (*in genere*), el socio es responsable por los riesgos hasta que ingresan a la sociedad, pero después de ello el ente social es quien debe afrontarlos⁽¹⁸⁸⁾.

Los negocios de la sociedad pueden ser dirigidos por cualquiera de los socios, salvo que expresamente se estipule que sólo los debe realizar uno de ellos⁽¹⁸⁹⁾. Quien lo efectúa debe rendir cuentas y está obligado a transferir a la sociedad los derechos u obligaciones que adquiere en el ejercicio de sus funciones, ya que el socio gestor se hace personalmente acreedor o deudor del negocio que realiza⁽¹⁹⁰⁾. Así, también tiene derecho a reclamar que se le restituyan los gastos que demande la realización del negocio y a que se lo libere de aquellos compromisos asumidos en nombre de la sociedad hasta la concurrencia de su alícuota⁽¹⁹¹⁾.

Los socios son responsables de dolo y culpa grave. Respecto de la culpa leve, sólo responden de la llamada culpa *levis in concreto*, ya que los une el *affectio societatis*, y porque aquel socio que actúa en representación del ente social tiene tanto interés en que la operación sea exitosa como el resto de los socios⁽¹⁹²⁾.

Los socios pueden convenir en que uno de ellos se encuentre exento de participar de las pérdidas, pero no pueden acordar que uno de ellos sea privado de las ganancias. También pueden concertar, previamente, cómo se dividirán las ganancias y qué porcentaje le corresponderá a cada uno de los socios. Si nada se estipula al respecto, se entiende que participan de las ganancias en partes iguales, y en cuanto a las pérdidas, deben afrontarlas en la misma proporción en que participan de los beneficios⁽¹⁹³⁾.

Los socios pueden disponer de su parte por contrato o por disposición de última voluntad, pero ello no origina que el tercero se vincule con los demás integrantes, ya que sólo es un cesionario. Además, cada socio puede a su vez asociar a un tercero a su porción social, pero ello no lo convierte en integrante de la sociedad, porque falta el consentimiento de los restantes socios⁽¹⁹⁴⁾.

Cuando uno de los socios celebra un negocio, sólo éste queda vinculado a terceros, excepto cuando el socio que realiza la operación es designado "factor de comercio" o "patrón de un navío", en cuyo caso todos los socios son solidariamente responsables. También se reputa que el socio actúa en representación de la sociedad cuando lo hace en virtud de un mandato expreso o tácito; y asimismo en el caso de "gestión de negocios", ratificada después por los restantes integrantes de la sociedad⁽¹⁹⁵⁾.

Si el negocio es concertado por todos los miembros de la sociedad con un tercero, cada uno de ellos es responsable en proporción a la parte que tiene en la sociedad, salvo que se estipule en contrario.

2.3.4. Disolución del contrato de sociedad

La disolución puede producirse a causa de las personas (ex personis), por las cosas (ex rebus), por la voluntad (ex voluntate) y por la acción (ex actione)⁽¹⁹⁶⁾.

El primero de los casos mencionados (ex personis) se da por muerte de uno de los socios, ya que la sociedad no puede continuar con los socios sobrevivientes ni con los herederos del socio fallecido, excepto cuando las partes convienen desde el inicio en que la sociedad continuará funcionando con los socios sobrevivientes, porque se entiende que se ha formado una nueva sociedad⁽¹⁹⁷⁾. También se disuelve la sociedad en virtud de la "disminución de cabeza máxima y media" (capitis deminutio) de alguno de los socios.

El segundo supuesto (ex rebus) se da cuando concluye la operación para la cual se conforma la sociedad; se produce el vencimiento del plazo por el cual ella se constituye; se pierden las cosas que conforman su objeto o quedan excluidas del comercio, y cuando surge alguna circunstancia que torne imposible el cumplimiento del fin para el cual se celebra el contrato de sociedad: v.gr., que éste imposibilita de pagar⁽¹⁹⁸⁾.

La sociedad se disuelve por imperio de la voluntad (ex voluntate) cuando así lo acuerdan todos los socios o uno o varios de ellos presenten su renuncia, siempre que ésta no sea intempestiva ni fraudulenta⁽¹⁹⁹⁾.

Finalmente, la sociedad se extingue mediante la interposición de una acción (ex actione) cuando alguno de los socios demanda su disolución judicial a través de la "acción de sociedad" (actio pro socio)⁽²⁰⁰⁾.

Al disolverse la sociedad, los bienes que han sido aportados por los socios y que conforman el capital social deben repartirse, pero antes han de deducirse todas las cargas de acuerdo con la naturaleza de las operaciones realizadas y deben regularse los derechos y pretensiones de los consocios. Luego se procede a la partición del patrimonio común a través del acuerdo de los socios, y cuando ello no se consigue, por decisión judicial.

2.4. Mandato (mandatum)

Es el acuerdo de voluntades en virtud del cual una persona (mandatario) se obliga respecto de otra (mandante) a hacer gratuitamente una cosa lícita que la otra le ha encargado. Es la primera forma contractual de este tipo cuya existencia se reconoce legalmente bajo la vigencia del procedimiento formulario. En sus orígenes, el mandato implica una relación de amistad, un conjunto de deberes morales y religiosos, que obligan a una persona a actuar por cuenta de otra, la cual le brinda toda su confianza. En el derecho de gentes el mandato adquiere el rango de negocio contractual, que se perfecciona con el consentimiento de las partes, prestado de manera tácita o expresa, llegando finalmente a admitirse, en virtud de la evolución jurídica, la representación en los actos jurídicos.

El mandato se caracteriza por ser un contrato consensual, de buena fe y bilateral imperfecto. Para que se perfeccione se requiere que ambas partes presten su consentimiento, que tenga un objeto lícito⁽²⁰¹⁾, que el mandante esté interesado en la ejecución del mandato y que la gestión sea gratuita. Se admite como objeto del mandato cualquier acto jurídico, así como también cualquier acto que no tenga tal carácter, como por ejemplo, que una persona se comprometa a lavar la ropa de otro gratuitamente⁽²⁰²⁾.

Por otra parte, el mandante debe estar interesado en que el mismo se lleve a cabo; nunca puede celebrarse este contrato en interés exclusivo del mandatario, porque ello implica un mero consejo desprovisto de fuerza obligatoria⁽²⁰³⁾.

El mandatario no puede exigir retribución alguna por su gestión, ya que, si se conviene algo al respecto, éste no es un mandato, sino una locación de servicios; además, si la retribución consiste en otras cosas, se está ante un contrato innominado⁽²⁰⁴⁾. Sin embargo, puede formularse una promesa de honorarios a favor del mandatario como una forma de agradecimiento frente a los servicios prestados, especialmente en el mandato judicial. Esta promesa no cuenta con fuerza obligatoria, y por ello no le confiere ninguna acción al mandatario para exigir su cumplimiento, hasta que en tiempos de Alejandro Severo se admite que pueda ser reclamada *extraordinem*, quedando librada su determinación al magistrado⁽²⁰⁵⁾.

El consentimiento de los contrayentes puede expresarse en forma expresa o tácita, por carta o mensajero, y no requiere términos sacramentales. Además, el mandato puede quedar sujeto a plazo o condición⁽²⁰⁶⁾.

La principal obligación del mandatario es cumplir el encargo en los términos convenidos, siendo responsable por todo aquello que indebidamente realice más allá de sus funciones, debiendo responder por los daños e intereses. En este caso, además, carece de derecho a reclamar que le restituyan los gastos erogados⁽²⁰⁷⁾.

El mandante debe instruir al mandatario, otorgándole un encargo especial que lo autoriza a representarlo en uno o varios negocios determinados. También puede conferirle un poder general que lo autorice a realizar actos de administración, abarcando, entonces, todos los negocios del mandante. Sin perjuicio de la libertad que le otorga al mandatario el poder general, éste no puede realizar determinados actos; v.gr., celebrar una transacción, adquirir la posesión (y en consecuencia la propiedad), o enajenar los bienes del mandante⁽²⁰⁸⁾. Para que estos negocios tengan validez, es necesario que el poder general le otorgue al mandatario la libre administración y gestión de los negocios del mandante⁽²⁰⁹⁾.

El mandatario puede delegar el cumplimiento del mandato o encargo en un tercero, siempre que el contrato no se celebre en virtud de una característica o cualidad especial del mandatario, o que expresamente se estipule que no puede ser reemplazado por otra persona. Ello no genera ningún vínculo entre el mandante y el reemplazante del mandatario, y el mandatario no se libera de las obligaciones emergentes del contrato por el solo hecho de designar un reemplazante⁽²¹⁰⁾.

Además, el mandatario debe rendir cuentas de su gestión y transferirle al mandante todo aquello que adquiere en su nombre, como así también cederle todos los créditos y acciones que tenga contra terceros⁽²¹¹⁾.

El mandatario, en la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato, es responsable por dolo y toda culpa, porque el mandato implica un encargo de confianza que el mandatario debe cumplir con toda diligencia⁽²¹²⁾. También responde ante el mandante por las sumas de dinero que emplee en su propio interés y aquellas que, por su culpa, no le brinden al mandante rédito alguno, pagándole en consecuencia los correspondientes intereses⁽²¹³⁾.

Por su parte, el mandante debe reintegrarle al mandatario los gastos que éste debe efectuar para poder cumplir el encargo, como así también indemnizarlo por aquellas pérdidas que sufra a raíz de la gestión⁽²¹⁴⁾. Además, debe liberar al mandatario de las obligaciones que ha contraído en su nombre⁽²¹⁵⁾. El mandante responde por toda culpa, ya que el contrato se celebra en su propio beneficio.

La legislación romana, en un principio, rechaza la representación directa y por ello el mandatario no representa al mandante, sino que se vincula directamente con los terceros, haciéndose él propietario, acreedor o deudor, siendo necesario que los efectos del negocio le sean transferidos al mandante y recién a partir de ahí éste queda directamente vinculado con los terceros. Luego, se admite que los terceros, en determinados casos, puedan accionar directamente contra el mandante⁽²¹⁶⁾, e, inversamente, si el mandante es acreedor de un tercero, se le otorga una acción contra éste a fin de suplir la cesión de acciones a su favor que debe realizar el mandatario⁽²¹⁷⁾.

El mandato puede extinguirse voluntariamente, por acuerdo de ambas partes, o por decisión unilateral. En este último caso, puede ocurrir en virtud de causas necesarias que resultan ajenas a la intención de los contratantes. Entre las causas voluntarias se encuentran el mutuo consentimiento de ambas partes⁽²¹⁸⁾ y la renuncia del mandatario, pero esta última no puede llevarse a cabo en perjuicio del mandante, ni ser intempestiva, porque, si no, responde por los daños y perjuicios que su conducta pueda provocar al mandante⁽²¹⁹⁾. Si la renuncia tiene justos motivos, como por

ejemplo, haber contraído una enfermedad que le impide cumplir diligentemente con el encargo o que nazca entre las dos partes una enemistad, cesa su responsabilidad respecto del mandante⁽²²⁰⁾.

Ocorre lo mismo si el mandante revoca expresamente el mandato, y ello tiene efectos tanto respecto del mandatario como de los terceros desde que toman conocimiento de esta decisión⁽²²¹⁾. La revocación tácita opera cuando el mandante interviene directamente en el negocio que le ha encargado al mandatario o cuando éste designa a una nueva persona para que realice tal gestión⁽²²²⁾.

Entre las causas necesarias de extinción del mandato se encuentra el vencimiento del plazo estipulado por las partes o el cumplimiento de la condición a la que está sujeto el contrato⁽²²³⁾. También, provoca su disolución la muerte del mandatario o del mandante, ya que el mismo tiene su fundamento y razón de ser en la confianza que existe entre ambas partes, es decir que es de carácter personal. Sin perjuicio de ello, los actos realizados por el mandatario que ignora la muerte del mandante son perfectamente válidos y obligan a sus herederos⁽²²⁴⁾. Ello no ocurre así cuando las partes expresamente convienen en que la muerte del mandante no extingue el contrato⁽²²⁵⁾. Debo destacar que el caso que contempla la muerte del mandante, cuya circunstancia es desconocida por el mandatario, que continúa actuando convencido de que el mandato se encuentra vigente, conforma claramente uno de los tantos supuestos, como se ha visto, de la denominada modernamente "teoría de la apariencia".

IV. CUASICONTRATOS

Según las fuentes, entendemos por cuasicontratos a las obligaciones que no emergen de un contrato ni tampoco de un delito propiamente dicho, por lo que se asemejan a un contrato sin serlo⁽²²⁶⁾.

Dentro de la figura del cuasicontrato encontramos, entre otras, la gestión de negocios (negotiorum gestio), la tutela y curatela, el enriquecimiento sin causa, la comunidad incidental, el legado, los gastos funerarios, la lex Rhodia de iactu,⁽²²⁷⁾ etc.

1. La gestión de negocios (negotiorum gestio)

Consiste en la administración o gestión de intereses de un tercero llevados a cabo sin su anuencia o conocimiento. Estas premisas son importantes, por cuanto si el titular da instrucciones al gestor o conoce la gestión, nos encontramos dentro de la figura contractual del mandato. La gestión se debe llevar a cabo sin intervención del titular del negocio, obrando el gestor por propia iniciativa con el fin de anudar una obligación a cargo del titular para beneficiarlo o evitarle un perjuicio. La gestión produce efectos respecto del gestor y el titular del negocio (dominus negotii), que son las siguientes. El gestor debe finalizar la gestión iniciada y rendir oportunamente cuentas. El titular debe abonar al gestor las deudas y gastos en que hubiera incurrido en el ejercicio de la gestión. Ambos poseen acciones destinadas a hacer valer sus derechos; así la actio negotiorum gestorum directa (el titular) y la actio negotiorum gestorum contraria (el gestor). Por otra parte, una vez concretada la gestión, únicamente el gestor queda vinculado de manera directa con los terceros y, por ende, debe luego transmitir al titular los derechos y obligaciones adquiridos por la gestión⁽²²⁸⁾.

2. El enriquecimiento sin causa

Se configura cuando una de las partes se beneficia a expensas de la otra sin causa jurídica que lo justifique. El derecho romano trata el tema con profundidad y la cuestión evoluciona desde el derecho antiguo hasta Justiniano. De este modo encontramos el enriquecimiento sin causa contemplado en diversas acciones creadas para repararlo; v.gr., cuando una persona paga una obligación inexistente, cancelada o extinguida; cuando una persona paga según una causa lícita que nunca ha tenido lugar; cuando una persona paga más de lo que debe, etc.⁽²²⁹⁾.

3. La comunidad incidental

Se trata del condominio creado por un hecho ajeno a la decisión de los titulares en virtud de una confusión o una liberalidad de un tercero; v.gr., testamento. La jurisprudencia romana refiere respecto de ella de un modo similar a la comunidad convencional o societaria, pero como no puede aplicar las disposiciones de ésta en virtud de que no es creada por un acto voluntario, la considera entre los cuasidelitos⁽²³⁰⁾.

4. Los gastos funerarios

Son las erogaciones efectuadas por una persona para sufragar los gastos funerarios y entierro de otra, sin encargo a dicho respecto, ni tampoco movilizadas por razones de piedad. Es una relación muy similar a la gestión de negocios y los deudos del fallecido deben reintegrar dichos gastos al que los efectuó. Para el caso de que se negaran, se crea la "acción funeraria" (actio funeraria) para perseguir el cobro⁽²³¹⁾.

5. La lex Rhodia de iactu

Tiene su origen en Rodas y su disposición es adoptada por el derecho romano. Contempla la situación de que ante un peligro de naufragio se ordena aligerar la nave, arrojando al mar la carga que transporta para salvarla, o parte de ella misma. Los juristas romanos estimaron justa la solución que brinda la ley de los rodios en cuanto ordena la reparación de la pérdida de la mercadería arrojada al mar. Esta reparación debe ser llevada a cabo por los armadores y los propietarios de las mercaderías no arrojadas en razón de que sus intereses resultaron indemnes por la carga que se echó al mar⁽²³²⁾.

6. La tutela y curatela

La responsabilidad del tutor y el curador guardan similitud con la del gestor de negocios, remitiendo a lo dicho en oportunidad del desarrollo de las mencionadas instituciones de guardaduría. No obstante ello, he de señalar que las obligaciones originadas por la tutela y la curatela son consideradas por el derecho romano como un cuasicontrato en virtud de que no se origina por un acuerdo de voluntades entre representante y pupilo o curado⁽²³³⁾.

7. Los legados

Las obligaciones derivadas de los legados per damnationem y sinendi modo son consideradas como provenientes de un cuasicontrato en virtud de que no existe un acuerdo de voluntades entre legatario y heredero⁽²³⁴⁾.

FRANJA
MORADA

CAPÍTULO XXIV - DELITOS

El delito es la contravención voluntaria a una ley que acarrea la imposición de una sanción. Los delitos constituyen una de las fuentes de las obligaciones. Se dividen en delitos públicos y privados.

Los delitos públicos (crimina publica) son aquellos cuya comisión pone en riesgo el orden social, la organización político administrativa, la seguridad del Estado, y su persecución puede ser llevada a cabo por cualquier miembro de la comunidad. Los delitos privados (delicta privata) son los que afectan directamente a los particulares y sólo pueden ser perseguidos por el damnificado.

En los delitos públicos, los tribunales del Estado aplican la pena a fin de restablecer el orden social y la seguridad, mientras que en los delitos privados, la pena implica un resarcimiento a la víctima por el daño sufrido. Este último tipo de delitos le otorga al damnificado una acción para exigir al ofensor el pago de una pena pecuniaria, que habitualmente resulta proporcional al daño que ha sufrido.

Para que una persona resulte responsable de un delito es suficiente, en cuanto a la edad, que sea púber, pero también puede serlo quien carece de capacidad negocial, como los esclavos o los pródigos. Si varias personas cometen juntas un delito, la pena es personal y todos solidariamente deben reparar el daño causado, sin que puedan invocar el beneficio de división ni recurrir contra aquellos con quienes han cometido el delito.

Los delitos privados encuentran su primera clasificación en la "ley de las XII Tablas", que contiene una enumeración, con sus correspondientes sanciones. En determinados casos, como en el de las injurias, la ley sólo se limita a describir la forma de aplicar el castigo y el damnificado puede hacer uso de la venganza privada⁽⁴⁾. Con la evolución del delito privado, la graduación de la pena se efectúa teniendo en cuenta la intención criminal del autor del hecho e intentando que ella implique un resarcimiento equitativo al daño sufrido por el damnificado. Sin embargo, el ofendido, para poder obtener la condena del culpable, debe recurrir al procedimiento civil.

En la época imperial, los delitos privados son perseguidos mediante la acción civil ordinaria, al mismo tiempo que al ofensor se le aplican penas especiales. Así, la víctima puede optar entre obtener el resarcimiento pecuniario por los daños sufridos o demandar el castigo del delincuente mediante el procedimiento extraordinario (cognitio extraordinem).

En un principio, como ya señalara precedentemente, los delitos constituyen la principal fuente de obligaciones, ya que en susinicios los contratos son pocos y muy formales.

I. CLASIFICACIÓN

Los delitos pueden ser clasificados, como se ha visto, en públicos y privados.

Los delitos públicos son los siguientes:

a) Perduelo (Perduellio). Es el delito de alta traición que atenta contra la seguridad del Estado.

b) Parricidio (Parricidium). Consiste en causar la muerte de un pater familia. En este caso interviene el Estado para evitar una guerra civil entre los grupos familiares del ofensor y de la víctima. En mi opinión, es el antecedente más antiguo que se conoce respecto del actual delito de parricidio, es decir, el homicidio del padre perpetuado por el hijo (homicidio agravado por el vínculo).

c) Crimen maiestatis. Cuando no se respeta la potestad o autoridad del tribuno, de los ediles o de los jueces decenvirales (iudices decemviri).

d) Cohecho (repetundarum). Es el delito cometido por el funcionario que pide o acepta dádivas o coimas.

e) Peculado (peculatus). Se configura cuando un funcionario dispone como propios de los fondos públicos.

Las penas para los delitos públicos suelen ser: muerte del autor del delito (supplicium) y la multa (damnum), pero en ninguno de los dos casos se benefician con su aplicación los particulares que resultan víctimas del delito.

Los delitos privados son los siguientes⁽²⁾:

a) Injuria (iniuria). Es el atentado contra las personas, ya sea con palabras o hechos. Implica una lesión personal que puede ser tanto física como moral⁽³⁾. La "ley de las XII Tablas" contempla el delito de iniuria como todo ataque dirigido a la persona física, sin importar la intención con la que se lo efectúa, ya que comprende también los daños ocasionados por simple imprudencia, distinguiendo entre aquellos actos que provocan lesiones graves y aquellos que ocasionan lesiones leves, estableciendo distintas sanciones para cada caso. Por ejemplo, entre las lesiones graves se incluye la ruptura de un miembro y ello se castiga con la aplicación de la "ley del Talió", a menos que las partes convengan una composición voluntaria. Las lesiones leves, en cambio, se sancionan con penas, pecuniarias. La ley decenviral también reprime las injurias difamatorias y si éstas han sido públicas, ello se castiga con la pena de muerte⁽⁴⁾.

El derecho honorario amplía la noción de este delito, agregando cualquier lesión moral que sufra la persona, comprendiendo entonces a la difamación escrita o verbal, las palabras ultrajantes y la violación de domicilio, entre otros⁽⁵⁾. Sólo incluye aquellos casos en que el ofensor actúa con dolo.

En la época de Sila se dicta la lex Cornelia de iniuris, que establece nuevas formas para este delito. Esta ley permite que aquella persona que es ofendida pueda reclamar el pago de una suma de dinero, cuyo importe será determinado judicialmente. La acción es perpetua y su ejercicio sólo está en manos de la víctima⁽⁶⁾. Ello le brinda una mayor protección al ofendido.

En el derecho imperial, el espectro de posibilidades aumenta todavía más, ya que el delito de iniuria comprende la más leve lesión corporal y las violaciones menores de los derechos de la personalidad⁽⁷⁾. En estos casos, el damnificado puede optar entre la acción privada o la persecución criminal, tendiente a aplicar una pena corporal⁽⁸⁾.

b) Furtum. Es todo acto mediante el cual una persona le sustrae a otra una cosa con la intención de aprovecharse de ella. Implica la aprehensión fraudulenta de una cosa contra la voluntad de su dueño con la intención de obtener un beneficio de ello, ya sea mediante su uso o posesión. Advierto que el delito del furtum en Roma abarca en conjunto los actuales delitos de hurto, robo y estafa⁽⁹⁾. Comprende así todos aquellos casos en que una persona sustrae fraudulentamente una cosa que le pertenece a otra con el propósito de obtener un beneficio económico⁽¹⁰⁾. Se lo legisla en Roma por primera vez en la "ley de las XII Tablas"⁽¹¹⁾.

Existen cuatro clases de furtum, a saber:

— Manifestum. Es cuando el ladrón es sorprendido in fragante. Comprende tanto aquellos casos en que el ladrón es sorprendido en el lugar en que se consuma el hecho, como cuando todavía tiene la cosa hurtada en su poder o es visto por el dueño u otra persona antes de esconderse⁽¹²⁾.

— Nec manifestum. El autor del delito es descubierto, pero no sorprendido en el momento en que está cometiendo el hurto⁽¹³⁾.

— Conceptum. Implica una especie de encubrimiento que se origina cuando una persona oculta en su casa la cosa hurtada por otro. Ello da lugar a la realización de una pesquisa, la cual puede ser solemne o no solemne. En el primer caso, el propio ofendido ingresa desnudo al domicilio del causante a fin de registrarlo, llevando una bandeja en sus manos. Entiendo que nos encontramos ante el vestigio más remoto de la actual orden de allanamiento de domicilio.

— Oblatum. Se tipifica cuando el autor del delito oculta la cosa en otra casa para deslindar su propia culpa, eximiéndose de responsabilidad, o le entrega la cosa a un tercero de buena fe⁽¹⁴⁾.

b.1. Evolución del delito del furtum. Posteriormente, la jurisprudencia clásica crea dos nuevos tipos de furtum: el denominado furtum prohibitum, por medio del cual se sanciona al ocultador de una cosa robada que se opone a la realización de la pesquisa que se pretende llevar a cabo en su domicilio ante testigos, y el furtum non exhibitum, en el cual incurre aquella persona que se niega a entregar la cosa robada que se encuentra escondida en su casa⁽¹⁵⁾. También se extiende el concepto de furtum al uso ilícito de la cosa, denominado furtum usus. Este último se configura cuando una persona que tiene la posesión de una cosa ajena, v.gr., el depositario o comodatario, la usa en su provecho sin autorización, o le brinda un uso distinto al convenido. Además, surge

el *furtum possessionis*, que se da cuando el propietario de una cosa despoja de su posesión a aquella persona a quien se la ha entregado en virtud de un contrato⁽¹⁶⁾.

Durante el Bajo Imperio y en la época justinianeas, se suprimen las variedades del *furtum* indicadas precedentemente, subsistiendo únicamente la distinción entre el *furtum manifestum* y *furtum nec manifestum*. En esta época, para que el delito se configure se requiere que una persona se apodere de una cosa ajena, lo cual se logra cuando el ladrón se la lleva del lugar en el cual su dueño la tiene guardada. No basta la mera intención de cometer el ilícito para que éste se consuma⁽¹⁷⁾. La sustracción del objeto debe realizarse en contra de la voluntad de su propietario, por lo que la apropiación de una cosa con el consentimiento de su dueño o de su poseedor, como así también la apropiación de una cosa abandonada o sin dueño, no configuran este delito, excepto que se trate de una cosa perdida y que aquel que lo haga tenga conocimiento de esta circunstancia⁽¹⁸⁾.

También, se exige la presencia de un elemento subjetivo dado por la intención fraudulenta de obrar en perjuicio de los intereses de un tercero⁽¹⁹⁾. El ofensor debe cometer el delito con la voluntad de obtener un beneficio, y no importa si después se la entrega a un tercero⁽²⁰⁾.

El objeto del ilícito debe ser una cosa mueble que se encuentre dentro del comercio, y más tarde se admite que pueda hurtarse una persona libre, como por ejemplo un *filius familias*, la mujer *in manu* y el deudor sometido a la *manus iniectionis* del acreedor⁽²¹⁾. Por otra parte, cuando el autor sustrae una *res divini iuris*, se considera que se trata de un delito de carácter público⁽²²⁾.

c) *Damnum iniuria datum*. Es el daño ilícito ocasionado intencional o culposamente a una cosa ajena. Ello difiere de nuestro derecho, ya que sólo se encuentra tipificado el daño doloso. Este delito es contemplado por la "ley de las XII Tablas", que contiene distintos casos, sin llegar a configurar la noción de un tipo único de delito⁽²³⁾. A instancias del tribuno Aquilio se sanciona el plebiscito denominado "ley aquilia" (*lex Aquiliae*), que deja sin efecto las disposiciones contenidas en la ley decenviral relacionadas con este delito, intentando generalizar los casos de daño injustamente causado⁽²⁴⁾.

Este daño debe consistir en la destrucción material de una cosa ajena, extendiéndose luego el concepto a aquellos supuestos en que se reduce el valor material de la cosa, aunque ésta aún conserve su integridad⁽²⁵⁾. Además, debe haber sido causado como consecuencia de un esfuerzo físico ejercido sobre la cosa. Luego la jurisprudencia incluye aquellos casos en que no hay un contacto físico directo sobre la cosa; v.gr., si una persona encierra a un esclavo ajeno y lo deja morir de hambre⁽²⁶⁾.

También se requiere la presencia de un elemento subjetivo, bastando para ello no sólo que el daño se ocasione con dolo, sino también como consecuencia de culpa o negligencia por parte del ofensor⁽²⁷⁾. Por ello, resulta suficiente la mera relación de causalidad entre el hecho provocado por el autor y el daño que le provoca a la cosa perteneciente a la víctima, sin considerar que exista la voluntad de originar el resultado dañoso.

Se encuentra exento de responsabilidad aquel que actúa dentro de los límites de la ley, aunque su conducta le provoque un daño a alguien; por ejemplo, cuando una persona mata a un esclavo ajeno que intenta lesionarla⁽²⁸⁾.

d) *Rapiña*. Se lo incluye dentro de los delitos por decisión de Justiniano. Implica un hurto calificado, porque la sustracción de la cosa se lleva a cabo con violencia. Generalmente es cometido por bandas armadas o por una multitud de personas desarmadas⁽²⁹⁾. Durante el Imperio se amplía este delito a los hechos provocados por una sola persona, siempre que medie violencia, sin importar si ésta, para llevarlo a cabo, se encuentra o no armada⁽³⁰⁾. Disposiciones de Augusto (*lex Iulia de vi publica et privata*) y de Marco Aurelio (*Divi Marci*) castigan con pena de confiscación a aquel que, portando armas o ayudado por varias personas, se apodera de un inmueble despojando al poseedor⁽³¹⁾.

II. ACCIONES QUE CONFIEREN LOS DELITOS PRIVADOS

Gayo enseña en su obra *Institutas* que los delitos privados otorgan tres clases de acciones, a saber: penales, reipersecutorias y mixtas. Son intransmisibles, ya que no pueden ser ejercitadas por los herederos de la víctima, como así tampoco pueden intentarse contra los del ofensor. Más tarde

se permite que las acciones puedan iniciarse contra los herederos del delincuente por el monto de lo que éstos se han aprovechado económicamente. También se van a transmitir a los herederos de la víctima, con excepción de las injurias, en las que la ofensa aparece como estrictamente personal⁽³²⁾.

Además, las acciones son acumulables, es decir que el ofendido puede intentar al mismo tiempo cualquier otra acción que, originándose en el mismo delito, conduzca al mismo fin que aquélla, ya sea la recuperación de la cosa o el resarcimiento del daño. Otra característica es la "noxalidad", por la cual se autoriza al ofendido a perseguir la entrega del autor del delito cuando se trate de un esclavo o un filius familias. Esta acción se ejerce contra el dominus o el pater, quienes se encuentran facultados a evitar la entrega del hijo o el esclavo a cambio de pagar la indemnización correspondiente⁽³³⁾.

Finalmente, aquellas acciones emergentes de los delitos privados enmarcadas dentro del ius civile son perpetuas, por lo que pueden ser ejercitadas en cualquier momento, sin que el transcurso del tiempo afecte el derecho. Esto no sucede con las acciones que sancionan los delitos pretorianos, ya que éstas se extinguen en el transcurso de un año, contado desde el momento en que se comete el delito o desde que el ofendido se encuentra en condiciones de iniciar la acción⁽³⁴⁾.

Ahora bien, las "acciones penales" le imponen al autor del ilícito una pena pecuniaria cuyo monto puede alcanzar el doble, triple, cuádruplo, etc., del valor del perjuicio. Las "acciones reipersecutorias" persiguen la reparación del daño causado o la indemnización por daños y perjuicios. Por su parte, las "acciones mixtas" imponen la pena pecuniaria y la reparación del daño.

III. CUASIDELITOS

Del análisis de las fuentes, no surge que se hayan tenido en cuenta caracteres o patrones que permitan dilucidar el concepto de cuasidelito, siendo por lo general de creación pretoriana. Es más, en ciertos casos se consideran cuasidelitos a verdaderos delitos, y también viceversa. Es decir que no se puede aseverar que en los delitos prima el dolo y en los cuasidelitos la culpa. Por cierto que la cuestión no ha pasado desapercibida por los juristas romanos, dado que los cuasidelitos, como también los cuasicontratos, son tenidos en cuenta por Gayo (variae causarum figurae) y después por Justiniano (ex variis causarum figuris). Efectuada esta aclaración previa, puedo decir, entonces, que para el derecho romano cuasidelitos son obligaciones que guardan similitud con aquellas originadas en un delito propiamente dicho⁽³⁵⁾.

Entre los principales cuasidelitos encontramos los siguientes: el juez que hace suyo el proceso; las cosas arrojadas o derramadas; las cosas suspendidas o colgadas; la responsabilidad de los barqueros, posaderos y dueños de establos, aun por el hecho de sus dependientes; etc.⁽³⁶⁾.

PARTE TERCERA - OTROS ASPECTOS DEL DERECHO ROMANO

CAPÍTULO XXV - PROCEDIMIENTO CIVIL ROMANO

La preocupación de Roma no es sólo "crear derecho", sino también "estar al derecho". La madurez de su cultura le hace comprender que es fundamental en la temática de "dirimir conflictos" realizar de la manera civilizada, es decir, incruenta. A modo de reflexión, debo acotar que, acicateados por lograr la "paz social", avizoran que ésta sólo se puede lograr de dicho modo, incluso como factor político, por cuanto, siendo Roma "cuna de civilización", necesariamente, para darse a conocer al conquistar los pueblos circunvecinos o denominados "bárbaros", debe tener "el frente interno en paz". Y el mejor modo de demostrarlo es mediante un modo de dirimir conflictos de manera civilizada, es decir, sin violencia⁽¹⁾.

La primitiva manifestación de la organización judicial romana se encuentra dentro de la gens y la familia, en donde el jefe de familias (paterfamiliae) resuelve todos los conflictos que se presentan entre sus miembros⁽²⁾. Mas, luego, cuando la controversia se produce de manera exógena, fuera del grupo familiar, entre individuos que pertenecen a distintas familias, se hace necesario impartir justicia por intermedio de un tercero ajeno a ellas. Es claro que esta evolución del sistema procesal romano en general no es ajena a lo experimentado por casi todas las civilizaciones antiguas. En efecto, el primer atisbo de justicia, aunque imperfecto, es el denominado "justicia por mano propia" ("venganza privada"), que consiste en la punición a cargo de la propia víctima, lo que apareja inevitable excesos por falta de objetividad del damnificado. Luego se produce un adelanto en la cuestión, cuando se pretende cuantificar el daño mediante la denominada "ley del talión" ("ojo por ojo, diente por diente"). Pero este nuevo estadio de avance procesal, si bien demuestra cierta cordura, no contribuye de un modo equitativo a la "paz social". Por dicho motivo, el sistema procesal se dirige hacia la etapa de la denominada "composición voluntaria", mediante la cual la víctima conviene con el responsable del daño el monto pecuniario de la reparación. Este sistema es perfeccionado luego por la intervención de la autoridad pública (tercero imparcial) en la determinación de la indemnización.

Ahora bien, circunscribiendo la cuestión a la órbita del procedimiento civil, es menester dejar en claro la siguiente premisa para favorecer la comprensión del sistema romano: En el mundo moderno la función de impartir justicia se encuentra a cargo del Estado, pero en Roma, desde tiempo antiguo y hasta el gobierno de Diocleciano (año 284), dicha facultad es delegada en manos privadas. El Estado actúa en la primera parte del procedimiento a través de los magistrados, esencialmente el pretor. El dictado de la sentencia corresponde en la segunda etapa al juez, árbitro o tribunal, que no son otra cosa que simples particulares, al igual que los litigantes, designados expresamente para dicho pleito. Es a partir de Diocleciano que el Estado decide monopolizar la función de justicia como facultad privativa, iniciando el procedimiento moderno. Ya no es el simple particular quien dicta la sentencia, sino magistrados o jueces designados en modo permanente para la función. Efectuada esta premisa fundamental, destaco que el sistema procesal civil romano se divide a lo largo de su evolución en dos etapas perfectamente diferenciadas: 1º) El "ordenamiento procesal privado" (ordo iudiciorum privatorum). 2º) El "procedimiento extraordinario o de conocimiento fuera de orden" (cognitio extraordinem o extraordinaria cognitio).

El primero, a su vez, se encuentra desarrollado en dos sistemas procesales que emergen sucesivamente, a saber: "acciones de la ley" (legis actiones) y "procedimiento formulario" (per formulam). El segundo lo encontramos en el sistema que es en principio excepcional y luego definitivo, denominado de igual modo: "procedimiento extraordinario" (cognitio extraordinem)⁽³⁾.

I. EL ORDENAMIENTO PROCESAL PRIVADO (ORDO IUDICIORUM PRIVATORUM). CARACTERES GENERALES

Es el ordenamiento procesal que presenta como característica primordial "la prevalencia del juez privado (iudex privatus) elegido por las partes en litigio o, en su defecto, por el magistrado"⁽⁴⁾. Como ya dijera, este "ordenamiento procesal" se lleva a cabo a través de dos grandes sistemas que se conocen como "acciones de la ley" (legis actiones) y "procedimiento formulario" (per formulam). En ambos sistemas advertimos dos etapas perfectamente diferenciadas: la primera, sustanciada ante el magistrado, denominada "de derecho" (in iure), y la segunda, ante juez, árbitro o tribunal, llamada en juicio (in iudicio o apud iudicem).

La presencia del Estado se encuentra en modo fundamental, como dijera, en la primera parte del ordenamiento procesal (in iure) con la actuación del magistrado. El dictado de la sentencia, por el contrario, se delega en la segunda etapa (in iudicio) a un simple particular (juez o árbitro) designado a tales efectos para dicho caso. Estos últimos no representan al Estado, porque carecen de imperium y se limitan a resolver las situaciones de hecho que les someten a su decisión los magistrados que intervienen en la primera de las etapas señaladas (in iure)⁽⁵⁾. La ejecución de la sentencia, una vez firme, no se encuentra a cargo del "juez privado", sino que debe ser sustanciada en una nueva instancia ante el magistrado que, por tener imperium, es quien decide al respecto.

Esto último se condice con lo expuesto más arriba, en cuanto he sostenido que la presencia del Estado se encuentra en la primera etapa del procedimiento con la figura del magistrado (el pretor por excelencia) y en la segunda instancia se delega en manos del juez o árbitro (un simple particular) el dictado de la sentencia o veredicto. Pero como éstos carecen de imperium, puesto que no son funcionarios del Estado y no tienen atribución para ordenar la ejecución de la sentencia que dictan, es entonces que el favorecido con el veredicto debe acudir nuevamente ante el magistrado, sustanciar un nuevo juicio (ejecutivo esta vez) similar al primero y, una vez comprobada por el nuevo juez designado por el magistrado la procedencia de la acción de ejecución, es el magistrado quien emite finalmente un decreto de ejecución. En otras palabras, la legalidad de la ejecución se encuentra a cargo del Estado y no de los particulares.

Es así que ambos sistemas procesales que componen el "ordenamiento procesal romano" (ordo iudiciorum privatorum), a saber, "acciones de la ley" (legis actiones) y formulario (per formulam), presentan generalidades comunes, aunque matizadas por variantes, producto del tiempo histórico de cada una de ellas que se analizará en cada caso en particular.

II. SISTEMA DE LAS ACCIONES DE LA LEY (LEGIS ACTIONES)

Es el sistema procesal más antiguo que se conoce en Roma. Su aplicación se extiende aproximadamente desde casi la misma fundación de la "ciudad-estado" y hasta la sanción de la lex Aebutia (230 a.C.). Es anterior a la misma "ley de las XII Tablas", que lo recoge por escrito, siendo regulado con anterioridad por la "costumbre". Se lo denomina de dicho modo por cuanto las acciones que lo componen son creadas por la ley y deben ajustarse estrictamente y formalmente a la misma en modo inmutable⁽⁶⁾.

Es necesario dejar en claro que "acción" (actio) no es lo mismo que "acción de la ley" (legis actiones). Por la primera "se entiende siempre la posibilidad de amparo judicial de una situación o posición jurídica en un caso determinado"; v.gr., la rei vindicatio en defensa del propietario quiritario. En cambio, "acción de la ley" hace referencia a las vías de procedimiento solemnes por las cuales debe transitar la acción (actio)⁽⁷⁾.

Las características primordiales de este sistema procesal son las siguientes: oralidad, solemnidad, excesivo ritualismo, ejercicio reservado exclusivo para los ciudadanos romanos, comparecencia de éstos de modo personal ante el magistrado en días fastos y dentro de los límites de la ciudad, carácter abstracto y fundamento en el derecho quiritario⁽⁸⁾.

De acuerdo con este sistema procesal, los pleitos sólo pueden tramitarse por las cinco acciones permitidas, a saber: "acción de la ley por apuesta sacramental" (legis actio per sacramentum); "acción de la ley por postulación de juez o árbitro" (legis actio per postulationem); "acción de la ley por condictio" (legis actio per condictioem); "acción de la ley por aprehensión corporal" (legis actio per manus iniectionem); "acción de la ley por toma de prenda" (legis actio per pignoris capionem)⁽⁹⁾.

De estas acciones, las tres primeras son "declarativas", porque el litigio versa respecto del reconocimiento o decisión de un derecho controvertido; y las dos últimas, "ejecutivas", por cuanto ejecutan una sentencia existente o un acto con efectos similares a ella⁽¹⁰⁾.

El procedimiento de "las acciones de la ley", como dije ut supra, se implementa a través de las dos etapas indicadas. La primera, conocida como "de derecho" (in iure), sustanciada ante el magistrado (casi siempre el pretor) con la realización de ritos y palabras solemnes que deben ser pronunciadas puntillosamente por el demandante. La segunda, denominada "en juicio" (in iudicium o apud iudicium), desarrollada ante un juez privado (iudex privatus) que dirime el pleito. La designación de este último se efectúa deinmediato, pero después de la sanción de la lex Pinaria (281 a.C.), se concede un plazo de treinta días para la designación⁽¹¹⁾. De manera sucinta he de decir que el sistema procesal del sistema de las "acciones de la ley" funciona del siguiente modo.

1. La etapa "de derecho" (in iure) en el sistema de las acciones de la ley

Es la primera etapa, denominada "de derecho", que se sustancia ante el magistrado (por lo general el pretor). Se inicia con "laintimación particular" efectuada en forma solemne por el demandante al demandado para que comparezca ante el magistrado en un día determinado. La citación puede ser efectuada en el domicilio del demandado o en cualquier otro lugar en que fuere hallado por el demandante. El emplazado no puede sustraerse de la intimación, a menos que garantice su comparecencia mediante una persona solvente (vindex)⁽¹²⁾. Para el caso de que el citado se niegue a comparecer ante el magistrado, el demandante, frente a testigos que acrediten la negativa, puede ponerle las manos encima y llevarlo por la fuerza. Este accionar duro con el emplazado que se niega a comparecer contiene atenuantes que la misma ley de las XII Tablas se encarga de prescribir; así, por causa de edad avanzada o mal estado de salud, el citado puede exigir al accionante que le suministre un medio de transporte⁽¹³⁾.

Soy del parecer que es interesante dejar en claro que este modo de citación compulsivo extrajudicial (manus iniectio) no debe confundirse con la "acción de la ley de carácter ejecutiva", denominada precisamente "acción de la ley por aprehensión corporal" (legis actio per manus iniectioem), que más adelante se analizará con debida atención⁽¹⁴⁾.

Estas primeras excepciones luego son ampliadas mediante "edicto" por los pretores, prohibiendo la citación particular directa del emplazado sin autorización previa del magistrado en los siguientes casos: los cónsules, pretores y demás magistrados "con imperio" (cum imperio) en el ejercicio de sus funciones; los pontífices mientras practican el culto; los novios durante la celebración del matrimonio; el juez cuando está conociendo un asunto; los deudos de un pariente durante el entierro de éste; y aquel que se encuentra en el mismo momento ejerciendo otra acción⁽¹⁵⁾. Más adelante se agregan otras prohibiciones especiales a las citaciones particulares, imponiendo la autorización previa del magistrado, a saber: las personas a quienes se debe respeto y obediencia (v.gr., padre, madre, demás ascendientes; el patrono, la patrona y sus hijos). La pena por el incumplimiento es una multa pecuniaria de cincuenta áureos⁽¹⁶⁾.

El juicio debe sustanciarse íntegramente en una sola sesión, pero para el caso de que no fuese posible, con el fin de evitar una nueva citación del demandado, se permite que la audiencia pueda continuar o fijar para otro día, siempre y cuando el emplazado asegure su comparecencia, ofreciendo a una persona como garante de su asistencia (vas o vades). Más tarde, esta garantía se sustituye por una promesa formal del demandado de pagar una suma de dinero si no cumple con la obligación de concurrir a la nueva audiencia (vandemonium). Mas si el demandado no ofrece garante o no asume el compromiso de pagar la multa pecuniaria, el demandante está autorizado a retenerlo a fin de asegurar la nueva asistencia. Finalmente, si el citado no concurre a la audiencia fijada, el demandante puede accionar contra el garante (vades) o exigir el pago de la multa pecuniaria (vandemonium)⁽¹⁷⁾.

Una vez ambas partes presentes ante el pretor, se sustancia la "etapa de derecho" propiamente dicha, con la exposición del reclamante ante el magistrado de "la pretensión" (editio actionis), fundándola en el "derecho civil" (ius civile). A continuación el pretor debe conceder o negar la viabilidad de la acción invocada.

En este punto, debo señalar que, pese a cierta oscuridad en las fuentes al respecto, soy del parecer que el pretor no puede denegar la pretensión articulada por el actor cuando ella tiene

fundamento en alguna de las "acciones de la ley", aunque su opinión fuera contraria⁽¹⁸⁾; pero sí puede denegarla en los otros casos.

Entonces, una vez que el pretor procede a conceder o denegar la viabilidad de la acción frente a la presencia de testigos del acto, se concierta entre las partes un acuerdo verbal por el cual el proceso queda trabado (litis contestatio). Este acto procesal es de suma importancia, implicando para las partes asumir una obligación de carácter judicial mediante la cual se consuma la pretensión original del accionante, originando una nueva relación que conduce a la sentencia. Ambas partes quedan identificadas de manera inamovible y fijan su posición respectiva, que no pueden tampoco modificar. En razón de la postura fijada por los litigantes, el juez, en la etapa posterior, debe dictar la sentencia.

Debo realizar al respecto las siguientes precisiones: los testigos del acto procesal por el cual la "litis" queda trabada lo son con independencia de los testigos que hacen a la prueba de los hechos de la controversia. Justamente, el nombre de "litis contestatio" se debe a la presencia de los testigos del acto, que tienen la finalidad de dar fe de la existencia y contenido del pleito. En otras palabras, no se debe olvidar el carácter primordial del sistema de "las acciones de la ley", que es la oralidad; entonces, necesariamente, al no quedar registros escritos del debate, los testigos ofrecidos por cada litigante presentes en el acto dan fe de la posición de cada uno para preservar su inalterabilidad ante la exposición que deben realizar a posteriori ante el juez. En este caso son testigos de la "litis trabada", y no de los hechos controvertidos, aunque nada entorpece que luego lo fueran también de estos últimos.

Frente a las posiciones asumidas por las partes se pueden presentar en la instancia ante el magistrado las siguientes posibilidades: 1) Que el demandado reconozca expresamente la pretensión del demandante, aceptando el derecho por éste invocado (confessio in iure). En la actualidad podemos hablar de "allanamiento de la pretensión del actor por parte del demandado, dando fin al litigio". El reconocimiento debe ser aceptado por el pretor (addictio), produciendo efecto de "cosa juzgada" y autoriza al acreedor a iniciar la ejecución del crédito⁽¹⁹⁾. 2) Que el demandado enerve la pretensión del actor, ordenando el pretor la sustanciación de la segunda etapa ante el juez o árbitro. 3) Que el demandado asuma una conducta esquiva o remisa, negándose a intervenir activamente en el proceso, lo que dificulta la sustanciación del proceso, por cuanto en las "acciones de la ley" no se conoce aún el instituto procesal de la "rebeldía". La actitud del demandado autoriza, en el caso de una "acción personal" (crédito), al actor a dirigir la pretensión contra la garantía otorgada por el primero (vades o vindex). Y para el caso de una "acción real" (propiedad), el pretor soluciona la situación equiparándola con el primer supuesto (confessio in iure)⁽²⁰⁾.

2. La etapa "en juicio" (apud iudicium) en el sistema de las acciones de la ley

Es la segunda etapa del sistema procesal que se sustancia ante el juez, árbitro o tribunal. Tiene lugar cuando el demandado enerva la pretensión articulada por el actor, sosteniendo tener un derecho a su favor que la contrapone (la segunda de las posibilidades indicadas en el acápite anterior). La etapa en sí misma comienza cuando el pretor da por concluida la instancia "de derecho", ordenando la designación de un juez, cuya elección queda a cargo de las partes y, para el caso de discrepancia, la suple con su decisión. Como dijera, en un principio la designación es inmediata; luego, por la lex Pinaria (281 a.C.), se otorga un plazo de treinta días⁽²¹⁾.

Generalmente se dice que la etapa "en juicio" se sustancia ante el juez o árbitro, lo que es cierto, pero he de realizar las siguientes apreciaciones. En realidad, puede ser un juez, árbitro o tribunal, según la índole de la controversia⁽²²⁾. Así, en una "acción personal" interviene un juez (iudex); en una "acción real", un juez o un tribunal, que puede ser el de los centunviro o el de los decenviro; en una "acción divisoria", un juez o árbitro (arbiter); y en toda clase de acciones en que involucre extranjeros, el tribunal de los recuperatores.

El juez (iudex) es un simple particular encargado de decidir la causa. Sus facultades son más bien restringidas, por cuanto se limita a "reconocer o no la existencia del derecho y de los hechos en la forma en que es dada por el magistrado, condenando o absolviendo al demandado"⁽²³⁾.

El árbitro (arbiter), a diferencia del juez, posee, por el contrario mayor libertad en cuanto a la apreciación de los hechos y el derecho, lo cual se advierte reflejado en la sentencia. A diferencia del